InDret
REVISTA PARA EL
ANÁLISIS DEL DERECHO

WWW. INDRET.COM

El remedio indemnizatorio en el derecho español de daños*

Análisis, aplicación e instrumentos comparados

2013

2ª edición

Pablo Salvador Coderch (Ed.)
Catedrático de derecho civil, abogado, fundador y *senior editor* de InDret

Carlos Gómez Ligüerre
Profesor titular de derecho civil

Antoni Rubí Puig
Doctor en derecho, profesor lector de derecho civil

Sonia Ramos González
Doctora en derecho, investigadora del programa Ramón y Cajal

Álvaro Luna Yerga
Doctor en derecho, abogado (Cuatrecasas), profesor asociado de derecho civil

Antoni Terra Ibáñez
Doctorando en derecho, estudiante de economía

*Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de investigación "Análisis de los remedios (*Remedies*) en derecho privado español según la teoría general de la aplicación del derecho (*Law Enforcement Theory*), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional de I+D+I, 2011-2013, DER2010-15624).

Índice

Capítulo 1º: Fundamentos analíticos del remedio indemnizatorio en el derecho español de daños **2**
Pablo Salvador Coderch, Antoni Terra Ibáñez

Capítulo 2º: Las cuatro reglas básicas de responsabilidad y los límites del derecho de daños **29**
Pablo Salvador Coderch, Sonia Ramos González

Capítulo 3º: Negligencia (I): Circunstancias de la negligencia **38**
Pablo Salvador Coderch, Antoni Rubí Puig

Capítulo 4º: Negligencia (II): Estimación del riesgo **55**
Pablo Salvador Coderch

Capítulo 5º: Negligencia (III): Negligencia *per se* y *res ipsa loquitur* **69**
Pablo Salvador Coderch, Sonia Ramos González

Capítulo 6º: Negligencia (IV): Culpa comparativa y culpa contributiva
Pablo Salvador Coderch, Carlos Gómez Ligüerre

Capítulo 7º: Causalidad de hecho
Pablo Salvador Coderch, Antoni Rubí Puig

Capítulo 8º: Imputación objetiva
Pablo Salvador Coderch, Antoni Terra Ibáñez

Capítulo 9º: Responsabilidad objetiva
Antoni Rubí Puig

Capítulo 10º: Daño
Sonia Ramos González

Capítulo 11º: Responsabilidad por hecho ajeno
Carlos Gómez Ligüerre

Capítulo 12º: Prescripción
Carlos Gómez Ligüerre

Capítulo 13º: El proceso civil de reclamación de responsabilidades civiles **97**
Álvaro Luna Yerga

Capítulo 1º
Fundamentos analíticos del remedio indemnizatorio en el derecho español de daños

1. Estructuración del análisis **2**
1.1. Preliminar: Cuatro modos de estructurar un discurso 2
1.2. La transversalidad del derecho de daños. Responsabilidad civil y responsabilidad civil derivada de delito o falta penales: atropello múltiple en la estación de ferrocarril de Castelldefels, Barcelona (23.6.2010) 6
1.3. Accidente de ferrocarril 10
2. Fuentes primarias y secundarias/ *Primary and Secondary Sources* **12**
2.1. Legislación / *Statutes* 12
2.2. Jurisprudencia / *Case-law* 13
2.3. Doctrina / *Secondary Literature or Secondary Sources* 14
3. Análisis económico del derecho / *Law and Economics* **16**
4. Concepto y clases de accidente, y limitaciones del derecho de daños. La minimización de los costes sociales de los accidentes **17**
4.1. Concepto y clases de accidente 17
4.2. Algunas limitaciones del derecho privado de daños 18
4.3. La minimización de los costes sociales de los accidentes (Guido CALABRESI, 1970; Steven SHAVELL, 2004) y las simplistas pero escasamente realistas asunciones iniciales de los modelos analíticos del moderno derecho de daños 19
5. La acción de daños de los perjudicados por un ilícito competencial y la Propuesta de Directiva comunitaria de 11.6.2013 ..... **20**
6. Responsabilidad civil y penal / *Tort and Crime* **23**
7. Responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad (también civil, pero) contractual / *Tort and Contract* **24**
8. ¿Es el derecho de daños una especialidad bien definida? **27**

1. Estructuración del análisis

1.1. Preliminar: Cuatro modos de estructurar un discurso

Los buenos profesionales del derecho se expresan, verbalmente y por escrito, con un discurso estructurado sobre el caso o los casos que analizan. A continuación se presentan cuatro buenas maneras de estructurar el análisis de los casos en derecho y en derecho de daños, pero solo la primera es propia del jurista:

IRAC: el punto de vista del jurista:

a) *Issue*: ¿cuál es o cuáles son las cuestiones legales que plantean los hechos alegados y probados por las partes en el caso?
b) *Rules*: ¿cuáles son las reglas de derecho aplicables a los hechos del caso? En su caso: ¿cuál es la jurisprudencia?
c) *Analysis*: ¿cuáles son las razones, en derecho, de las partes, de cada una de ellas?
d) *Conclusion*: ¿qué concluiría el Juez o Tribunal en un caso como el presentado o qué habría de haber resuelto?

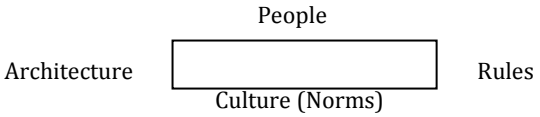
Para más información, véase http://www.csun.edu/~kkd61657/brief.pdf

Lecciones para el futuro: el punto de vista del ingeniero:

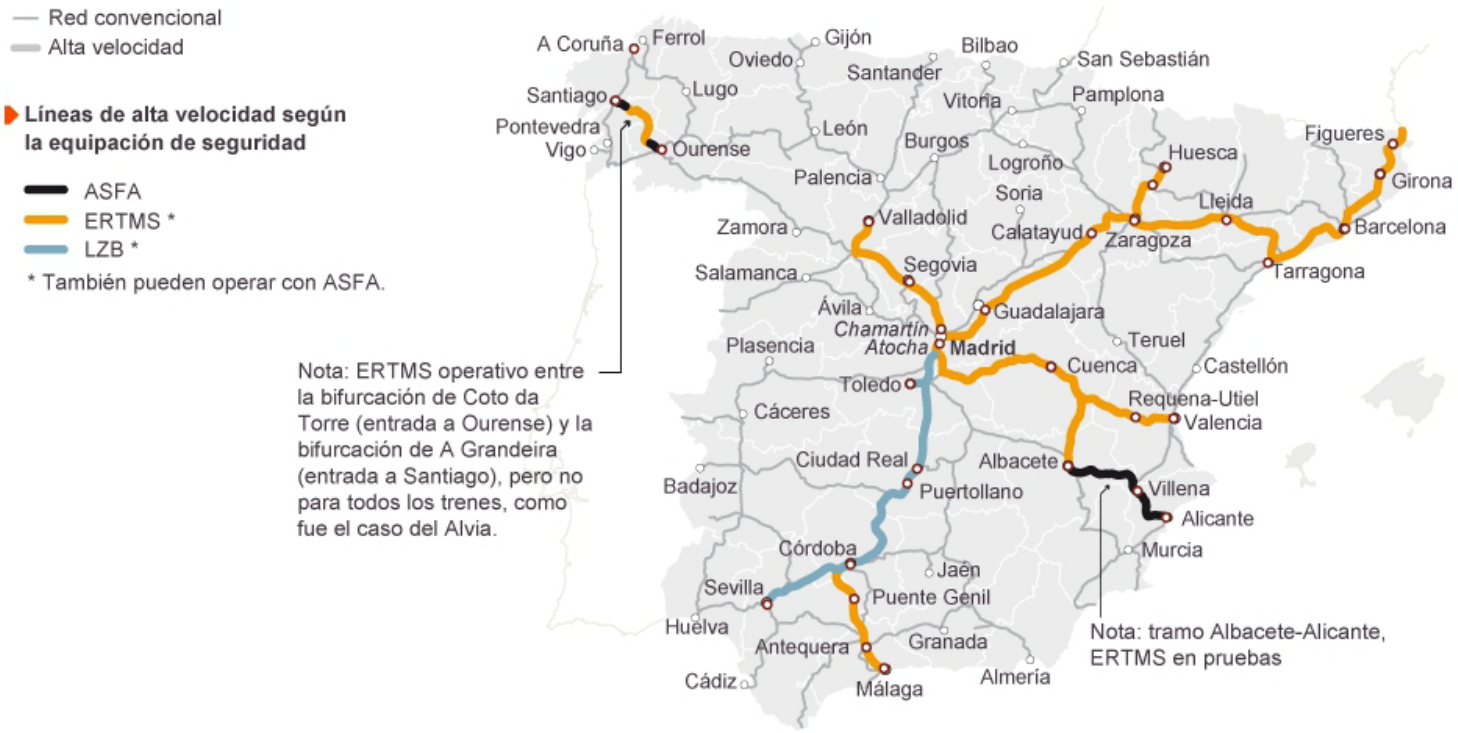
J. BUONGIORNO, R. BALLINGER, M. DRISCOLL, B. FORGET, C. FORSBERG, M. GOLAY, M. KAZIMI, N. TODREAS, J. YANCH, *Technical Lessons Learned from the Fukushima-Daichii Accident and Posible Corrective Actions for the Nuclear Industry: An Initial Evaluation*, Nuclear Science & Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Canes publications, May 2011
http://web.mit.edu/nse/pdf/news/2011/Fukushima_Lessons_Learned_MIT-NSP-025.pdf

a) Observations from the accident
b) Key questions
c) Possible corrective actions
d) Possible design improvements in the future

PARC: El punto de vista del científico social:

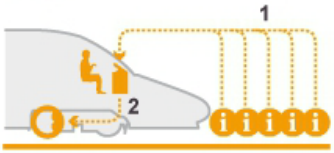


El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Ferrol descarriló en una curva a la entrada de Santiago de Compostela. 79 personas fallecieron y más de 130 resultaron heridas de diversa consideración. Iniciadas actuaciones penales, una de las cuestiones planteadas se relaciona con la posible responsabilidad –penal y civil– del maquinista del tren, pues el convoy entró en la curva a una velocidad a todas luces superior a la permitida. Pero la discusión sobre la arquitectura, sobre la infraestructura de seguridad del sistema ferroviario, emerge como otra de las cuestiones cruciales para analizar el caso. En el tramo accidentado, el sistema de seguridad instalado era el ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático – vídeo RENFE, 1983), menos avanzado que el ERTMS (European Rail Traffic Management System):



ERTMS (1.974 kilómetros instalados. Sólo en alta velocidad)

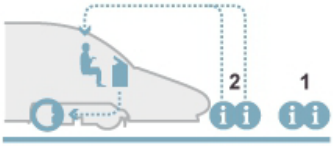
1. Comunicaciones e información del trayecto permanentes a lo largo de toda la ruta. En implantación a nivel europeo.



2. El ordenador actúa sobre el tren en el momento en que se supera la velocidad máxima establecida o rebasa señales que indican detención.

LZB (498 km. Sólo en alta velocidad)

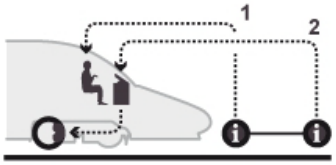
1. Trayecto dividido en cantones. Información cada 100 metros de la velocidad máxima que se puede desarrollar en cada punto del cantón.



2. El ordenador avisará al maquinista y frenará el tren si no actúa para llevar al tren a la velocidad permitida.

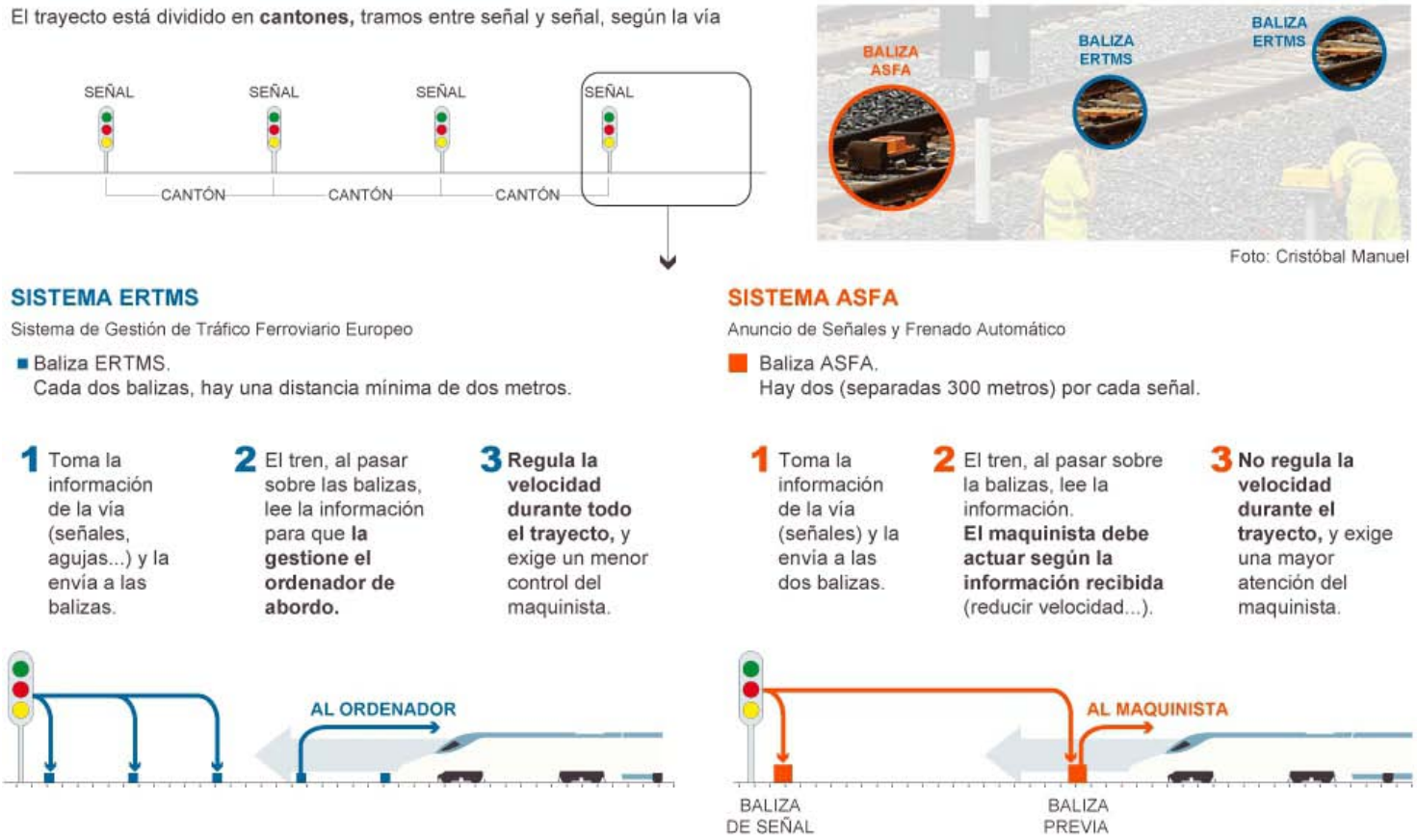
ASFA (instalado en toda la red, incluida la convencional. 13.398 km)

1. El maquinista debe actúar según la información que se recibe en cabina en puntos concretos del tramo.



2. Frenado automático si se rebasa una segunda baliza de información gemela, incumpliendo la limitación de parada o con velocidad superior a 200 km/h.

El País, 8.8.2013, http://elpais.com/elpais/2013/08/05/media/1375732774_197519.html



El País, 26.7.2013, http://elpais.com/elpais/2013/07/26/media/1374872840_505323.html

— Funcionamiento del sistema ASFA en el accidente de Santiago de Compostela: http://elpais.com/elpais/2013/08/08/media/1375970174_064671.html

Redacción legal: el punto de vista del escritor legal:

Distribuye el tiempo disponible para redactar tu discurso legal, de acuerdo con la siguiente regla de las cinco E's (PSC (1985)):

- ***Escucha***. Mucha gente no lo hace, sino que espera, ansiosa, su turno para hablar.

- ***Estudia***. Ni el mejor redactor legal está solo en el mundo -solo lo está ante la pantalla del dispositivo electrónico que está usando. Si el texto que vas a redactar es un examen escrito, las dos primeras E's pueden reducirse a una: antes de arrancar a escribir, asegúrate de que has entendido bien las cuestiones formuladas en el examen.

- ***Esquematiza***. Construye un esquema de tu discurso y hazlo por escrito. En derecho, IRAC es una buena manera de organizar los esquemas.

> En cuanto al contenido específicamente retórico de tu discurso, la organización triádica es clásica, pues permite exponer y defender tres ideas o reiterar una fundándola en tres razones distintas. Más de tres –sean ideas o razones- resulta arriesgado, pues casi nadie es capaz de recordar un discurso basado en cinco, seis o siete principios (prueba: defiendan los lectores una causa durante diez minutos y, al cabo, pidan a sus oyentes que resuman la intervención). Siguen tres

ejemplos de discursos clásicos, retóricamente logrados, todos ellos accesibles en la red: el primero es el de Steve Jobs, *How to Live Before You Die*, cuya estructura es claramente triádica, pero si consigues concebir y formular una buena y única idea el resultado puede ser histórico. Así, este año de 2013, hemos conmemorado el cincuentenario de la alocución, conocida como *"I have a dream",* de Martin Luther King, el 28 de agosto de 1963, un ejemplo legendario de un discurso centrado en un tema único, la igualdad racial. Mas, para un profesor veterano y, sobre tod, para un alumno listo, el *How schools kill creativity* de Ken Robinson es una de las dos o tres admoniciones de referencia. Los Lectores interesados en hacerse con una buena formación para abogar por las causas en las que crean harán bien en recurrir con cierta frecuencia a *TED Ideas worth spreading*.

- ***Escribe***. Al final, las palabras son el arma principal del abogado, del juez. Y un buen test para un Estado de derecho es calificar de 0 a 10 el grado de coherencia entre las palabras del juez y las razones auténticas de su decisión.

Un buen libro para aprender a escribir en derecho es el de Terrill POLLMAN, Judith M. STINSON, Richard K. NEUMANN, Jr., Elisabeth POLLMAN, *Legal Writing*, 1st edition, Wolters Kluwer, New York, 2011.

- ***Edita***. Dedica por lo menos una cuarta parte del tiempo de que dispones a editar el texto que acabas de redactar. Hay algunas buenas maneras de editar un texto: una, que no siempre es posible, es hacerlo editar por otra persona mayor o más joven que tú; otra, que lo hagas tú al día siguiente de haber redactado el primer borrador. Si, por fin, has de editar tu propio texto, concédete una pausa, por breve que sea, antes de empezar.

En cualquier caso, editar es siempre encoger el texto: córtalo sin piedad ni consideración alguna, que suelen ser demasiado largos, se repiten. "repetirse", en la frase anterior, reitera la idea de "ser demasiado largo", que podría no estar.

Las cinco reglas anteriores, las cinco E's ayudan a evitar errores. Hay una sexta que es solo para profesionales:

- ***¡Empieza de nuevo!***

¿Quién, tras volver a escribir de cabo a rabo el texto que había borrado sin querer de su dispositivo electrónico, no ha experimentado nunca la sensación de que el nuevo discurso es más claro y sencillo que el original?

1.2. La transversalidad del derecho de daños. Responsabilidad civil y responsabilidad civil derivada de delito o falta penales: atropello múltiple en la estación de ferrocarril de Castelldefels, Barcelona (23.6.2010)

Cuando se habla de responsabilidad civil de alguien, es decir, de la posible obligación de indemnizar puesta a cargo de quien ha causado un daño a otro, la primera intuïción legal es que sobre la cuestión resolverá un tribunal civil, de acuerdo con las regles, materiales y procesales, civiles.

No es así, pues el derecho de la responsabilidad civil es transversal, multijurisdiccional: sobre un mismo daño pueden conocer varias jurisdicciones en función del sujeto que lo causó, de las circunstancias que rodearon su causación.

En efecto, una característica singular del derecho español, comparada con otros ordenamientos jurídicos, es que la cuestión sobre la posible responsabilidad civil derivada de accidentes mortales o que causan lesiones corporales es resuelta habitualmente por tribunales penales, los cuales deciden sobre la responsabilidad propiamente penal, por delito o falta, y sobre la específicamente civil derivada de la anterior.

Si el tribunal penal archiva el caso o resuelve que no hay delito ni falta, normalment queda abierta a las víctimas o a sus allegados la posibilidad de iniciar un nuevo pleito y acudir a un tribunal civil, a la jurisdicción civil, en busca de un remedio indemnizatorio por los daños causados.

Esta singularidad del derecho español ha generado discusiones sin cuento entre quienes, por una parte, consideran que la atracción de las cuestiones de pura responsabilidad civil por la jurisdicción penal es una solución práctica que permite resolver en un solo litigio penal los temas civiles y penales cuestiones y quienes, por la otra, opinan que ventilar en un juicio penal los intereses puramente Civiles, además de los penales, distorsiona el proceso penal y el derecho penal mismo o que, en el caso de que haya que volver a litigar porque el tribunal penal descarte la existencia de una infracción penal, los pleitos se eternizan. De ello trataremos en varias de las Sesiones de este curso. Baste ahora con indicar que, para bien o para mal, este rasgo del derecho español caracteriza todo el derecho de daños. El caso que se plantea a continuación y que, en la fecha de cerrar esta edición, sigue planteado ante los tribunales, es un ejemplo también característico de lo anterior: más de tres años después del accidente, todavía se está discutiendo si el caso tiene relevancia penal o exclusivamente civil.

El 23.6.2010, a las 23:23 horas (vigilia de San Juan), en la estación de trenes de Rodalies (Cercanías) RENFE de Castelldefels Platja (Castelldefels, Barcelona), un convoy arrolló a un grupo numeroso de personas que, en aquellos momentos estaban cruzando las vías del ferrocarril. 12 personas fallecieron y 17 resultaron heridas de diversa consideración.

Las víctimas, viajeros de un tren de Cercanías que había llegado a la estación poco antes de que lo hiciera el convoy de media distancia que les arrolló, habían salido de sus vagones cerca de un paso subterráneo habilitado para pasar al otro lado del andén, pero se habían dirigido a una pasarela superior, más próxima a ellos y que era la antigua salida de la estación, que estaba inhabilitada y el paso cerrado por una cadena. Entonces algunos viajeros, en lugar de volver sobre sus pasos y cruzar por el paso subterráneo, resolvieron fatalmente saltar a las vías para cruzarlas y acceder a la playa.

Sigue una grabación extraída de un informativo que dio la noticia poco después del accidente: http://www.youtube.com/watch?v=_HSmGph9zrA

Como consecuencia del accidente, se iniciaron diligencias penales. El 30.6.2010, el Juez entonces encargado de la instrucción del caso dictó un auto por el que se acordó el sobreseimiento libre de las diligencias previas. Las acusaciones particulares interpusieron recurso de reforma y apelación contra dicho auto. Un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 10.1.2011, estimó el recurso, revocó el auto recurrido y ordenó la continuación de la instrucción a fin de practicar más diligencias. Las acusaciones particulares presentaron escrito en el que interesaban la imputación de las personas que ocupaban diversos cargos directivos en RENFE y ADIF en la fecha del accidente por 12 presuntos delitos o faltas de homicidio imprudente, así como por 17 delitos o faltas de lesiones imprudentes, a título de comisión por omisión. El Ministerio Fiscal, ADIF y RENFE se opusieron a lo interesado y presentaron escritos de alegación.

El AJPII nº1 Gavà, de 30.5.2012, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas (art. 641.1 LECrim) por "no darse (…) los requisitos que los tipos imprudentes exigen para apreciar su existencia" (FD 2.8) puesto que, "[d]el análisis de las actuaciones obrantes en autos no resulta la existencia de incumplimiento sustancial de la reglamentación y de las normas de cuidado a observar en el ámbito del tráfico ferroviario que permita afirmar la existencia de omisión de un deber de cuidado punible en la esfera penal" (FD 2.1).

En concreto, la Juez consideró probado que

a) "[E]l estado de mantenimiento técnico del tren (…) implicado en el siniestro [era] adecuado" (FD 2.2).

b) [E]l maquinista (…) cumplió en su conducción con todas las exigencias normativas al respecto" (circulación dentro de los límites de velocidad, llevaba encendidas las luces reglamentarias al momento de entrar en la estación, instante en que también accionó el claxon, y el resultado de las pruebas de alcoholemia resultó negativo) (FD 2.2).

c) [E]l apeadero de Castelldefels cumplía "los requisitos de seguridad y accesibilidad exigidos normativamente" (en concreto, había sido reformado en 2009 para adaptarse a las exigencias del RD 1544/2007, de manera que el cruce de pasajeros de un andén al otro mediante una pasarela superior fue sustituido por un paso subterráneo) (FD 2.3). Y,

d) "[L]as condiciones que en particular presentaba el apeadero en el momento de los hechos" eran igualmente adecuadas (iluminación suficiente, paso subterráneo accesible, "sin ningún obstáculo", y –extraordinariamente, por la mayor afluencia de personas en el apeadero con motivo de la noche de San Juan– tornos de salida de la estación abiertos, así como también los portones situados al lado de dichos tornos) (FD 2.3).

Finalmente, la Juez del caso afirmó: "[N]o era previsible (…) que los pasajeros del tren de cercanías, incurriendo en una notoria negligencia y prescindiendo de las más elementales normas de cuidado, incumpliendo con lo previsto en la normativa aplicable, decidieran, sin buscar el paso habilitado al efecto [ya que "desde que el tren de cercanías abandonó la estación hasta que se produjo la entrada en el mismo del tren causante del siniestro transcurrieron únicamente 15 segundos"], pasar al otro andén cruzando directamente las vías, sin prever que por las mismas se podría acercar otro tren (…) (FD 2.6). "Siendo tal decisión de todo punto imprevisible", sus efectos "no [son] imputable[s] a las personas respecto de las cuales se pretende su imputación por las acusaciones particulares" (FD 2.7).

El auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14.5.2013 revocó la anterior interlocutoria al considerar que los peritos que fueron escuchados en sede policial deben ratificarse a presencia de las partes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Gavà. Sin embargo, en contra del *petitum* de los recurrentes, la AP Barcelona no ordenó practicar nuevas diligencias sobre el accidente ferroviario.

A continuación, se reproducen tres fotografías de la estación de Castelldefells Playa, donde ocurrió el accidente y otras tres de dos estaciones de ferrocarril suizas, Grindelwald e Interlaken-Ost. En las estaciones secundarias de la Confederación Helvética es frecuente que no haya ni pasos elevados ni subterráneos: los pasajeros esperan a que el empleado del ferrocarril que viaja con ellos en cada tren les indique el momento apropiado para cruzar los andenes.

Estación de ferrocarrils de Castelldefels

Der Bahnhof Grindelwald

Der Bahnhof Interlaken-Ost

El contraste entre España y Suiza sugiere una reflexión sobre los comportamientos apropiados en derecho: en ambos países, la gente, las infraestructuras (la arquitectura) y las normas (la cultura) son distintas y, por lo tanto, las reglas de derecho más apropiadas para evitar accidentes, reducir su número y disminuir su gravedad pueden analizarse habida cuenta de su interacción con aquellas.

La modificación de las reglas de derecho o de su interpretación razonablemente posible pueden producir modificaciones en la arquitectura o infraestructura, en el sistema de normas culturales o en el comportamiento de las gentes, o pueden hacer en distinta medida en cada caso.

La decisión infraestructural sobre qué efecto es preferible –estaciones como la española o como las suizas, por ejemplo- no es autoevidente. Así, un factor muy relevante puede ser la velocidad del convoy de largo recorrido que circula por vías que cuentan con estaciones secundarias a más de cien km/h y que, por lo tanto, no puede detenerse si una persona invade indebidamente la vía del tren.

Dos casos recientes:

- El 23 de noviembre de 2012, un hombre de 67 años de edad, que atravesaba las vías del ferrocarril en la estación de Salou, Tarragona y por un paso a nivel que tenía las barreras bajadas, fue arrollado por un tren Euromed que circulaba a 140 km/hora y que no tenía parada en aquella estación. Puede muy bien pensarse que la infraestructura era deficiente. También que el peligro lo era muy manifiestamente y que la manera más sencilla de evitarlo es abstenerse de cruzar la vía cuando las barreras están bajadas.
- La madrugada del sábado 24 de agosto de 2013, una chica de 16 años fue arrollada por un tren de mercancías a su paso por Ascó (Tarragona). Murió en el acto. Las vías del ferrocarril (línea Reus-Zaragoza) se encontraban junto a la plaza donde se desarrolló el festival de música, pintura y agua al que asistía la fallecida durante la fiesta mayor de la población. El Ayuntamiento había instalado un frente de vallas metálicas para impedir el acceso a las vías, aunque aquella noche muchos jóvenes las cruzaron presumiblemente para ahorrarse tener que ir a los servicios instalados en el otro extremo de la plaza que acogía el concierto.

1.3. Accidente de ferrocarril

STS, 1ª, 44/2010, de 18 de febrero:

El 19 de marzo de 1994, dos menores, de 15 y 16 años de edad, circulaban en un ciclomotor de una sola plaza. Su conductor, quien carecía de permiso de conducir, cruzó la vía del tren por un paso a nivel sin barreras ni semáforos en A Rúa (Padrón, A Coruña) y un tren arrolló a ambos muchachos matándoles en el acto. A un lado del paso, había una señal descolorida de paso a nivel. Al otro, un poste de unos dos metros de altura con señales de atención al tren. En ninguno había señal, preceptiva, de stop. Los dos menores eran vecinos del lugar y conocían el paso a nivel. En el momento del accidente el tren circulaba a 98 km/hora, la velocidad máxima permitida era de 100 km/hora y el convoy era visible, aproximadamente, a un kilómetro de distancia del lugar del accidente en línea recta. A unos 600 m. de distancia del paso a nivel existía la señal reglamentaria que ordena "silbar".

Los padres y el hermano, respectivamente, de los dos fallecidos interpusieron sendas demandas contra Renfe y el maquinista del tren. Los padres y hermano de una de las víctimas solicitaron que:

> "[S]e declar[ara] la obligación de [Renfe] de dotar al paso a nivel e inmediaciones… de las medidas de seguridad, protección y advertencia a los usuarios…, necesarias para evitar riesgos en las personas y en las cosas, atendiendo a las circunstancias de la zona y en particular el cercamiento de la vía al paso por la población y dotación de barreras o mecanismos de obligada detención de vehículos y personas …". Y
>
> Se conden[ara] a los demandados a pagar 90.361,45 euros a cada uno de los padres del fallecido y 60.240,96 euros al hermano, así como 553,48 euros por gastos funerarios. Los padres y el hermano de la otra víctima solicitaron una indemnización de 132.530,12 euros por el fallecimiento del menor, de 90.361,45 euros por daño moral y de 1.826,55 euros por gastos funerarios.

El JPI estimó sustancialmente la primera demanda: condenó a Renfe a "dotar el paso a nivel e inmediaciones sito en A Rua de las medidas de seguridad, protección y advertencia que sean necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas" y condenó a ambos demandados a pagar, en concepto de daño moral, 144.821,15 euros a los padres, 18.807,93 euros al hermano, ambas cantidades en concepto de daño moral, así como la cuantía reclamada por gastos funerarios. Asimismo, el JPI estimó sustancialmente la segunda demanda y condenó a ambos demandados a pagar las mismas cantidades en concepto de daño moral y la cuantía reclamada por gastos funerarios.

La Audiencia Provincial (AP) de A Coruña estimó el recurso de apelación de Renfe, revocó la SJPI y desestimó ambas demandas. Extractamos los fundamentos de su resolución (e introducimos algunos cambios en la puntuación para separar los párrafos):

"[L]a causa del accidente fue el grave descuido de las víctimas, que, con infracción de todas las normas de la prudencia y de la circulación viaria, se metieron literalmente debajo del tren; descuido relativamente explicable por la edad juvenil, pero no por ello prescindible e intrascendente cuando de la aplicación del Derecho se trata.

Pero ha sido objeto también de debate otra interesante cuestión: si existe responsabilidad de Renfe por no haber abordado ya la supresión de ese concreto paso a nivel, o, al menos, su reordenación para dotarlo de mejores medios de seguridad, como barreras o semibarreras. Es claro que la actual red viaria, con la existencia de pasos a nivel para cruzar la línea férrea, deriva de razones que en tiempos pretéritos los hicieron necesarios; sin que creasen tan elevado riesgo como en la actualidad, al haber aumentado tanto la circulación de vehículos a motor que se ven obligados a cruzar por ellos. Pero en los tiempos presentes, con medios técnicos muy superiores, se ha impuesto la política conducente a la eliminación de tan peligrosos obstáculos viarios, que por unas u otras razones se han cobrado muchas vidas, como en el caso que nos ocupa.

Responde a tal criterio el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real Decreto 1211/90, de 28 setiembre), que en su artículo 235 contempla tanto lo relativo a nuevos pasos a nivel, que solo permite con carácter excepcional y por causas absolutamente justificadas, como la supresión de los actuales o en otro caso, para los subsistentes, la adopción de sistemas de seguridad y señalización más eficaces.

Pero es de advertir que el accidente ocurrió el 19 de marzo de 1994, y que por ello el texto vigente era la primera redacción del artículo 235. A tenor de ella, en su apartado 4, "Los pasos a nivel que resulten subsistentes deberán contar con los sistemas de seguridad y señalización adecuados para garantizar su seguridad que, a tal efecto, se determinen por los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y de Transportes, Turismo y Comunicaciones".

Pues bien, estos sistemas de seguridad no se determinaron ministerialmente hasta la Orden de 1 de diciembre de 1994 (BOE de 14 del mismo mes), varios meses después de haber ocurrido el accidente objeto de este litigio. En ella se disponen las medidas de seguridad correspondientes a un paso a nivel como el de esta *litis*, que se califica de clase A, en el que ha de procederse a la instalación de la señalización que allí se hace constar (artículos 8 y 9).

No cabría, pues, imputar a RENFE un retraso o dejadez en la aplicación de medidas de seguridad que se anunciaban en el Decreto de 1990, con remisión a lo que dispusiesen los Ministerios competentes, y que no se concretaron hasta después de ocurrido el accidente. Pero ha de tenerse muy en cuenta respecto a las medidas de señalización a instalar en la carretera o camino, que la norma, que se remite a las del Reglamento General de Circulación ya aludidas, al igual que éste, responsabiliza de aquéllas al titular de tales vías (disposición adicional sexta). [E]s lo que ya establecía la Orden de 8 de mayo de 1982, vigente cuando el desdichado accidente ocurrió ... A RENFE solo correspondía entonces y ahora la señalización establecida para la vía férrea" (FD. 4º).

Los actores de la primera demanda interpusieron recurso de casación que el TS desestimó:

"La "defectuosa señalización" del paso a nivel, admitida por la AP, no desempeñó papel relevante alguno en la determinación del nexo de causalidad, sino que, en expresión de la sentencia recurrida, la causa del accidente estuvo en "el grave descuido de las víctimas, que, con infracción de todas las normas de la prudencia y de la circulación viaria, se metieron literalmente debajo del tren" (FD. 3º).

En *"Trenes"*(InDret 1/2000, www.indret.com), un artículo publicado en el año 2000, Carlos Gómez Ligüerre y Pablo Salvador Coderch analizaron la jurisprudencia española de la época sobre responsabilidad civil por accidentes ferroviarios en pasos a nivel y a la luz de la

experiencia histórica norteamericana, es decir, a la de una cultura industrial más antigua y más avanzada tecnológicamente que la española. En el artículo, se rememoraba el intento lúcido, brillante, finalmente fallido, de William Wendell Holmes, Jr., un magistrado legendario, de establecer una única regla para resolver todos los casos de arrollamiento en pasos a nivel sin barreras. A principios del siglo XX, Holmes propuso que, ante un paso a nivel, los conductores de automóviles habían de detener sus vehículos, salir de ellos, mirar a uno y a otro lado de las vías y escuchar si se acercaba algún tren (***"Stop, look and listen"***). De no haber adoptado tales precauciones, opinaba, las víctimas o sus sucesores no podrían reclamar nada por el accidente sufrido. La historia, contada en *Trenes*, enseña que la regla duró pocos años y que, al cabo, los tribunales norteamericanos hubieron de recurrir a criterios mucho más matizados y apegados a las circunstancias de cada caso. Probablemente, lo mismo habrá sucedido con las propuestas sobre precauciones exigibles que Gómez y Salvador formularon hace trece años en su artículo. Los estándares de responsabilidad civil cambian con el tiempo y este solo respeta aquello que ha creado.

2. Fuentes primarias y secundarias/ *Primary and Secondary Sources*

En responsabilidad civil, la ley –desarrollada por los reglamentos- y la jurisprudencia establecen los casos y circunstancias en los cuales el demandado habrá de ser condenado civilmente a reparar los daños derivados de un suceso o acontecimiento dañoso que no debería haber ocurrido, que ha causado el demandado mismo y que el derecho establece que ha de ser puesto a su cargo.

Es muy difícil ofrecer una definición de la responsabilidad civil que sea, a la vez, omnicomprensiva, operativa y fecunda.

Véanse las dos siguientes, tomadas, respectivamente, de un libro clásico español y de otro norteamericano:

"Responsabilidad civil es imputación (...) La responsabilidad civil por daños extracontractuales [refiere a] los presupuestos, condiciones, y circunstancias por las que una persona que ha sufrido un daño jurídicamente tutelable como consecuencia de la conducta o actividad de un tercero tiene derecho a exigir su reparación a ese tercero o a otra persona que se encuentre con él en una determinada relación" (Fernando Reglero Campos, *Tratado de Responsabilidad Civil*, Aranzadi, 2002).

"A tort is a conduct that amounts to a legal wrong and that causes harm for which courts will impose civil liability" (Dan Dobbs, *The Law of Torts,* West, 2000)**.**

2.1. Legislación / *Statutes*

Muchas disposiciones del derecho español (civil, penal, administrativo y laboral) establecen supuestos de responsabilidad civil o, más generalmente, de responsabilidad extracontractual. Las principales están en los artículos de los textos legales que se citan a continuación:

— 1902-1910 del Código Civil de 1889.
— 109-125 del Código Penal de 1995.
— 139-146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
— 42-54 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
— 128 y ss. RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
— 123 del RDL 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Algunas observaciones preliminares:

En primer lugar y como ya hemos señalado, algunas de las disposiciones citadas se encuentran en leyes civiles aplicadas por tribunales civiles; otras están residenciadas en leyes penales y son aplicadas por tribunales también penales; unas terceras son administrativas y su conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y, por fin, algunas son laborales y los casos que plantean son competencia de la jurisdicción social. La primera característica procesal de la responsabilidad civil es, pues, su naturaleza multijurisdiccional, que trataremos en capítulos posteriores.

En segundo lugar, buena parte de las disposiciones citadas son principios (*standards*), no reglas (*rules*) de derecho. Sobre la distinción entre ambos, véase Ward Farnsworth, *The Legal Analyst. A Toolkit for Thinking About the Law*,The University of Chicago Press, 2007, pp. 163-171: para aplicar una regla, basta con conocer los hechos que describe su supuesto de hecho. En cambio, la apreciación de un principio exige siempre la formulación de un juicio de valor. Así, por ejemplo, conducir un automóvil a más de sesenta kilómetros por hora es una simple cuestión de hecho; conducir negligentemente es, además, una cuestión valorativa, normativa. La primera circunstancia puede integrar una regla; la segunda, un principio.

Luego, en tercer lugar, hoy en día, la ley y los reglamentos, el derecho legislado y regulatorio, ocupan un lugar creciente en la prevención de los accidentes y en la resolución de los conflictos a que su ocurrencia da lugar. Aquí es importante destacar las diferencias básicas entre el derecho regulatorio de los accidentes, establecido por el Parlamento, por el gobierno o por la agencia reguladora con potestad reglamentaria, por una parte, y el derecho de daños creado y desarrollado por los tribunales, por la otra, el *case law*:

> —El derecho regulatorio mira al futuro, se establece *ex ante*. En cambio, el derecho judicial de daños mira al pasado, se decide *ex post*.
> —El derecho regulatorio suele ser detallado –y cada vez lo es más-. Es un conjunto de reglas, no de principios o no solo de ellos. En cambio, la mayor parte del derecho de daños parte de principios o estándares que los tribunales concretan de modo mucho más fluido y, muchas veces, de modo intersticial.

Entonces y en cuarto lugar, una pregunta capital del moderno derecho de daños es si la regulación detallada de un sector de actividad cierra o clausura el sistema de modo tal que excluya toda pretensión adicional por derecho de daños o si, por el contrario, el demandante puede ejercitar una pretensión de responsabilidad civil además de los remedios previstos por la regulación específica del caso: es el tema de la "*preemption*", de la cuestión de si el derecho regulatorio cierra o no el paso a ulteriores reclamaciones por responsabilidad civil.

Un ejemplo: ¿cierra la regulación vigente en España sobre la disolución del matrimonio y sus consecuencias la posibilidad de que uno de los cónyuges ejercite una pretensión de responsabilidad civil contra el otro y en cuyo fundamento alegue los daños morales que, presuntamente, le ha causado la infidelidad del demandado?

2.2. Jurisprudencia / *Case-law*

En España, el derecho de daños es fundamentalmente jurisprudencial, *case-law*. Y lo es, porque, como ya hemos indicado, las disposiciones más importantes sobre la materia del derecho legislado son principios o estándares, no reglas. Así, dos fuentes positivas básicas del derecho español de daños --el art. 1902 del Código Civil de 1889 y el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común— se formulan como principios. Su concreción y desarrollo se dejan a la jurisprudencia y esta ha venido decidiendo constelaciones de casos que, muy aproximadamente, van delimitando poco a poco grupos de supuestos análogos de responsabilidad civil, las llamadas -mal- "constelaciones de casos".

Tales grupos de supuestos van cambiando con el paso del tiempo y las circunstancias -a diferencia de las auténticas constelaciones, que están fijas en el firmamento- como hemos visto que ocurre en los casos de accidentes de ferrocarril. El jurista que trabaja la interpretación del derecho a partir del estado de los conocimientos científicos y técnicos puede ofrecer criterios razonables sobre el sentido de las resoluciones que propugna. Sin embargo, no existe ninguna teoría que permita predecir y explicar la dinámica del derecho de daños y no existe por la misma razón por la cual no hay una ciencia de la Historia que nos permita predecir y explicar el devenir de una colectividad. Pero la razonabilidad del jurista es crucial a la hora de decidir, de nuevo por ejemplo, casos de accidentes de ferrocarril, si queremos encaminar a la colectividad hacia Castelldefells, o hacia Grindelwald o Interlaken. Siempre es importante que el jurista sepa hacer llegar a los tribunales y la colectividad misma el sentido último, las consecuencias de las decisiones que vayan a adoptar.

En derecho español, la Jurisprudencia en sentido estricto es solo la establecida por el Tribunal Supremo y, más concretamente, por cada una de sus Salas en asuntos de su competencia (*Spanish Supreme Court's Case-law*), pero la denominada jurisprudencia menor, las sentencias de las Audiencias Provinciales (*Spanish Courts of Appeals' Case-law*) son cada vez más importantes: en la actualidad, conocer cómo deciden las Audiencias las distintas constelaciones de casos es imprescindible en la buena práctica de cualquier abogado especializado en responsabilidad civil.

Dos buenas bases de datos de consulta:
— Westlaw Aranzadi (www.upf.edu/bibtic/recursos/bd/bd-a.html)
— CGPJ – CENDOJ (www.poderjudicial.es/jurisprudencia)

El equipo de investigadores que, en 1999, fundó InDret mantiene al día una selección de sentencias del Tribunal Supremo español sobre responsabilidad civil de los últimos años. Su contenido integra las páginas de este curso y ofrece un panorama de la jurisprudencia española reciente:

Pablo SALVADOR CODERCH y Sonia RAMOS GONZÁLEZ (Coords.), Laura ALASCIO CARRASCO, Laura ALLUEVA AZNAR, Luca BIFFARO, Esther FARNÓS AMORÓS, Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, Ignacio MARÍN GARCÍA, Rosa MILÀ RAFEL, Sergi MORALES MARTÍNEZ, Magalí RIERA ROCA, Carlos Alb. RUIZ GARCÍA y Antoni TERRA IBÁÑEZ, "120 casos de derecho de daños (2004-2011)", *InDret* 4/2012 (http://www.indret.com/pdf/939.es.pdf).

2.3. Doctrina / *Secondary Literature or Secondary Sources*

Hay muchos buenos tratados, comentarios, monografías y artículos sobre responsabilidad civil. Los autores de este e-libro hemos seleccionado los siguientes, la mayor parte de los cuales versan sobre el derecho español, pero no todos, como los lectores comprobarán:

— Hugo ACCIARRI, *Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños*, 1ª ed., Asociación latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía (ALACDE) & George Mason University, Law & Economics Center, Berkeley, California, 2009. Junto con el libro de Bullard, dos de las más brillantes referencias latinoamericanas, utilísimas y usadas en las mejores universidades del cono sur por quienes ya son estudiantes de excelencia mundial.
— Mario BARCELLONA, *Trattato della Responsabilità Civile*, Ed. Utet, 2011. Tratado italiano de referencia.
— Alfredo BULLARD, *Derecho y Economía. El Análisis Económico de las Instituciones Legales*, 2ª ed., Palestra Editores, Lima, 2006. Síntesis académica y profesional de primer nivel.
— José Manuel BUSTO LAGO/L. Fernando REGLERO CAMPOS (Coords.), *Lecciones de responsabilidad civil*, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2013. La puesta al día de un manual de referencia.
— Ana CAÑIZARES LASO/Pedro DE PABLO CONTRERAS/Javier ORDUÑA MORENO/Rosario VALPUESTA FERNÁNDEZ (Dirs.), *Código civil comentado*, Vol. 4, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur

Menor, 2011 (Javier PLAZA PENADÉS, "Comentario al art. 1902", pp. 1454-1464; y Esther GÓMEZ CALLE, "Comentario al art. 1903", pp. 1464-1476). El otro.

— Robert D. COOTER/Thomas ULEN, *Law and Economics,* 6th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2011. Presentación asequible, muy meditada y muy bien escrita: una excelente introducción para estudiantes que no cursen doble grado.
— DEUTSCH/AHRENS, *Deliktsrecht*, 5. Aufl, Verlag Carl Heymanns Verlag, 2009. Buen libro de introdución.
— Ricardo DE ÁNGEL YÁGÜEZ, *Tratado de responsabilidad civil*, 3ª ed., Universidad de Deusto, Civitas, Bilbao, Madrid, 1993. La visión del abogado.
— Simon DEAKIN, Angus JOHNSTON, Basil MARKESINIS, *Markesinis and Deakins' Tort Law*, 6th ed., Oxford University Press, Oxford, 2007. Obra británica de referencia.
— Luis DÍEZ-PICAZO, *Fundamentos de derecho civil patrimonial*, Tomo V, 1ª ed. Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011. Referencia española: da razón del pensamiento dominante.
— Richard A. EPSTEIN/Catherine M. SHARKEY, *Cases and Materials on Torts*, 10th edition, Aspen Publishers, 2012. La experiencia (Richard Epstein) se encuentra con la juventud (Caty Sharkey) en la universidad actualmente más potente en análisis académico del derecho de daños.
— Michael FAURE, *Tort Law and Economics* (*Encyclopedia of Law and Economics*, Vol. 1, 2nd edition), Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) – Northampton, Massachussetts (USA), 2009. La enciclopedia.
— Massimo FRANZONI (Dir.), *Trattato della Responsabilità Civile* (Vol. 1: *L'illecito*, Vol 2: *Il danno risarcibile*), 2ª ed., Dott. A. Giuffrè – Editore, Milano, 2010. Otro tratado italiano de referencia.
— James A. HENDERSON/Richard N. PEARSON/Douglas A. KYSAR/John A. SICILIANO, *The Tort Process*, 7th edition, Aspen Publishers, New York, 2007. Tres generaciones de académicos de primer nivel se concitan para producir un *case-book* extraordinario
— Mariano José HERRADOR GUARDIA (Dir.), *Derecho de daños*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013. Las actas de un congreso de primeros especialistas en la materia.
— InDret. Revista para el análisis del derecho: www.indret.com. El origen de todo esto. Un producto muy costoso, acaso de algún valor y –para sus lectores- gratis. Editado y escrito por tres generaciones de civilistas.
— Hein KÖTZ/Gerhard WAGNER, *Deliktsrecht*, 11., neu bearbeitete Auflage, Verlag Vahlen, München, 2010. El mejor puente entre el derecho alemán, el *common law* y el moderno análisis del derecho de daños, escrito por dos especialistas de primer nivel y de distintas generaciones, un clásico. Comparte con los *case-books* angloamericanos un lenguaje admirable, pues está muy bien escrito.
— José Luis LACRUZ BERDEJO et. al., *Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones,* Vol. 2º, Contratos y Cuasicontratos. Delito y cuasidelito. 4ª ed., Dykinson, Madrid, 2009. Manual español de referencia.
— Ángel LÓPEZ LÓPEZ/M. Rosario VALPUESTA FERNÁNDEZ, *Tratado jurisprudencial de responsabilidad por daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
— Miquel MARTÍN-CASALS, La "modernización" del Derecho de la responsabilidad extracontractual", XV Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, http://www.derechocivil.net/jornadas/APDC-2011-PONENCIA-CASALS.pdf, 2011. La visión del primer comparatista español.
— Thomas J. MICELI, *The Economic Approach to Law*, 2nd edition, Stanford University Press, Stanford, 2008 (óptima introducción analítica, indicada para estudiantes de doble grado).
— *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch* (Band 5: *Schuldrecht - Besonderer Teil III §§ 705 – 853, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, Produkthaftungsgesetz*), 5. Auflage, C.H. Beck, 2009. Presentación clásica, panorama para práctica y academia.
— Fernando PANTALEÓN PRIETO, "Comentario al artículo 1902 CC", en Cándido PAZ-ARES, Luis DÍEZ-PICAZO, Rodrigo BERCOVITZ, Pablo SALVADOR, *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1993, pp. 1971-2003. Los años transcurridos desde su publicación revalidan el comentario como la referencia clásica del derecho español de la negligencia.
— Fernando PEÑA LÓPEZ, "Comentario a los arts. 1902 a 1910 CC", en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios al Código Civil*, 3ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009, pp. 2153-2171. Uno de los dos mejores comentarios globales al código civil español.

— L. Fernando REGLERO CAMPOS (Coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 4ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2008. El testamento de un gran profesor, prematuramente desaparecido.
— Encarna ROCA TRÍAS/Mónica NAVARRO MICHEL, *Derecho de daños. Textos y materiales*, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. La voz de profesoras de dos generaciones, una de ellas magistrada del Tribunal Supremo y, desde 2011, del Tribunal Constitucional.
— SCHWARZ/WANDT, *Gesetzliche Schuldverhältnisse – Deliktsrecht, Shadensrecht, Bereicherungsrecht, GoA*, 4. Auflage, Verlag Vahlen, 2011. Imprescindible para la formación de un académico versado en *Civil Law*: el derecho de daños en la primera potencia industrial y exportadora de Europa, un país cuyos sectores de actividad están intensamente regulados y que no se puede permitir inseguridad jurídica ni incertezas de ningún tipo a la hora de delimitar las incumbencias de cada persona u organización en el marco de una división extrema y excelente del trabajo.
— Steven SHAVELL, *Foundations of Economic Analysis of Law*, 1st edition, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2004. Paradigma implacablemente neoclásico del análisis económico del derecho, sin casos.
— Geneviève VINEY, Patrice JOURDAIN, *Introduction a la responsabilité* (2008), *Les conditions de la responsabilité* (2006), *Les effets de la responsabilité* (2011), 3ème éd. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), (Collection Jacques GHESTIN [Dir.], *Traité de droit civil*). Manuales franceses de referencia, muy influyentes, como todo lo francés, en nuestra cultura.

3. Análisis económico del derecho / *Law and Economics*

La economía, la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios (Paul KRUGMAN/Robin WELLS), puede aplicarse con buenos frutos al análisis del derecho –como también pueden serlo la psicología, la ciencia política o la sociología- y, durante el último medio siglo, lo ha sido con mucho éxito y algunos fracasos -notablemente, algunos excesos-.

El análisis económico del derecho puede ser positivo o normativo.

El análisis positivo pregunta sobre las consecuencias económicas del establecimiento y aplicación de una regulación determinada, por ejemplo, ¿qué efectos tendría establecer una regla general de defecto en cuya virtud la velocidad máxima de circulación de vehículos a motor en las vías urbanas no debe superar los treinta kilómetros por hora?

El análisis normativo pregunta sobre cuál es la mejor regla, de entre varias reales o posibles, en términos de eficiencia económica y, por ello, de entre las distintas alternativas razonablemente posibles en términos de limitación de velocidad en vías urbanas, considera preferible aquella que resulte más eficiente en términos de costes y beneficios sociales.

El análisis económico, aplicado al derecho de daños, al derecho de accidentes abordado con las técnicas de la responsabilidad civil, parte de considerar las consecuencias probables, positivas y negativas, de las distintas actividades sociales cuyo desarrollo genera accidentes.

Thomas J. MICELI (*The Economic Approach to Law*, 2nd edition, Stanford University Press, Stanford, 2008), uno de los mejores analistas económicos del derecho, señala que el riesgo de causar algún daño es el subproducto inevitable de muchas –si no de todas- las actividades sociales globalmente beneficiosas. Y aunque, escribe, normalmente no podemos eliminar el riesgo sin suprimir de raíz la actividad de que se trate, deberíamos adoptar todas las medidas, justificadas en términos de costes y beneficios, para minimizar el riesgo: deberíamos, pues, invertir en reducción de riesgos cantidades crecientes de recursos hasta el punto en que un euro adicional empleado en evitar pérdidas derivadas de los accidentes solo consigue impedir accidentes estimados justamente en otro euro.

Toda sociedad avanzada dispone de muchos medios distintos -jurídicos y no jurídicos- para controlar los riesgos derivados de las actividades peligrosas –de casi todas-, pues, además de la

responsabilidad civil, tales actividades pueden estar sujetas a regulaciones de seguridad, a impuestos, al derecho administrativo o, incluso, al derecho penal, además de estarlo a medidas físicas de seguridad o a tradiciones educativas y cívicas que nada tienen que ver con el derecho.

En todo caso, la esencia de la responsabilidad civil es la obligación potencial, asumida por el demandado, de reparar los daños causados a la víctima de un accidente y que esta -o un allegado suyo, si la víctima falleció- reclama ante un tribunal de justicia.

4. Concepto y clases de accidente, y limitaciones del derecho de daños. La minimización de los costes sociales de los accidentes

4.1. Concepto y clases de accidente

Accidente: suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas (DRAE).

Accident: *a mishap, a mischance, especially one causing injury or death* (Collins English Dictionary).

Clases de accidentes: la implosión de la distinción entre accidentes naturales y accidentes causados por conductas humanas

Tradicionalmente los accidentes pueden ser naturales o causados (o cocausados) por una conducta humana, individual o colectiva.

Ejemplos de accidentes naturales (*natural accidents, acts of God*) son los terremotos, como los de Haití y Chile, de 2010, o los maremotos (*tsunami*), como el de Japón en 2011. También los huracanes, ciclones, tormentas, inundaciones, incendios de origen natural. Los accidentes naturales no siempre son acontecimientos discretos, sino que, en ocasiones, son fenómenos que tienen lugar muy lentamente y cuyos efectos se manifiestan a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo: así los denominados *Medieval Warm Period (950-1250*) o *The Little Ice Age, 16th-19th centuries.* Pero en estos últimos casos, la noción de accidente se difumina hasta desaparecer. Además, no todos los accidentes naturales son catastróficos (Pablo SALVADOR CODERCH/Sonia RAMOS GONZÁLEZ/Rosa MILÀ RAFEL, "Catastrophic Damages: Liability and Insurance", in Karen B. BROWN/David V. SNYDER [Eds.], *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law*, 1st edition, Springer, New York, 2012, p. 85-103, esp. 90), sino que muchos de ellos dañan únicamente a una o a muy pocas víctimas, como la caída de un rayo o de un árbol.

Los accidentes causados por una conducta humana (*caused by human agency*) son los causados o agravados por conductas humanas, tales como los de trabajo, los de tráfico, los iatrogénicos, los domésticos.

La distinción entre accidentes naturales y accidentes causados por los seres humanos está en crisis: 2008 fue el año en el cual, por primera vez en la historia de la Humanidad, más habitantes de la Tierra vivían en ciudades que en el campo. Ciertamente, el campo es una idealización que, al menos desde la Revolución Neolítica, desde la última glaciación, hace 10.000 años, cada vez ha tenido menos que ver con la naturaleza, con el mundo silvestre, no humanizado. Tanto es así que, para muchos geólogos –rendidos a la geografía, una ciencia humana-, ya no vivimos en el Holoceno, la fase del Cuaternario posterior a la última Glaciación, sino que hemos entrado en, el Antropoceno, en la Era del Hombre (Paul Crutzen y Eugene Stoermer).

Así, el terremoto de Haití, de 12 de enero de 2010, mató quizás a 200.000 personas, pero el poco posterior de Chile, de 27 de febrero de 2010, de mayor intensidad, a menos de 600: Chile estaba mucho mejor preparado que Haití para soportar la catástrofe.

El Tsunami de Japón, de 11 de marzo de 2011, mató a casi 16.000 personas, pero su consecuencia más destacada culturalmente fue su efecto sobre la central nuclear de Fukushima Daiichi y sobre la política energética mundial de una generación.

Para muchas personas, los accidentes naturales no existen. No es así, pero el jurista hará bien en apuntar a las posibilidades que la ciencia y la técnica ponen a nuestra disposición para prevenir un accidente y los costes de todo tipo de la prevención. Un ejemplo de libro es la susceptibilidad de algunas localidades del Sureste español a un terremoto: sabemos que se producirá, pero no estamos en condiciones de decir cuándo (véase la web del Servicio de Información Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento).

4.2. Algunas limitaciones del derecho privado de daños

Otras distinciones en crisis son las que dividen al mundo en sistemas nacionales de derecho. Desde 2009, se discute sobre el concepto de límites, linderos o fronteras ecológicos del planeta (*environmental boundaries of the world*) que se construye sobre nueve categorías de problemas, algunas de las cuales, al menos, no reconocen fronteras políticas ni, por tanto, sistemas nacionales de derecho (cambio climático, acidificación de los océanos, desaparición de la capa de ozono, intervención en el ciclo del nitrógeno, roturación y urbanización crecientes, extinción, incremento de los polucionantes químicos y su creciente concentración en la atmósfera, difusión de transgénicos, etc.). Algunas de estas fronteras no son globales, pero otras lo son y todas obligan a poner de manifiesto las limitaciones del derecho de daños como derecho de los accidentes: tratados internacionales, políticas mundiales, derecho público y regulatorio, derecho sancionador, impulso del desarrollo tecnológico son instrumentos aparentemente más eficaces para afrontar los retos del Antropoceno que el viejo derecho nacional de daños.

Sin embargo, el derecho de daños juega un rol esencial en tanto en cuanto constituye un instrumento de cambio del derecho mismo de los accidentes, es un motor de su dinámica: típicamente, los nuevos supuestos de responsabilidad civil impulsan cambios de legislación, las iniciativas descentralizadas de los abogados especializados en responsabilidad civil anuncian con frecuencia los cambios que han de llegar.

Así, los derechos de daños son fundamentalmente nacionales, pertenecen a sistemas estatales de derecho –aunque haya macrosistemas regionales armonizados de derecho de daños, como sucede con el derecho europeo de la responsabilidad civil del fabricante--.

Los sistemas de derecho de daños están caracterizados por rasgos comunes: son, como acabamos de señalar, fundamentalmente nacionales, pero las herramientas analíticas utilizadas para su explicación y mejora son globales y por ello permiten realizar una valoración igualmente global y unitaria de cada sistema nacional. En todos ellos, podemos preguntar sobre los costes y beneficios de la responsabilidad civil –que es muy costosa de aplicar-, sobre su contribución a mejorar la eficiencia, en sentido económico, de las conductas humanas, sobre la que puedan tener, psicosociológicamente, a corregir los sentimientos de maltrato, de trato injusto, que la causación de un daño pueda haber generado en sus víctimas o en la sociedad, o sobre los efectos meramente distributivos de su aplicación, sobre sus consecuencias en la seguridad jurídica y en la certeza del derecho, o sobre sus efectos en el desarrollo tecnológico.

Luego, son sistemas basados en la aplicación privada del derecho, en el ejercicio de pretensiones resarcitorias por decisión de las víctimas de un daño o –si estas fallecieron- de sus herederos o allegados. Operan *ex post*, después de que el accidente y, por tanto, el daño hayan tenido lugar.

Y su rasgo más característico consiste en que toda acción de daños en cualquier sistema de derecho consiste en el ejercicio judicial de una pretensión tendente a la reparación del daño o a su indemnización en dinero, dirigida contra el causante del daño, la persona, natural o jurídica, que ha de responder por aquel, o la compañía aseguradora de ambos.

4.3. La minimización de los costes sociales de los accidentes (Guido CALABRESI, 1970; Steven SHAVELL, 2004) y las simplistas pero escasamente realistas asunciones iniciales de los modelos analíticos del moderno derecho de daños

Durante el último medio siglo, la noción de que el derecho de daños puede contribuir, con otras ramas del derecho, a reducir y, específicamente, a minimizar los costes sociales de los accidentes ha ido a más. Aunque los sectores doctrinales más tradicionales del derecho civil español se aferran a la idea de que el derecho de la responsabilidad civil persigue principalmente compensar daños, nadie hasta ahora ha sido capaz de negar fundadamente que la compensación perfecta supone prevención óptima: la prevención de daños es la sombra de su compensación. En efecto, a poco que nos paremos a pensar, un sistema de reglas de responsabilidad civil que consiguiera que todos los casos de accidentes por los cuales alguien ha de responder se transigieran o litigaran con el resultado de que la víctima obtuviera una compensación integral de los daños, prevendría óptimamente la ocurrencia potencial de tales daños: yo no causaré un daño evaluado en 100 si tengo la certeza de que, si lo hago, me condenarán a pagar a mi víctima tal cantidad, pero *ex ante* puedo evitar el accidente invirtiendo 75 en precauciones (75< 100) y los beneficios que obtengo de mi actividad son los mismos en ambos casos.

Al respecto, los modelos más sencillos del análisis económico parten de asunciones simples, escasamente realistas, pero heurísticamente muy fecundas, pues, en términos generales, las personas razonablemente bien informadas y que no estén trastornadas responden a los incentivos. Básicamente, los modelos parten de suponer que, primero, podemos identificar un nivel de precaución que minimiza el coste total de los accidentes para cada tipo de actividad (fabricar objetos, conducir automóviles, prestar servicios médico-sanitarios, etc.). El coste total incluye los costes privados, es decir, los que sufre la víctima, y los costes sociales, los que experimentan terceros.

En segundo lugar, los modelos asumen, también muy drásticamente, que los agentes sociales son neutrales al riesgo, que están perfectamente informados de las consecuencias de sus actos –o de sus omisiones- y que sus conductas individuales son la única causa de cada accidente, es decir, que las víctimas nada pudieron hacer para evitar el daño.

Asumen además que los individuos son económicamente racionales, es decir, que responden a los incentivos de forma tal que su comportamiento se ajusta siempre al que resulta más eficiente, dada una regla de derecho que se les aplicará inexorablemente en todos y cada uno de los casos en que hayan incurrido en una conducta dañosa por la que hayan de responder.

Finalmente, se suele suponer que las reglas de derecho de daños objeto de análisis permiten conseguir una compensación perfecta de los accidentes, de modo tal que sus víctimas son compensadas de forma tan ajustada al daño sufrido que si, antes del accidente, fueran preguntadas sobre qué preferirían, si no sufrir el accidente o sufrirlo y ser indemnizados por ello, responderían que les resultaría indiferente, le daría igual.

A lo largo de este curso, veremos que ninguna de estas asunciones puede mantenerse incólume, pero, como en otros muchos experimentos, conviene comenzar pensando qué ocurrirá si los realizamos en el vacío. Luego, tiempo habrá para complicar las condiciones de partida. Pero, por muchas complicaciones que añadamos, nunca prescindiremos de la idea básica: ***a la larga, los humanos responden a los incentivos*** (aunque el lector escéptico hará bien en recordarnos a Nietzsche cuando dijo que ***la única razón por la cual el hombre no toma el veneno es su mal sabor***).

Frente a las limitaciones del análisis moderno del derecho de daños, el análisis doctrinal tradicional insiste en la de que la responsabilidad civil pretende únicamente compensar íntegra o limitadamente daños causados, corrigiendo en su caso la injusticia generada por el daño mismo. Mas, como ya hemos señalado, si el derecho de daños en acción compensa adecuadamente, es decir, íntegramente, a todas las víctimas en todos los casos de causación de un daño por los que se haya de responder, también minimiza los costes de los accidentes de que

se trate. Últimamente, el análisis tradicional admite la función preventiva del derecho de daños, pero solo como una consecuencia de hecho, no como un efecto normativo del derecho de la responsabilidad civil. Pero la distinción entre efectos de derecho y de hecho roza la metafísica.

Mucho más relevante que la crítica anterior es otra distinta que relaciona el derecho de daños con una función correctiva, catártica, restauradora del orden jurídico y social alterado por el causante y responsable de los daños. Esta es mucho más digna de atención que la anterior y apela a la psicología social, un punto de vista desconsiderado por el análisis económico neoclásico del derecho.

Y finalmente quizás es decisiva la consideración de que el derecho no está únicamente condicionado por la economía, sino que lo está igualmente por todos los saberes científicos y tecnológicos: a largo plazo, el derecho cumple cabalmente sus funciones si trata de realizarlas a partir del estado de los conocimientos, no a su margen ni, mucho menos, en contra de ellos: la ignorancia no es fuente de derecho.

5. La acción de daños de los perjudicados por un ilícito competencial y la Propuesta de Directiva comunitaria de 11.6.2013

— Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (COM(2013) 404 final, 11.6.2013): http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html.

La responsabilidad civil también se llama responsabilidad extracontractual. El nacimiento de una obligación de indemnizar por daños causados al margen de una relación jurídica contractual puede estar asociado a la realización de una conducta penalmente típica, pero también puede estarlo a la infracción de disposiciones puramente administrativas, de derecho público, pero no necesariamente de derecho penal.

Un ejemplo crecientemente importante es el de infracciones del derecho público de la competencia, las cuales, además de violar el derecho europeo, español --o ambos—causan daños a terceros: si las empresas de una misma industria forman un cártel o una sola empresa que ocupa una posición dominante en la industria abusa de tal posición y el resultado final es que los terceros que adquieren bienes o contratan servicios de tales empresas han de pagar un precio más elevado del que habrían de pagar si el mercado funcionara en condiciones de competencia razonable, es obvio que sufren un daño y que, en principio, tal daño es indemnizable: las víctimas del daño, clientes de las empresas en cuestión, tienen una acción civil, cuyo conocimiento corresponde en principio a los tribunales civiles.

Sin embargo, los obstáculos al ejercicio de una acción de responsabilidad civil por daños derivados de la infracción del derecho de la competencia son punto menos que insalvables. Citemos algunos de ellos:

1) En primer lugar, la autoridad competencial, europea o española, habrá de haber declarado la existencia de un ilícito –de la formación de un cártel, de la existencia de un abuso de posición dominante, etc.–. En derecho europeo, el núcleo básico de la regulación relevante se encuentra en los arts. 101 y 102 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea y en el Reglamento del Consejo 1/2003, de 16 de diciembre de 2002. En derecho español, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
2) Luego, el demandante habrá de probar que ha sufrido un daño y que este deriva precisamente de la infracción cuya existencia ha declarado la autoridad competencial, pero esta podrá, en determinadas circunstancias, negarse a facilitar la información

relevante, por ejemplo, aquella que hubiera obtenido de empresas participantes en el cártel que denunciaron su existencia para librarse de las sanciones legales o moderar su importe. En Europa continental, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, no hay *discovery* y la transparencia de las Administraciones Públicas es también más limitada a esta orilla del Océano Atlántico.

3) El derecho europeo y, por supuesto, el español, tampoco tienen tradición en materia de acciones colectivas o de clase. Miles o cientos de miles de consumidores pueden haber resultado dañados, el daño total puede ser muy elevado, pero al ser muy difuso, ningún consumidor individual tiene incentivos para reclamar y la iniciativa de una firma de abogados para acomunar las acciones individuales de los consumidores perjudicados puede encontrar muchas dificultades en la regulación procesal del Estado Miembro de que se trate.
4) Los distintos derechos nacionales europeos tampoco regulan finamente la llamada *"passing-on defence"*, una excepción en cuya virtud el demandado puede oponer que el demandante o los demandantes no sufrieron el daño que alegan, pues consiguieron repercutir sobre sus clientes y proveedores el exceso de precio cobrado por el demandado mismo al demandante. Si A, B y C constituyen un cártel y acuerdan un precio un tercio superior al que regirían en condiciones de competencia, pero sus clientes consiguen repercutir el sobreprecio en los suyos sin disminución de la demanda --ciertamente, un caso raro--, no habrán sufrido daño alguno y la excepción será oponible con éxito.
5) La ausencia de valor probatorio, en el posterior pleito civil, de las resoluciones de la autoridad competencial de que se trate.
6) La cuantificación del daño causado: el demandado puede haber cometido un ilícito, esta circunstancia puede resultar perfectamente establecida por la autoridad competencial, pero aun y así, probar la existencia y causación del daño puede resultar extraordinariamente complejo: véase Assimakis KOMNINOS (Dir.) (2009), *Quantifiying antitrust damages – Towards non-binding guidance for courts*.

La Propuesta de Directiva trata de abordar estas cuestiones. En particular, intenta establecer un mismo equilibrio entre todos los derechos de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea y el derecho europeo mismo, sobre la aplicación del derecho público de la competencia -*public enforcement*, aplicación pública, con técnicas de derecho público- y su aplicación privada -*private enforcement*, con instrumentos de derecho privado, en el caso, con la acción privada de responsabilidad civil, ejercitable ante tribunales civiles-.

En efecto, el ya citado Reglamento 1/2003 desarrolla las reglas de los art. 101 y 102 del Tratado, las cuales prohíben los acuerdos anticompetitivos y los abusos de posición dominante. El Reglamento establece las condiciones bajo las cuales la Comisión Europea y las autoridades competenciales nacionales (y, por supuesto, los tribunales) aplican tales disposiciones.

Además de la aplicación propiamente pública –administrativa (y, en algunos casos, penal)- del derecho de la competencia, el proyecto de Directiva establece los presupuestos de un derecho armonizado de su aplicación privada, es decir, del ejercicio de la acción de responsabilidad civil que corresponde a los perjudicados por el ilícito competencial para reclamar de los infractores una compensación razonable no solo por las pérdidas ocasionadas, sino también por las ganancias dejadas de obtener y, en su caso, los intereses correspondientes.

El proyecto trata de alinear ambos procesos de aplicación del derecho para optimizar el resultado final, intenta armonizar los distintos derechos nacionales y persigue establecer las fronteras entre aplicación pública y privada en búsqueda de un equilibrio razonable –pero en el caso europeo, muy deferente con las atribuciones y competencias de las autoridades--.

Los arts. 1 y 2 de la Directiva en proyecto establecen su alcance, esto es, las reglas necesarias para asegurar que quien haya sufrido un daños como consecuencia de las infracciones competenciales referidas en los arts. 101 y 102 del Tratado o del derecho nacional de la competencia, puedan ejercitar de forma efectiva su derecho a la compensación íntegra (*full compensation*) del caño causado (arts. 1 y 2.1), de modo tal que la víctima del daño, una vez

obtenida la compensación, se encuentre en la misma situación que estaría si la infracción no se hubiera cometido *("Full compensation shall place anyone who has suffered harm in the position in which that person would have been had the infringement not been commited"*, art. 2.2). La propuesta insiste en que los Estados Miembros habrán de asegurar que los perjudicados podrán ejercitar de forma efectiva las acciones correspondientes por responsabilidad civil (art.2.3).

En particular, el proyecto busca proteger a las empresas participantes en un ilícito competencial, pero que han facilitado su persecución pues han denunciado tempranamente la infracción y se han acogido a los programas denominados de clemencia (*leniency programmes*) establecidos por el derecho europeo y los distintos derechos nacionales (véase *Commission Notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases*. OJ C 298, 08.12.2006, p. 17). El proyecto parte de la asunción, indudablemente correcta, de que, *ex ante*, el infractor y denunciante potencial del ilícito se retraerá si no recibe garantías de que, además de la anulación o moderación de la multa administrativa, no será objeto de una reclamación por responsabilidad civil en cuyo ejercicio, además, el accionante presentará como prueba la denuncia misma y los demás medios de prueba que el demandado hiciera llegar en su momento a las autoridades: todas las policías del mundo trabajan con confidentes, pero saben de sobras que sin confidencia no hay confidentes.

Lo mismo ocurre cuando los infractores o algunos de ellos cooperan activamente con la investigación y llegan a una transacción con las autoridades (*settlement submissions*): difícilmente podría haber una transacción si, luego de acordada y en el procedimiento civil subsiguiente, los demandantes por responsabilidad civil pudieran acceder a la información que está en la base de la transacción misma. En junio de 2008, la Comisión Europea introdujo un nuevo procedimiento para la transacción en casos de cárteles (*Commission Notice on the conduct of settlement procedures in view of the adoption of Decisions pursuant to Article 7 and Article 23 of Council Regulation (EC No 1/2003 in cartel cases (OJ C 167/1, 02.07.2008), and Regulation 622/2008 (OJ L 171/3, 01.07.2008) amending Regulation 773/2004*). La Comisión tiene amplia discrecionalidad y puede comunicar a las partes su predisposición a transigir el caso en el intento de llegar a un entendimiento común (*common understanding*) previo a la transacción misma (*settlement submission*). En el procedimiento, las partes intercambian la información relevante, conducente al esclarecimiento del caso y a su resolución, pero de nuevo es obvio que la transacción sería mucho más difícil de alcanzar si no se ofrecieran garantías de confidencialidad.

Finalmente y al margen de los dos supuestos anteriores, es también lógico que, mientras el procedimiento administrativo incoado para la posible declaración de la comisión de un ilícito competencial no ha sido resuelto (ni, en su caso, revisado jurisdiccionalmente), los perjudicados por el presunto ilícito competencial no pueden acceder a la información que obra en poder de la autoridad competencial de que se trate, pues ello pondría en peligro su buena gestión.

Por ello, el proyecto planea establecer un mismo nivel de protección mínimo a favor de los denunciantes amparados por un programa de clemencia, europeo o nacional:

- El art. 6. 1. establece una regla de protección absoluta en cuya virtud los Estados Miembros habrán de asegurar que, en relación con las acciones de responsabilidad civil, los tribunales nacionales no podrán desvelar en ningún momento –nunca- las manifestaciones relacionadas con los programas de clemencia (*leniency corporate statements*), ni con las transacciones (*settlement submissions*).
- El art. 6.2. establece una regla de protección temporal según la cual los Estados Miembros habrán de asegurar que, con respecto a las acciones de responsabilidad civil, los tribunales nacionales solo podrán exigir el desvelo de información específicamente preparada para un expediente iniciado por una autoridad competencial o generada por esta última, una vez la autoridad en cuestión haya resuelto definitivamente el expediente o adoptado una decisión de acuerdo con el art. 5 del Reglamento 1/2003 o su Capítulo III.

Con estas dos limitaciones, el resto de las reglas propuestas sobre revelación de información a efectos de prueba sigue la tradición europea continental –muy reacia a la *discovery*— y planea exigir a los Estados Miembros asegurar que los tribunales admitan la proposición de prueba de

las partes demandantes por responsabilidad civil con tal que la prueba sea relevante para sustanciar su caso, esté suficientemente especificada, en vista de los hechos alegados, y que resulte proporcionada, a la luz del grado de probabilidad de la comisión de la infracción, del ámbito y coste de la obtención de la información solicitada, de su naturaleza confidencial, así como de su especificidad en relación con una eventual investigación pública anterior (art. 5).

Otras reglas incluidas en la Directiva en proyecto tratan de cuestiones cuyo análisis corresponde a otros capítulos de este e-libro. Así, la muy razonable propuesta de establecer un plazo de cinco años para la prescripción de la acción (art. 10), la que establece la presunción de la causación de daños en el caso de los cárteles (art. 16), las que limitan la –tradicionalmente hipertrofiada– responsabilidad solidaria en el caso de los programas de clemencia (art. 11) y, similarmente, la que hace lo propio en el caso de transacción y a favor de la parte que ha transigido (art. 18). Mención especial merece la regulación de la *passing-on defence* (art. 12), en cuya virtud el demandado podrá siempre oponer como excepción a la demanda de daños que el actor repercutió a terceros todo exceso de su prestación (*overcharges*) derivado del ilícito competencial.

El proyecto de Directiva someramente descrito en estas páginas constituye un ejemplo destacado del nuevo derecho de daños: se trata de una regulación claramente específica de un sector muy especializado del moderno derecho regulatorio, pero que al mismo tiempo participa del conjunto de características del derecho general de daños. Quizás la mayor utilidad de este curso es su transversalidad, su potencial utilidad para integrar el derecho aplicable en una miríada de sectores intensamente regulados en los cuales los árboles han de dejar ver el bosque, la comunidad de criterios normativos y analíticos que mantiene la unidad del derecho de daños a lo largo y a lo ancho de todas las ramas del ordenamiento jurídico.

6. Responsabilidad civil y penal / *Tort and Crime*

En derecho de accidentes y en general, interesa la distinción entre derecho público y derecho privado: el derecho público establece infinidad de regulaciones que establecen, *ex ante*, cuáles son las condiciones de seguridad (precauciones) bajo las cuales puede desarrollarse tal o cual actividad y, *ex post*, las consecuencias de no haber observado las precauciones establecidas, normalmente, una multa pecuniaria, pero también, la suspensión de la actividad, su cese, o, incluso, la imposición de penas en sentido estricto (aplicación del derecho penal). En España, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestra área cultural, los delitos y faltas tipificados en el Código Penal comportan una pena, una sanción específicamente penal, pero además, en el mismo proceso en el cual se ventilan las eventuales responsabilidad penales de los imputados, se resuelve sobre sus responsabilidades estrictamente civiles o aquellas de las personas de quienes dependen.

El derecho penal, el derecho de la responsabilidad penal es primariamente derecho público que tutela intereses públicos: los consistentes en evitar la comisión de delitos y en restablecer la justicia quebrantada por el delincuente. El derecho civil de daños, el derecho de la responsabilidad civil no es incongruente con el anterior, pues también pretende abordar la reducción razonable o la supresión de riesgos que afectan a miembros de la colectividad o a toda ella. Pero ello se consigue, en el caso del derecho civil, con pretensiones puramente civiles ejercitadas normalmente en un proceso civil y queda siempre a la decisión del demandante la relativa al ejercicio de la pretensión de daños. El derecho de daños es privado por dos razones: el demandante elige entre accionar o no hacerlo y la indemnización que, en su caso, obtenga, quedará en su patrimonio, no es ninguna multa que engrose las arcas de la Hacienda Pública.

Sin embargo, ya hemos señalado que un mismo acto puede ser, al mismo tiempo, un delito (o falta) y un supuesto de responsabilidad civil: de derecho, todos los delitos y faltas pueden general una acción de responsabilidad civil por los daños eventualmente causados, acción que, normalmente, se ejercerá en el proceso penal, pero que los afectados pueden reservarse para ejercitarla en un proceso civil independiente (art. 112 LECr), algo que raramente sucede.

7. Responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad (también civil, pero) contractual / *Tort and Contract*

En derecho privado interesa la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual o civil (derecho de daños en sentido estricto). En una primera aproximación, la conducta cuya realización implica el incumplimiento de un contrato conlleva la responsabilidad de la parte incumplidora frente a su contraparte, pero no es considerada un supuesto de responsabilidad civil. Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato de transporte de personas no genera responsabilidad civil aunque, claramente, pueda dar lugar a responsabilidad contractual en los términos previstos por el contrato mismo o la ley. Sin embargo, si, con ocasión del transporte, quien lo realiza, hiere o veja al viajero, este dispondrá de una pretensión específica de responsabilidad civil con independencia de las que puedan derivarse del contrato mismo.

En virtud de lo genéricamente establecido por el art. 1255 CC o, menos formalistamente, en virtud del ingenio precisamente humano, los humanos mismos y las organizaciones creadas por ellos pueden entablar relaciones contractuales muy diversas y con un contenido infinitamente diverso: el incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de una de las partes en un contrato válido da derecho a la otra a llevar a la primera ante un Juez para que este establezca las consecuencias de la infracción según el mismo contrato. Así, los deberes y obligaciones contractuales son creados por el ingenio y promesas de las partes del contrato. En cambio, los deberes derivados del derecho de daños dimanan directamente de la legislación y de los reglamentos aplicables o del derecho judicial, al margen de todo pacto o acuerdo entre las partes.

En el *Common Law,* la responsabilidad contractual es fundamentalmente objetiva, mientras que la responsabilidad civil es mayormente por negligencia. Sin embargo, en el *Civil Law* y, concretamente, en derecho español, la responsabilidad contractual parte de un principio general de negligencia, aunque la cuestión es muy discutida.

En la práctica, la dinámica del derecho de contratos es estrictamente privada: los contratos surgen y se desarrollan de abajo arriba –*bottom-up*—a partir de las soluciones ingeniadas por los abogados de las partes, para cada sector del tráfico económico, ante el desarrollo de la tecnología y la comercialización de nuevos productos y servicios cuyo acceso al mercado y distribución exigen nuevas soluciones contractuales. En cambio, la dinámica del derecho de daños, de responsabilidad civil, es regulatoria –*top-down*- o judicial –*bottom-up*, pero pública. Ello genera diferencias estructurales importantes: el derecho de contratos mira a crear o facilitar rutas comerciales, tráfico económico y solo secundariamente litigación. En cambio, el derecho de daños está centrado en la litigación, pues su énfasis está puesto en la reclamación de una indemnización de daños y perjuicios en un proceso judicial. La diferencia es tan marcada que, en algunos países, los abogados de contratos y los abogados de litigación se diferencian claramente los unos de los otros.

La **STS, 1ª, 349/2012, de 11 de junio** resuelve la cuestión relativa a si el propietario de una finca que la contamina en el ejercicio de una actividad industrial lícita y que después vende la finca misma responde extracontractualmente frente al tercer adquirente por los daños económicos sufridos.

En palabras del Tribunal Supremo:

"Se trata de decidir si una sociedad mercantil constituida por entes públicos para la regeneración y consiguiente explotación de un puerto deportivo-pesquero y su zona residencial contigua puede repercutir retrospectivamente los costes de la descontaminación a la sociedad mercantil que en tiempos contaminó la zona, y ello pese a haber tenido que cesar esta en su actividad industrial y haber vendido en su día los terrenos a bajo precio debido precisamente a su contaminación, conocida por todas las entidades que sucesivamente fueron adquiriendo derechos sobre dichos terrenos. Y esta decisión se somete por la actora-recurrente a la jurisdicción civil con base en el Código Civil pero invocando el principio "quien contamina paga"

, presente en diversas normas administrativas de protección medioambiental que se consideran aplicables al caso".

Hechos:

Ercros, S.A. "explotaba desde el primer tercio del siglo XIX una fábrica sita en un terreno de su propiedad ubicado en la fachada marítima de Badalona, y destinada a la fabricación de … productos químicos y abonos en general… siendo su actividad la de gran industria".

El 7.5.1987, la Corporación Metropolitana de Barcelona (luego Consell Comarcal Barcelonés) aprobó el Plan Especial de la Fachada Marítima de Barcelona, que contemplaba la ubicación del futuro puerto de Badalona al norte de los mencionados terrenos, y los calificaba como terrenos para pequeña y mediana industria, con la excepción de una zona destinada a uso residencial.

El 14.5.1987, Ercros, S.A. vendió mediante escritura pública a la Corporación una porción de terreno de unos 71.000 m² ubicada en primera línea de mar por 3.906.579 euros (650 millones de ptas.). En ese momento, el precio de mercado del terreno vendido era muy superior, de 5.318.957 euros (885 millones de ptas.). Los terrenos estaban altamente contaminados porque presentaban un elevado contenido de plomo y arsénico.

El 31.7.1987, Ercros cesó su actividad industrial y consta acreditado que, con posterioridad, el lugar fue utilizado como zona de extracción de arenas y vertido incontrolado de residuos de diferentes procedencias

En 1989, Ercros vendió el resto de los terrenos a Prima Inmobiliaria, S.A., que, a su vez, se los vendió mediante escritura pública el 9.5.1990 a Inmobiliaria Industrial Urbana, S.A. y esta, a su vez, se los vendió al ICO en 1994 en pago de deudas.

En 1991, el Ayuntamiento de Badalona decidió ubicar el puerto en los antiguos terrenos de la demanda, pese a ser conocida la contaminación de la zona por los estudios que había iniciado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en 1990, y dividió la zona en dos polígonos: uno destinado a suelo residencial y el otro a sistema portuario. El Gobierno de la Generalitat aprobó el proyecto de construcción del puerto deportivo de Badalona y otorgó a Marina Badalona, S.A., sociedad participada al 50% por el Consell Comarcal Barcelonés y el Ayuntamiento de Badalona, la concesión para la construcción y explotación del puerto, con asunción, entre otras obligaciones, de descontaminar los terrenos.

En 2001, 2002 y 2003 el Consell Comarcal Barcelonés aportó la porción de terreno que había comprador a Ercros a Marina Badalona, S.A. como aportación no dineraria con ocasión de tres sucesivas ampliaciones de capital realizadas en tales años. Del valor de la finca se descontaron en aquel momento 3.432.981 de euros (571 millones de ptas.) en concepto de gastos de descontaminación.

El 19.12.2002 y por escritura pública, ICO vendió a Marina Badalona, S.A. los terrenos que originariamente habían pertenecido a Ercros haciendo constar que tales terrenos iban a verse afectados por las obras de construcción del puerto de Badalona y que como existía un remanente de contaminación del suelo el coste de la contaminación (valorado en 8.005.481 euros) debía descontarse del precio de la venta de los terrenos, que quedaba en 11.419.230 euros.

Procedimiento:

Marina Badalona, S.A. demandó a Ercros, S.A. y le reclamó el pago de 25.444.530,10 euros por daños y perjuicios asociados a la contaminación de las fincas con base en el art. 1902 CC, pero también en haber cumplido con la obligación de descontaminación que incumbía a Ercros, por lo que invocaban la subrogación, el reembolso la repetición y el enriquecimiento injusto, así como la STSJ de Cataluña núm. 308/2004 de 28.4.2004, que habría impuesto a Ercros la obligación de descontaminación.

El 3.6.1997 la Junta de Residuos de la Generalitat de Cataluña había dirigido a Ercros, S.A. un requerimiento para que en el término de dos meses procediese a la retirada de escombros y residuos y a la realización de un estudio sobre el alcance de la contaminación. Requerimiento que fue reiterado el 26.6.1997 y el 28.11.1997. Ercros presentó un recurso administrativo contra el último requerimiento de la Junta, que fue inadmitido el 11.11.1998. Ercros, a su vez, interpuso un recurso ordinario contra la inadmisión, que el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya desestimó mediante resolución de 31.1.2000. Ercros interpuso recurso contencioso-administrativo esta última resolución y el TSJ de Cataluña en Sentencia de 28.4.2004 lo admitió en el sentido de revocar las decisiones administrativas en cuanto a sus pronunciamientos de inadmisibilidad del recurso y, entrando en el fondo del asunto, desestimó el recurso contra la resolución de la Junta de 28.11.1997:

"[E]l apartado a) del ... artículo 15 [de la Ley 6/1993, de 15 de julio, de residuos de Cataluña] considera como responsable directo de la regeneración de los espacios degradados por descargas incontroladas a la persona que ha efectuado la descarga y solidariamente al productor o el poseedor del residuo, siendo responsable únicamente subsidiario de la misma..., según su apartado b), el propietario de la finca ...o en su caso el titular del dominio público afectado, y constituyendo obligación del productor y del poseedor de los residuos, según el art. 17.1.a), la de garantizar su gestión de acuerdo con sus prescripciones desde luego inmediatamente aplicables a un requerimiento de descontaminación producido bajo su vigencia, y ante una contaminación que se mantuvo en el tiempo tras ella, cualesquiera que fuesen los acuerdos, privados o incluso de carácter o alcance urbanístico, que pudieran haberse alcanzado al momento de la venta de los terrenos" (FD. 5º).

La SJPI nº 27 Barcelona (8.1.2008) estimó en parte la demanda y condenó a Ercros al pago de 8.895.785,28 euros. En apelación, la AP (Sección 16ª) de Barcelona (31.3.2009) estimó el recurso de apelación interpuesto por Ercros, S.A., desestimó el de la demandante, y revocó la SJPI, desestimando la demanda:

"El coste de la descontaminación de un suelo contaminado debe ponerse en relación con el uso urbanístico de ese suelo... [en este sentido, art. 15 Ley 6/1993, en su redacción dada por la Ley 9/1998, y actual art. 19 b Decret Legislatiu *1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus*: "Que les persones causants de la contaminació d'un emplaçament resten obligades a sanejar-lo en funció de l'ús urbanístic que tenia quan el van transmetre. No es poden requerir mesures de sanejament complementàries vinculades als nous usos urbanístics del sòl, llevat que hagin estat promoguts per elles mateixes" (…)

"[L]a reclamación fundada en el art. 1902 producía una sensación de perplejidad porque los daños se habrían causado a una finca propia de la demandada cuando ejercía una actividad industrial que cesó en 1987;... descartada cualquier obligación contractual de Ercros para con Marina, ya que ésta no compró directamente los terrenos a aquella ni funda su demanda en acciones derivadas del contrato de compraventa, tampoco cabía la responsabilidad extracontractual por faltar el elemento de alteridad, como consideró la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 rectificando el criterio de la de 29 de octubre del mismo año...; en último extremo, la acción para exigir responsabilidad civil extracontractual habría prescrito conforme al art. 1968 CC, pues el caso no sería de daños continuados sino permanentes y, además, conocidos desde mucho años antes de la interposición de la demanda, de modo que nada habría impedido... reclamar en su momento por los daños, al margen de una responsabilidad por saneamiento que parece haber sido asumida y resuelta convencionalmente en su momento" (...)

"La demandante no hizo propiamente una regeneración del solar por sustitución de una obligación concreta y exigible a la demandada impuesta por la Administración en interés general, sino que lo que hizo fue urbanizar la zona en propio interés y, ciertamente, ello implicó la descontaminación de la finca" (FD. 2º STS).

Marina Badalona, S.A. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El segundo, por infracción de los arts. 1210 y 1158 CC, arts. 33, 43 y 45 CE y art. 1902 CC, así como por infracción del art. 1968 CC. El TS desestimó ambos recursos y confirmó la SAP:

"[E]ntre los dos referidos criterios opuestos de decisión [el de la STS, 1ª, de 29.10.2008 (RJ 5801), en la que el Tribunal Supremo condenó a Ercros con base en la responsabilidad extracontractual y el de la STS, 1ª, núm. 1135/2008 de 22.12.2008, en la que el Tribunal, en

cambio, le absolvió porque los daños fueron causados a una finca propia] esta Sala considera que debe reiterar [el segundo criterio, según el cual] (FD. 4º):

"Cuando se trata de daños originados en la cosa vendida … el daño sufrido por el comprador resulta, en principio, del deficiente cumplimiento o del incumplimiento del contrato de compraventa; la relación de responsabilidad que resulta del cumplimiento o deficiente incumplimiento tiene el mismo alcance subjetivo que el que media, dentro de la órbita contractual, entre el que causa el daño (vendedor) y el que lo recibe (comprador); el ordenamiento jurídico prevé consecuencias específicas para los casos de defectos en la cosa vendida; y, finalmente, los bienes afectados son de carácter patrimonial, en tanto no se demuestre la afectación de bienes o derechos de mayor trascendencia. En suma, los daños originados en la cosa vendida que suponen un menoscabo de su valor o una imposibilidad de dedicarla al uso al que está destinada deben ser reclamados mediante el ejercicio de las acciones contractuales que correspondan, entre las cuales figuran las acciones para pedir el saneamiento de la cosa por vicios o defectos ocultos (acción redhibitoria y *quanti minoris* [de disminución del precio 'en cuanto menos']) o la acción resolutoria dimanante del incumplimiento del contrato cuando la cosa entregada es sustancialmente distinta de aquélla que se pactó como objeto de la compraventa o inhábil para el uso a que se destina (una cosa por otra, o *aliud pro alio*).

Esta reclamación debe ir dirigida contra el vendedor mediante, si procede, la subrogación que a tenor del artículo 1511 CC se opera en favor del comprador respecto de las acciones que corresponden al primero contra los transmisores anteriores…

El hecho de que el comprador no sea el primer adquirente no lo autoriza por sí mismo para el ejercicio de acciones de responsabilidad extracontractual contra los anteriores propietarios por los daños que haya sufrido la cosa vendida" (FD. 4º, véase un análisis de las SSTS de 2008 en Sonia RAMOS GONZÁLEZ y Rosa MILÀ RAFEL, "Responsabilidad civil y daños a los propios bienes", InDret 3/2009).

En último extremo, aunque se admitiera una obligación *ex lege* de Ercros, resultaría que esta ya se habría cumplido frente a la demandante, como razona la sentencia impugnada, mediante los sucesivos descuentos del coste de la descontaminación en los negocios jurídicos privados de transmisión de los terrenos" (FD. 5º).

8. ¿Es el derecho de daños una especialidad bien definida?

Sí, pero quizás sólo por oposición al derecho de la responsabilidad contractual o al derecho sancionador y, desde luego, está mucho menos definido en España que en otros países, señaladamente, que en los Estados Unidos de América.

El derecho de daños tiene una especificidad clara y distinta si se analiza desde el punto de vista del remedio típico que le es paradigmáticamente propio: las acciones de reparación e indemnización de daños. **Los remedios dan unidad al derecho de daños**.

Pero casi nada más lo hace: hoy en día, en un país occidental tecnológicamente avanzado es crecientemente difícil de concebir que una abogada esté especializada, al mismo tiempo, en litigación derivada de difamación, de protección de datos, de daños masivos, de accidentes de circulación, de daños biofarmacéuticos, de prevención de riesgos laborales, de exposición a sustancias tóxicas, etc. La razón es que el derecho de daños descansa sobre regulaciones crecientemente intrincadas y su conocimiento y dominio es, en la práctica, condición necesaria de la viabilidad de un escrito de demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios. Nadie domina a la vez el acoso sexual, la difamación, la litigación por inhalación de sustancias tóxicas o los accidentes de aviación. Ya no.

Mas queda, anclado bien en el análisis de los remedios, algún otro punto de apoyo a la idea de la unidad positiva del derecho de daños –es decir, a la idea de que este se define por algo más que por su contraposición al derecho de contratos, al derecho penal y al derecho regulatorio---

Así, y en primer lugar, la cuestión de la culpa, de la negligencia del demandado ocupa un lugar central en casi todos los casos de derecho de daños regidos por el estándar de la culpa misma, como es el supuesto general del derecho del art. 1902 del Código Civil español de 1889.

Más aún, en torno a las cuestiones la causalidad en sentido amplio, que abarcan la causalidad empírica o de hecho (*Cause in Fact*) y causalidad, de derecho, normativa o imputación objetiva (*Proximate Causation, Scope of Liability*), comunes a la responsabilidad por negligencia y a la objetiva.

Luego, la naturaleza esencialmente procesal del ejercicio de las acciones y pretensiones de derecho de daños centran a la responsabilidad civil en torno a su litigación y transacción: a diferencia del derecho de contratos, que es extrajudicial y *ex ante*, el derecho de daños es judicial y *ex post*. En los países con juicio de jurado para la responsabilidad civil, la unidad procesal y profesional del derecho de daños aún es más marcada, pero no es el caso de España.

Finalmente, esencial al derecho de daños, es su dinamismo: el cambio forma parte de su naturaleza. El contrato pretende atar el futuro, el derecho de daños reanudar el pasado.

Capítulo 2º
Las cuatro reglas básicas de responsabilidad y los límites del derecho de daños

1. Las cuatro reglas básicas de responsabilidad: ausencia de responsabilidad, dolo, culpa o negligencia y responsabilidad objetiva/*Basis: No Liability, Intentional Torts, Negligent Torts, and Strict Liability.* El límite de la responsabilidad absoluta 29
1.1. La regla de la ausencia de responsabilidad (*No liability*): sobre la libertad de actuar sin miedo a sus consecuencias dañinas para terceros 29
1.2. La causación dolosa, intencional, de daños 31
1.3. La regla de la negligencia 32
1.4. La regla de la responsabilidad objetiva 35

1. Las cuatro reglas básicas de responsabilidad: ausencia de responsabilidad, dolo, culpa o negligencia y responsabilidad objetiva/*Basis: No Liability, Intentional Torts, Negligent Torts, and Strict Liability.* El límite de la responsabilidad absoluta

Como hemos visto en el capítulo 1º, en responsabilidad civil, las circunstancias en las cuales el demandado ha de responder por los daños sufridos por la víctima son muy diversas y dependen de la regulación y la jurisprudencia aplicables al caso. Pero, en términos muy generales, hay cuatro grandes reglas de responsabilidad civil:

1.1. La regla de la ausencia de responsabilidad (*No liability*): sobre la libertad de actuar sin miedo a sus consecuencias dañinas para terceros

El estatuto más básico de una conducta dañina –pero más beneficiosa que dañina—es aquel según el cual su realización no comporta ningún deber de indemnizar a sus víctimas. Contra lo que a menudo se cree, la regla de la no responsabilidad es, afortunadamente, muy frecuente: las pérdidas se quedan donde se han producido; los daños, allí donde han tenido lugar.

Un soldado, jurista y juez norteamericano, Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-1935) expresó muy gráficamente esta idea, en su obra *The Common Law* (1881):

"Sound policy lets the losses lie where they fall except where a special reason can be shown for interference".

Muchos siglos antes, el Derecho romano lo había hecho con laconismo:

"casum sentit dominus".

Y en España lo mismo ha escrito la magistrada Encarna Roca en la Introducción a la 6ª edición de *Derecho de Daños. Textos y Materiales* (en colaboración con Mónica Navarro):

"En este libro se parte de un principio general: la persona que sufre un daño está obligada a asumir sus consecuencias, excepto si existen razones jurídicas para trasladarlas a quien lo ha producido" (p. 15).

Si la regla aplicable es la de ausencia de responsabilidad por los propios actos, no hay indemnización por daños, las víctimas se lamen sus propias heridas –si sobreviven a ellas- y el mundo sigue su curso. La regla incentiva niveles máximos de precaución en las víctimas potenciales (para evitar sufrir el daño), pero también un nivel cero de precaución en los causantes potenciales de daños (pues no habrá de pechar con sus consecuencias). La regla parte de que, para tales o cuales conductas, es preferible un principio de libertad individual sin consideración a los daños que la actividad de que se trate puede causar a terceros:

- Alguno de ustedes estará, sin duda, resfriado, pero sus compañeros no tienen derecho a reclamar indemnización alguna si, por ello, se contagian, mucho menos a exigirle que se quede en su casa, en cuarentena, hasta que cure del resfriado (en cambio, si hubiera contraído la tuberculosis, una enfermedad grave, quizás podrían reclamar por el contagio sufrido si el primer enfermo no adoptó precaución alguna).

- Todos ustedes tienen que soportar que su vecino compre el diario o se conecte a la radio en i-Tunes que ustedes detestan, que se peine, deje de hacerlo o que se atilde como guste o, más opinablemente, que se vista o medio desvista como le plazca.

- En nuestro derecho, nadie tiene derecho a ser amado, es decir, nadie puede ejercitar una pretensión judicial –una pretensión indemnizatoria, en nuestro caso– porque otra persona se niega a quererle, a amarle: no hay derecho al amor aunque ello pueda causar el suicidio del desesperado amante [***The Sorrows of Young Werther*** (*Die Leiden des jungen Werthers*) una novela de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), publicada en 1774]. Más discutiblemente, nadie tiene derecho a seguir siendo amado, aunque algunos juristas defienden que la infidelidad matrimonial y sus consecuencias biológicas deberían dar lugar a una pretensión indemnizatoria a favor del cónyuge afligido por ella.

- Parecidamente, varios aficionados a la práctica del noble deporte del rugby pueden decidir fundar un club deportivo, contratar un seguro de daños y comprometerse a no obligarse a responder recíprocamente por las lesiones causadas en el juego. En general y en derecho de contratos, las partes pueden excluir limitadamente su responsabilidad por accidentes. A cambio de ello, la ley puede exigirles que contraten un seguro obligatorio de accidentes y, en todo, caso prohíbe la exclusión de responsabilidad por daños causados dolosa, intencionadamente, o acaso también los causados por negligencia muy grave, rayana en el dolo.

- Tampoco responden los padres ante un hijo suyo por el hecho de haberle traído al mundo en condiciones tales que el hijo dice luego que preferiría no haber nacido -o alguien lo dice por él, una asociación o una fundación, por ejemplo-. El derecho de familia obliga a los padres a cuidar al hijo precisado de ayuda, pero no concede a éste una pretensión de daños contra aquéllos. El derecho de daños se niega a comparar una vida dura, acaso invivible para muchos, con el vacío absoluto del nihilismo. Pero incluso esto también resulta polémico para algunas personas que se niegan a traer hijos a este mundo, por no tener que convivir con seres temporalmente heterónomos y absolutamente dependientes, al tiempo que defienden que quienes lo hagan, respondan por ello en casos como el presentado aquí.

- La competencia, sumada al desarrollo tecnológico, es, literalmente, destrucción creadora: las tabletas han arrasado las librerías tradicionales del mismo modo que la bombilla de Edison acabó con las cererías y el motor de explosión con las caballerías, o que LED está ahora acabando con las bombillas incandescentes y el motor eléctrico pueda acabar desplazando al de explosión. Pero competencia no es competencia desleal. Es, simplemente, competencia. Causa daños, causa muchos más beneficios que daños, disloca comunidades, acaba con estilos de vida cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, pero, en una sociedad abierta, no impide que una comunidad resuelva libremente vivir al margen del desarrollo tecnológico y de la competencia misma (un claustro monástico, una comunidad de Amish, otra neorrural, etc.), eso también, de modo mucho más sencillo y probablemente menos rico que el del resto de los consociados.

- En general, el ejercicio legítimo de cualesquiera derechos fundamentales puede originar y, de hecho, origina daños, pero son daños por los cuales el causante no habrá de responder. Una madre atea puede llegar a precisar asistencia psicológica, incluso a enfermar después de que su hijo entre en religión y un padre puede pasar por lo mismo o peor porque su hijo deja el oficio paterno, aborrece la ideología de los abuelos o abandona el país que les vio nacer a todos. Pero, afortunadamente, es ley de vida. Igualmente, mis vecinos pueden comprar los diarios, ver las películas o ser socios de los clubes que detesto, practicar la religión, educar a sus hijos, o votar de los modos más alejados a aquellos que considero apropiados para hacer real mi idea del bien común. Y así sucesivamente: no hay responsabilidad.

STS, 1ª, 270/2006, de 9 de marzo. Asunción de riesgo en la práctica deportiva.

El 16.11.1991, Luis Manuel, quien jugaba a golf en el "Club de Golf Terramar" de Sitges, falleció tras recibir el impacto de una pelota lanzada por Ismael, que se encontraba en una calle distinta y separada de la de la víctima por una arboleda que impedía a ambos jugadores verse. El lanzamiento en cuestión había sido técnicamente incorrecto a causa del viento que soplaba en la zona.

Lucía, viuda del fallecido, en su nombre y en el de sus hijos menores, demandó a Ismael, al "Club de Golf Terramar", a "La Estrella S.A. de Seguros" y a "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros", y solicitó una indemnización de 281.237 € de las tres primeras y de 1.803 € de la cuarta.

El JPI nº 2 de Vilanova i la Geltrú (22.5.1996) estimó en parte la demanda y condenó al pago de 111.908 €, con el límite de 1.803 € para "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros". La AP de Barcelona (Sección 15ª, 12.5.1999) estimó los recursos de "Club de Golf Terramar", "La Estrella S.A. de Seguros" e Ismael, a quienes absolvió.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por Lucía:

"La idea del riesgo, fundada en la explotación de actividades, industrias, instrumentos o materiales peligrosos, y en los beneficios que a través de ello se obtienen, en modo alguno puede trasladarse a la práctica deportiva, no organizativa, para fundamentar un régimen de responsabilidad distinto del de la culpa. Se asume el riesgo desde la idea de que se conoce y se participa de él y de que el jugador es consciente de que no existe en el desarrollo de una buena práctica deportiva, más allá de lo que impone la actividad en concreto, porque confía en la actuación de los demás" (F.D. 3º).

Así, la regla de no responsabilidad consigue básicamente dos cosas: potencia la libertad individual o colectiva por el procedimiento de demarcar o fijar los límites de las actividades por cuyo desarrollo y consecuencias no se habrá de responder, y ahorra de paso los costes de compensar accidentes, caso por caso, por responsabilidad civil, que es una institución jurídica muy cara de gestionar (típicamente por cada euro gastado en un caso litigado y ganado por el demandante, la mitad, cincuenta céntimos, se quedan por el camino).

Su contraria, una regla de responsabilidad absoluta y universal, por todos los daños derivados de la convivencia, del roce social, nos arruinaría a todos, nos paralizaría y la sociedad colapsaría en pocos años. Nadie defiende seriamente semejante totalitarismo del derecho de daños. No existe tal regla en ningún ordenamiento del mundo. Asombrosamente, muchos la piden. Sin pensar.

1.2. La causación dolosa, intencional, de daños

Es el caso más grave y, desde luego, es difícil encontrar un supuesto de causación intencional de daños, sobre todo si tiene como consecuencia la muerte o las lesiones de la víctima, que no constituya un delito o una falta tipificados por el Código Penal, además de ser un ilícito civil. Pero, en todo caso, junto con la responsabilidad penal surgirá la civil, la cual, con independencia

de la anterior, obligará al imputado o a las personas de quienes dependiera a reparar los daños causados.

El dolo es grave en todos los sistemas jurídicos históricos y contemporáneos y es intuitivo que así sea:

- La probabilidad de causar dolosamente un daño suele ser mayor que la de causar el mismo tipo de daño con una conducta similar pero simplemente descuidada o negligente.

- Luego, el causante doloso de daños destruye riqueza dos veces: cuando se hace con el instrumento dañino y cuando lo usa.

- Finalmente, la psicología explica bien por qué los miembros de casi cualquier sociedad reaccionan de manera mucho más intensamente hostil contra quienes les causan daños de intento, a sabiendas y, a menudo, con la precisa voluntad de hacer daño. En el fondo, el principio básico de justicia correctiva, de retribución, en cuya virtud quien ha causado un daño -y sobre todo, quien lo ha causado a ciencia y conciencia-- ha de pagar por ello está presente en todas la culturas históricas y contemporáneas (Neil VIDMAR, "Retribution and Revenge", en Joseph SANDERS/V. Lee HAMILTON [Eds.], *Handbook of Justice Research in Law*, reprint of 1st ed. 2001, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2010). El reto más serio al análisis económico del derecho de daños proviene de la psicología y de la psicología social, que muestran tanto que la conducta humana no siempre es económicamente racional como que la revancha, el rencor y el resentimiento forman parte de la condición humana. Otra cosa es que, paradójicamente, castigar pueda ser mucho más costoso para la víctima que perdonar y olvidar (Kevin M. CARLSMITH/Daniel T. GILBERT/Timothy T. WILSON, "The Paradoxical Consequences of Revenge", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 95, No. 6, 2008, p. 1316–1324).

1.3. La regla de la negligencia

La causación de daños por culpa o negligencia, por descuido más o menos grave, es decir, por no haber puesto en práctica, al desarrollar tal o cual actividad, las precauciones razonablemente exigibles, es el supuesto de partida de nuestro sistema jurídico en derecho privado: todos estamos sujetos a deberes de cuidado, de precaución, y si al llevar a cabo una actividad los infringimos, habremos de responder civilmente por los daños causados, es decir, habremos de repararlos, normalmente, indemnizando al demandante.

Además de definirse como infracción de deberes de cuidado, la negligencia puede caracterizarse como creación o incremento irrazonable de riesgos: toda actividad humana comporta riesgos –si estoy resfriado y salgo de casa puedo contagiar a las personas que se acerquen a mí-, pero la mayor parte de los riesgos normalmente asociados a una conducta son riesgos permitidos –ni la ley ni los tribunales me obligan a quedarme encerrado en casa por un simple resfriado-. Mi responsabilidad comienza allí donde el nivel razonable, socialmente admisible, económicamente sostenible, psicológicamente tolerable, éticamente soportable de riesgos sobrepasa el umbral de los riesgos permitidos –si soy un médico internista y he de trabajar en una unidad de cuidados intensivos, tal vez deba abstenerme de acudir a mi hospital si estoy muy constipado; si soy seropositivo de VIH, habré de abstenerme de tener contactos sexuales sin protección adecuada-.

La regla de la responsabilidad por culpa o negligencia está presupuesta en el art. 1902 del Código Civil, pero no está definida allí.

El análisis doctrinal del *tort* de la *Negligence* en el *Common Law* distingue varios elementos -tres, cuatro o cinco, según los puntos de vista [David G. OWEN, "The Five elements of Negligence" 35 Hofstra L.R. 1671 (2007)]:

1) y 2) Existencia de un deber de precaución o de cuidado, establecido por la ley, los reglamentos o la jurisprudencia, que desarrolla la ley o que concreta estándares sociales de razonabilidad en cada sector de actividad (*Duty of care*); e infracción de tal deber (*Breach of*

duty. En la cultura jurídica alemana se habla parecidamente de *Verkehrspflichten*, "deberes del tráfico" atendidas las circunstancias, de acuerdo con el criterio de un tercero, observador razonable). Si se prefiere, se puede concebir la negligencia como la creación o incrementos irrazonables de un riesgo de causar un daño, pero este punto de vista tiene ventajas (permite cuantificar mejor la gravedad del riesgo generado o incrementado) e inconvenientes (oscurece la doble caracterización del deber y de su infracción).

La idea, escribe Shavell, es "that an injurer is held liable for the accident losses he causes only if he was negligent, that is only if his level of care was less than a level called due care that the courts specify" (*Foundations*, p. 180).

3) Daño, causado a los bienes sobre los cuales el demandante tiene algún derecho de propiedad o similar (*property harm*); o daño causado a su persona: muerte (*wrongful death*, en cuyo caso el demandante no será obviamente la víctima), daño corporal (*bodily injury*), pero también daños morales (*pain and suffering*); también daños puramente económicos (*economic losses*), es decir, no derivados de un daño personal o material, pero solo en algunos casos.

4) y 5) Causalidad naturalística o de hecho (*cause of fact*) y de Derecho o imputación objetiva (*proximate causation, scope of liability*). Relación entre la causa, la conducta precisamente negligente del demandado, y el efecto, el daño sufrido por la víctima. Para la causalidad de hecho, suele seguirse el test de la *condicio sine qua non, But-For test*: de no haber sido por la negligencia del demandado su víctima no habría sufrido el daño causado. Mas, como veremos, el *test* es muy burdo. Los criterios de causalidad jurídica tratan de acotar el alcance infinito de la causalidad de hecho: también muy aproximadamente, requieren que entre la conducta negligente del causante material del daño y el daño mismo la relación de causalidad sea razonablemente próxima: no se condena al bisabuelo por los daños causados por alguno de sus biznietos.

Una buena definición de negligencia se encuentra en el ***§ 3 Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010), del *American Law Institute* (ALI):

"A person acts negligently if the person does not exercise reasonable care under all the circumstances. Primary factors to consider in ascertaining whether the person's conduct lacks reasonable care are the foreseeable likelihood that the person's conduct will result in harm, the foreseeable severity of any harm that may ensue, and the burden of precautions to eliminate or reduce the risk of harm".

La regla de la negligencia incentiva precaución adecuada en el agente de la actividad arriesgada, peligrosa, pero ninguna en su víctima potencial (si el daño que puede sufrir es compensable, reparable: muchos no lo son y sus víctimas potenciales tratan por ello de evitar sufrirlos).

La regla de la negligencia simple mira solo al causante potencial de daños, al demandado, no a su víctima potencial, al demandante ni a su conducta. La unilateralidad de la regla de la negligencia, su falta de consideración al comportamiento de la víctima potencial no es, por definición, problema alguno en la causación precisamente unilateral de daños, es decir, en un acontencimiento dañoso tal que la víctima nada pudo hacer por evitar o paliar el daño causado.

Así, un ejemplo posible de negligencia médica (*medical malpractice*) –aunque se discutió en el caso- es el planteado y resuelto por la **STS, 1ª, 1152/2002, de 29 de noviembre**: el cirujano demandado había intervenido quirúrgicamente, en diciembre de 1974, a un hombre de 34 años de edad para extirparle un tumor en su espina dorsal. Durante la operación, el cirujano dejó olvidada una gasa alrededor de la columna lumbar del paciente y, por ello, hubo de intervenirle de nuevo tres meses más tarde para retirarla. Con posteridad a esta segunda operación, el paciente presentó unas secuelas irreversibles que dieron lugar a su incapacidad permanente y demandó al cirujano una indemnización de 240.000 euros.

Otro caso, esta vez, absolutamente claro, de negligencia unilateral es el que resolvió la **STS, 1ª, 813/1997, de 26 de septiembre**, que trataremos al inicio de la sesión 3ª: la víctima, una mujer de edad madura, se había sometido, a principios de año 1984, a una operación de extirpación

de un quiste ovárico en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Un tornillo minúsculo (4x3 mm.) se soltó de uno de los aparatos empleados durante la intervención, pero ni el el cirujano ni sus ayudantes se percataron de ello. Años después, la presencia del tornillo en el abdomen de la víctima fue detectada casualmente con ocasión de unas radiografías practicadas a la paciente con motivo de un accidente doméstico. En junio de 1987, operaron de nuevo a la actora para retirarle el tornillo que había acabado por adherirse a su útero, por lo que fue preciso practicarle una histerectomía. La víctima demandó al cirujano de la primera intervención y al Instituto Nacional de Salud (INSALUD) del que dependía. En la demanda solicitaba una indemnización de 60.000 euros, que le fueron concedidas por la primera instancia. La Audiencia Provincial de Zaragoza y el Tribunal Supremo desestimaron el recurso presentado por el INSALUD.

La **STS, 1ª, 340/2011, de 20 de mayo** recoge la doctrina jurisprudencial según la cual la responsabilidad civil del médico es en todo caso por negligencia: el 30.6.2005, Agustina, de 52 años, fue intervenida en la Clínica Clideba (Badajoz) de artrodesis instrumentalizada lumbar L4-L5 con tornillos pediculares y prótesis espaciadora intersomáticas por presentar espondilolistesis L4-L5 estenosis del canal L4-L5 y hernia foraminal L5-S1. Tras dicha intervención, se detectó la existencia de un sangrado abdominal precisándose el traslado de la paciente al Hospital Infanta Cristina, donde se procedió a ligar la arteria hipogástrica y al lavado de la cavidad. El 11.7.2005, Agustina fue reintervenida quirúrgicamente de sigma, pero falleció el 4.8.2005. La causa de la muerte fue el shock séptico inducido por la ligadura de la arteria mesentérica inferior, que, a su vez, había provocado una falta de riego y consiguiente necrosis isquémica del sigma del paciente y posterior sepsis al perforarse el sigma con desalojo de material fecal de la propia paciente.

Gaspar y sus cinco hijos, Maximino, Vicente, Abelardo, Zaira y Daniela (marido e hijos de Agustina) demandaron a Eugenio (neurocirujano), a la Compañía de Seguros Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) y a la Compañía de Seguros Caser Salud, en reclamación de la suma de 525.000 euros.

El JPI nº1 de Badajoz (28.5.2007) estimó en parte la demanda y condenó a la Compañía de Seguros Caser Salud al pago de 46.583,47€ a Gaspar, 7.763,91€ a Daniela y 3.881,95€ al resto de los demandantes.

La AP de Badajoz (Sección 2ª, 16.11.2007) desestimó sendos recursos de apelación interpuestos por Gaspar y sus cinco hijos y la Compañía de Seguros Caser Salud.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por los actores:

"La obligación del médico es de medios y no de resultados y estos medios que se deben poner a disposición del paciente se deben valorar no sólo en función de la economía del contrato de prestación de servicios médico-sanitarios sino en razón a los que derivan de esta relación y conoce la paciente, sin que sea posible cuestionar la actuación médico-sanitaria fundándose en la evolución posterior de la misma, lo que se conoce como la prohibición de regreso, para responsabilizar al médico de la materialización de un riesgo excepcional del que había sido previamente informada la paciente, que hacía innecesarios más medios de los que se disponían en esos momentos en una previsión lógica y ponderada de la intervención quirúrgica llevada a cabo." (FD 2º). Además, "[…] la responsabilidad fundada en la Ley de Consumidores y Usuarios no afecta a los actos médicos propiamente dichos, dado que es inherente a los mismos la aplicación de criterios de responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la *lex artis ad hoc*. Por consiguiente, la responsabilidad establecida por la legislación de consumidores únicamente es aplicable en relación con los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios." (FD 3º)

Adelantemos que la regla de responsabilidad por negligencia permite controlar bien la calidad de la actividad, pero no su cantidad, el nivel de la actividad misma. Baste hoy con dejar dicho que la regla de la negligencia solo funciona bien si su contenido captura todas las dimensiones de la precaución (la calidad exigible de la actividad, pero también su nivel o cantidad, por ejemplo). Dicho sea a modo de ejemplo: un cirujano precavido interviene a sus pacientes, de

acuerdo con las reglas de la profesión médica, la *lex artis*, pero no trabaja 24 horas seguidas sino que descansa entre operación y operación.

Sobre el concepto económico de negligencia en *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F2d Cr. 1947), el caso de derecho de daños más famoso del siglo XX, véase el apartado 2.2.3.

1.4. La regla de la responsabilidad objetiva

El tercer gran supuesto de responsabilidad civil es la denominada responsabilidad objetiva o por riesgo, que cubre los casos en los cuales el demandado responde por los daños que ha causado simplemente por haberlo hecho aunque no haya habido ningún género de culpa o negligencia –ningún incremento irrazonable de riesgos o ninguna infracción de deberes de cuidado--.

En el derecho comparado de los países tecnológica y económicamente avanzados, el criterio más común en esta materia es que la responsabilidad objetiva requiere una decisión legal que la establezca o una jurisprudencia que la justifique sostenidamente. En el derecho español, la responsabilidad objetiva no es la regla general de defecto de llegada en derecho privado – lo es la responsabilidad por culpa, art. 1902 CC—, pero, por razones históricas asociadas con la pobreza endémica de nuestro país y la influencia del derecho de la expropiación forzosa, es el principio general del cual partió el legislador administrativo al establecer la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, art. 139 L. 30/1992. Sin embargo, el sistema es impracticable –por ejemplo, no se puede aplicar a los casos de responsabilidad por omisión— y en la vida legal cotidiana, las soluciones a las que llega la Sala 3ª del Tribunal Supremo (que parte de un estándar de responsabilidad objetiva) no son muy distintas de aquellas adoptadas por su Sala 1ª (que lo hace de otro de negligencia): dicho en términos aproximados, sería contrario al buen sentido que el paciente de una clínica privada dispusiera de una pretensión por daños culposos mientras que el de un hospital público tuviera una pretensión por responsabilidad objetiva; o que el alumno de una escuela privada estuviera sujeto a un régimen distinto al de una escuela pública. Tiempo habrá de discutir esta cuestión, pero aquí bastará con dejar apuntado que los regímenes de responsabilidad han de establecerse, en su caso, por sectores o tipos de actividad, no por la condición, pública o privada, de quienes la realizan. Con todas las salvedades que correspondan, el principio general es que una actividad que pueden llevar a cabo tanto agentes públicos como privados ha de estar sujeta a un mismo régimen de responsabilidad por daños. A igualdad de actividad corresponde igualdad de estándar de responsabilidad.

De acuerdo con la regla de la responsabilidad objetiva, los agentes sociales responden por todos los daños que causan aunque no hayan incurrido en culpa o negligencia alguna: es responsabilidad por mera causación de daños, por creación de un riesgo que, en el caso, se concreta en un daño sufrido por un tercero.

La responsabilidad objetiva se llama, en inglés, *strict liability*: "injurers must pay for all accidents losses that they cause" (Shavell, *Foundations*, p. 179).Los alemanes hablan de *Gefährdungshaftung,* responsabilidad por riesgo. Y los italianos de *responsabilità per rischio*. En España, algunos autores escriben "responsabilidad objetiva" y otros "responsabilidad por riesgo". En este e-libro se sigue la primera convención.

La regla de la responsabilidad objetiva incentiva a los causantes potenciales de daños a adoptar los niveles requeridos de precaución, pero no incentiva a sus víctimas potenciales a adoptar ningún género de cuidado (siempre que los daños puedan ser reparados sin demasiados problemas, muchos no pueden serlo: solo se muere una vez, por ejemplo). Asimismo, la responsabilidad objetiva permite controlar no sólo la calidad de la precaución de los agentes de actividad, sino también su nivel mismo de actividad, también la cantidad, por tanto.

En derecho privado español, la responsabilidad objetiva no es la regla general, sino que requiere mandato legal, al menos en principio:

- Accidentes de circulación: Real Decreto Legislativo 8/2004**,** de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

- Administraciones públicas: arts. 139 y ss. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Animales: art. 1905 CC.

- Caza: art. 33.5 Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza

- Cosas que se arrojen o caigan de una casa: art. 1910 CC

- Energía nuclear: art. 45 Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.

- Medio ambiente: Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

- Navegación aérea: art. 120 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea

- Productos defectuosos: Art. 1 de la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos; arts. 128 y ss. RDL 1/1007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

- Responsabilidad del propietario por los humos excesivos nocivos para las personas o las propiedades y caída de árboles colocados en sitios de tránsito: art. 1908. 2º y 3º CC.

- Servicios: arts. 147-148 RDL 1/2007

STS, 1ª, 581/2007, de 28 de mayo. Accidente en helicóptero

José Augusto trabajaba como retén de incendios forestales para "TRAGSA", sociedad que había contratado con "HELICSA" los medios aéreos para la campaña 1991-92. El 18.9.1992, a causa de una tormenta, el helicóptero que transportaba a José Augusto se vio afectado por una turbulencia, chocó contra la ladera de una montaña y se incendió. Como consecuencia del accidente, José Augusto resultó herido y sufrió una incapacidad permanente total.

José Augusto demandó a "HELICSA" y a su aseguradora, "Allianz", en solicitud de una indemnización de 135.040,03 €.

El JPI de Purchena (23.9.1998) estimó la demanda. La AP de Almería (Sección 2ª, 31.3.2000) estimó en parte el recurso de apelación de los demandados, condenándoles a pagar 18.030,36 €.

El TS estimó en parte el recurso de casación interpuesto por José Augusto e incrementó el importe de la indemnización a 21.035.42 €. Si bien el accidente aéreo constituyó un caso fortuito, sostuvo el Tribunal, el transportista está sujeto a un régimen de responsabilidad objetiva con limitación del quantum indemnizatorio que no admite moderación alguna por los tribunales (art. 120 Ley de Navegación Aérea).

— Compárese esta resolución con la **STS, 1ª, 595/2012, de 23 de octubre**, en la que el demandante, aprendiz de piloto herido durante un examen de vuelo mientras otro aspirante estaba a los mandos, no obtiene indemnización al no ser considerado pasajero. El tribunal concluye que "la asunción del riesgo de volar tiene mucha más intensidad para los aspirantes a la licencia que para los pasajeros de líneas aéreas o aeronaves autorizadas para el transporte de viajeros, ya que mientras que en el transporte la regla general es evitar maniobras arriesgadas, en cambio la enseñanza del vuelo y los exámenes correspondientes comportan por sí maniobras

que simulen situaciones apuradas (…). Se produce así (…) una asunción de riesgos compartidos por todos los tripulantes de la aeronave que no permite imponer a su propietaria (…) un régimen de responsabilidad objetiva" (FD 3º).

STS, 1ª, 1243/2007, de 4 de diciembre. Caída de una maceta desde el quinto piso de un edificio

El 21.7.1989, una mujer de 65 años de edad, falleció como consecuencia de ser golpeada en la cabeza por una maceta que, durante un fuerte temporal de viento, cayó desde el quinto piso de un inmueble de Madrid. La propietaria había arrendado el inmueble a Carina y tenía contratado un seguro multirriesgo de comunidades de propietarios con "AGF Unión Fénix, S.A.".

Bernardo, viudo de la fallecida, demandó a Romeo, Luis Enrique y Lourdes, viudo e hijos de la propietaria del piso, "AGF Unión Fénix, S.A." y Carina, arrendataria del piso, y solicitó una indemnización de 90.151,82 €.

El JPI núm. 58 de Madrid (11.7.1997) estimó en parte la demanda, condenó a Carina a pagar 48.080,97 € y absolvió al resto de demandados. La AP de Madrid (Sección 13ª, 12.7.2000) desestimó el recurso de apelación interpuesto por Carina y estimó el de Bernardo en el sentido de condenar a todos los demandados a pagar 60.101,21 €.

El TS estimó los recursos de casación interpuestos por Romeo, Luis Enrique, Lourdes y la aseguradora, a quienes absolvió. La propietaria no incurrió en negligencia por no haber advertido a la inquilina del peligro que representaban las macetas, pues ello supone "(...) la imposición al propietario-arrendador de un exacerbado deber de vigilancia o supervisión en la conducta del inquilino" (FD 2º).

Capítulo 3º
Negligencia (I): Circunstancias de la negligencia

1. Infracción de deberes de precaución **38**
2. Circunstancias personales del demandado **43**
3. Riqueza del demandado **50**
4. Conocimientos especiales y habilidades particulares del demandado **50**
5. Circunstancias personales de la víctima **52**
6. Situaciones de peligro que requieren acción inmediata: *Sudden emergency doctrine* **52**

1. Infracción de deberes de precaución

— Encarna ROCA TRIAS/Mónica NAVARO MICHEL, *Derecho de daños*, 6ª ed., 2011, pp. 27-28:

"El retorno a la culpa como criterio de imputación": "el Tribunal Supremo ha vuelto a los criterios de imputación subjetiva" [a la culpa como criterio general por oposición a la responsabilidad objetiva].

La regla de la negligencia es el supuesto de partida del derecho de daños, está presupuesta en el art. 1902 del Código Civil, pero no definida allí. Una explicación tradicional de la culpa o negligencia alude a la idea de infracción de deberes de precaución o cuidado (*breach of a duty of care* en el *Common Law*, o incumplimiento de *Verkehrspflichten* en la cultura jurídica alemana).

La ley, los reglamentos o el juez especifican niveles razonables de precaución o cuidado para tales o cuales actividades humanas, cuya inobservancia por parte del causante de daños llevará a que haya de asumirlos y compensar a la víctima o al perjudicado.

La **STS, 1ª, 679/2010, de 10 de diciembre** resuelve un supuesto de responsabilidad civil médica por error de diagnóstico y, al hacerlo, identifica un deber de precaución del médico general consistente en la remisión del paciente a un facultativo especialista antes determinadas sintomatologías.

El 12.12.1996, Eva se sintió súbitamente enferma, perdió el habla, sintió cosquilleos con adormecimiento y pérdida de la fuerza en el brazo derecho. Acudió al Hospital General de Caranza, donde fue atendida de urgencias por el médico de guardia Pío, quien le diagnosticó una bajada de azúcar, le inyectó glucosa y le dio de alta. Tres días después, Eva volvió a presentar la misma sintomatología y acudió nuevamente al mismo servicio de urgencias, donde fue atendida por el doctor Luis Miguel, quien ordenó su ingreso. En la madrugada del día siguiente, ante la situación de la paciente, el doctor Carlos decidió trasladarla a un nuevo centro hospitalario donde se le pudo realizar un TAC. En el nuevo centro se le diagnosticó un infarto isquémico cerebral. Como consecuencia de ello, Eva quedó con una afasia de tipo motor, problemas en el habla, alexia, agrafía, parálisis espástica de extremidad superior derecha con contractura en flexión de dedos y parálisis espática en la extremidad inferior derecha.

Eva demandó a los médicos Pío, a Luis Miguel, a Carlos, al "Hospital General de Caranza Ferrol" y a las compañías de seguros "Compañía de Seguros Aegon" y "Compañía de Seguros Ama Previsión Sanitaria S.L." y solicitó una indemnización de 780.000 euros por los daños y perjuicios sufridos.

EL JPI núm. 6 de Ferrol (16.2.2004) desestimó la demanda. La AP de La Coruña (Sección 5ª, 4.12.2006) desestimó el recurso de apelación.

El TS estimó en parte el recurso de casación interpuesto por la actora y condenó a Pío y a las compañías de seguros (a estas hasta el límite de los seguros concertados) al pago de 235.112,98 euros. Se deberían "haber agotado los medios que la ciencia médica pone a su alcance para determinar la patología correcta cuando era posible hacerlo, como manifestó el propio perito, bien mediante la realización de las pruebas pertinentes, bien previa consulta de algún especialista en neurología si por razón de la especialización de quien en esos momentos le atendía (medicina general), no estaba en condiciones de detectar y prevenir un ictus en evolución. Faltaron en el caso los conocimientos médicos necesarios para hacer posible el diagnóstico que hubiera prevenido o evitado la obstrucción completa de la arteria carótida a partir de una previa sintomatología neurológica que no fue detectada por el médico de guardia, como "sin duda" lo habría hecho el perito, lo que a la postre no viene sino a indicar que cualquier otro médico con una base mínima de conocimientos para estos supuestos o supliendo sus carencias mediante un consejo médico complementario, habría detectado de inmediato la razón de su ingreso y le hubiera proporcionado con la urgencia y diligencia necesaria todos los medios curativos de que disponía" (FD 2º).

El derecho de daños puede contribuir a reducir los costes de los accidentes por el procedimiento de establecer niveles razonables de precaución y hacer cargar a quienes no los cumplan con las consecuencias (Pablo SALVADOR/Carlos GÓMEZ, "El Derecho de Daños y la Minimización de los Costes de los Accidentes", *InDret* 1/2005 (www.indret.com). Si se asume que el objetivo es minimizar los costes de los accidentes, ello resultará algo sencillo de conseguir en algunos casos, pero de dificultad variable y creciente en otros, como se muestra a continuación:

1. En un primer caso resuelto por la **STS, 1ª, 577/2012, de 17 de octubre**, la empresa Talleres Ballespí SL instaló en 2005 una puerta corredera de hierro –de 6,050 metros de ancho por 4,015 de alto- en el cementerio municipal de Lleida. Cuatro días después de la instalación, a primera hora de la jornada laboral, Simón, trabajador de 48 años empleado por Pintura y Decoración SL, comenzó a pintar la puerta y ésta se salió de la guía superior, le cayó encima y le causó un traumatismo torácico y múltiples fracturas, a resultas de las cuales fue declarada su incapacidad permanente absoluta.

El trabajador demandó a Talleres Ballespí SL y a su aseguradora Reale Seguros Generales SA y solicitó una indemnización de 172.911,84 euros. El JPI núm. 6 de Lleida desestimó la demanda por sentencia de 19.11.2007. La AP de Lleida, Sección 2ª, estimó en sentencia de 26.10.2009 el recurso de apelación, revocó el fallo del JPI y condenó a las sociedades demandadas a indemnizar al actor en 169.220,10 €.

El TS confirmó la sentencia de apelación y argumentó que:

"1ª) La empresa dedicada a la instalación de puertas y que instala en un cementerio municipal una puerta corredera metálica de seis metros de anchura por cuatro de altura debe hacerlo en condiciones de evitar que la puerta caiga no solo sobre los trabajadores de la obra del cementerio sino sobre cualesquiera personas que en el futuro visitaran el cementerio o pasaran por la puerta.

2ª) Entre los riesgos naturales de la vida no se encuentra el de que una puerta de semejantes dimensiones se desplome sobre quien se acerca a ella.

3ª) En el presente litigio no se juzga la responsabilidad de la empresa empleadora del perjudicado, sino la de la empresa que instaló la puerta. El problema no es, por tanto, de medidas de seguridad para el trabajador, sino de instalación de la puerta en las condiciones debidas para que no se desplome sobre persona alguna, trabajador o no de la obra.

4ª) El dato de la instalación de la puerta cuatro días antes del hecho dañoso, que en el motivo se invoca a favor de la empresa que hizo la instalación, justifica en realidad el juicio de imputación de la sentencia recurrida, pues demuestra una evidente proximidad temporal entre la instalación y el desplome de la puerta.

5ª) Es insostenible que la mera existencia de gravilla en la parte inferior de la puerta pueda provocar su desplome. Es más, si así fuera se vendría a demostrar su defectuosa instalación. Y no menos insostenible es que por la mera existencia de una empresa contratista quede exonerada de responsabilidad la empresa subcontratada precisamente para la instalación de la puerta como empresa especializada.

6ª) En definitiva, el hecho también indubitado de que los topes o espárragos se habían salido de la guía superior de la puerta justifica el juicio de imputación del tribunal sentenciador por la posición de garante (SSTS 20-12-11 , 30-10-09 y 5-3-09) que con la instalación de la puerta asumía la empresa instaladora.

7ª) En función de lo anterior, tampoco un mero cierre defectuoso de la puerta el día anterior exoneraría de su responsabilidad a la empresa instaladora, salvo prueba de una maniobra tan negligente o malintencionada que hubiera llegado al extremo de sacar los topes de la puerta de su guía superior, también instalada por la misma empresa" (FD 5º).

Se trata de un caso claro de negligencia unilateral, es decir, de un supuesto en el cual la víctima nada podía haber hecho para evitar el daño que finalmente sufrió, cuando, además, queda bien a las claras que los demandados podían haber adoptado más y mejores precauciones.

El caso siguiente plantea más dificultades tanto a la hora de identificar a los responsables de los daños sufridos por la víctima como a la de concretar los niveles de precaución que podrían haberse adoptado para evitarlos:

2. Una mañana del mes de marzo de 1992, la víctima esperaba la llegada del Metro en la estación de la calle Rocafort de Barcelona. El convoy llegó, abrió las puertas y la abigarrada muchedumbre que esperaba en el andén se abalanzó hacia el interior de los vagones. Empujada por el resto de viajeros, la víctima cayó al suelo y sufrió lesiones de gravedad por las que reclamó un total de 37.743,55 euros a la entidad "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA" gestora del servicio público de transporte por metro en la ciudad de Barcelona cuando de produjo el accidente. La Audiencia Provincial estimó el recurso de la víctima contra la sentencia desestimatoria de la demanda de la primera instancia y concedió una indemnización de 28.518,02 euros con cargo a la entidad demandada. La **STS, 1ª, 1121/2001, de 3 de diciembre**, que puso fin al proceso, desoyó los argumentos de "Ferrocarril Metropolità" y convalidó la condena decidida por la Audiencia de Barcelona.

El tercer caso que presentamos a continuación manifiesta aún más palmariamente las dificultades de atribuir responsabilidad al titular de una organización por los daños causados por un tercero ajeno al ámbito de influencia de la organización misma:

3. En la madrugada del 6 de mayo de 1990, la Sra. Ángela M.R. entró en una de las oficinas de la entidad bancaria demandada para retirar dinero de un cajero automático. En nuestro país, algunas oficinas de bancos y cajas disponen de cajeros a pie de calle, pero es más frecuente que tras la puerta de entrada de la oficina, haya un primer espacio en el que están instalados uno o varios cajeros automáticos, que pueden ser usados, por lo general, las 24 horas del día. La puerta de acceso a este local puede cerrarse con un pestillo. Durante las horas de oficina, los clientes pueden superar este espacio y entrar donde se encuentran los empleados que ofrecen los servicios bancarios de que se trate. En el asunto, el pestillo de la puerta estaba roto y un atracador, que estaba al acecho, entró en el local cuando la víctima ya había tecleado el número secreto de su tarjeta de crédito. Forcejearon, el atracador sacó una navaja con la que hirió a la actora en su mano izquierda y le robó la cantidad retirada. La víctima reclamó 90.152 euros a la entidad bancaria titular del cajero automático. En primera instancia, su demanda fue estimada en parte, pero la entidad demandada recurrió en apelación y la Audiencia Provincial desestimó íntegramente la demanda. El Tribunal Supremo, en **STS, 1ª, 255/1997, de 1 de abril**, desestimó el recurso de la víctima: "[…] no puede afirmarse que las lesiones sufridas por la recurrente al ser asaltada por un desconocido, sean una consecuencia […] del estado en que se encontraba el cerrojo instalado en la puerta de acceso al cajero automático y que impedía cerrar la puerta desde el interior, sino que tales lesiones son imputables exclusivamente, en una

relación de causa a efecto, a la violencia ejercida sobre la actora por el tercero desconocido que la atacó" (FD 2º).

En ocasiones, quien causa el accidente es su víctima. En otras, el responsable nada tuvo que ver con el accidente que motiva finalmente su responsabilidad. En unas terceras, la víctima carga con las consecuencias del daño que sufre. La imputación de daños no depende siempre del relato causal. Así lo confirman los dos casos siguientes.

4. La **STS, 1ª, 2034/1997, de 31 de diciembre** condenó a la Red Nacional de Ferrocarriles (RENFE) por la muerte de dos menores de edad quienes, durante las fiestas mayores del pueblo de Manzanares (Madrid), jugaban con sus compañeros a ver quién aguantaba más sobre la vía del tren cuando se acercaba la locomotora. RENFE había denunciado varias veces los hechos al Ayuntamiento de Manzanares que había ordenado vigilar la zona durante unas horas al día. Fuera de ellas, grupos de muchachos volvían a la vía para hablar, reír, beber y jugarse la vida. El día 21 de julio de 1990, Miguel Ángel C. y José Gabriel P., ambos de quince años, estaban de pie sobre las vías, con 0,92 gramos de alcohol por litro de sangre el primero, cuando un Tren Expreso que circulaba a 130 km/h., les arrolló. Ambos murieron en el acto. Los padres de las víctimas reclamaron una indemnización de 150.253 euros al Ayuntamiento de Manzanares, a RENFE y al maquinista del tren. Las instancias condenaron únicamente a RENFE y al Ayuntamiento a pagar 36.061 euros a cada uno de los demandantes. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la compañía ferroviaria. La actividad de los jóvenes, en absoluto justificable, era conocida y debían haberse adoptado todas las medidas necesarias, incluso la detención del convoy a su paso por el pueblo, para evitar daños como los que sucedieron (cfr. STS, 1ª, 44/2010, de 18 de febrero).

5. El demandante en el proceso que resolvió la **STS, 1ª, de 10 de octubre de 1998** era un trabajador de una empresa de productos congelados a quien una máquina termoselladora le amputó la mano derecha. Inmediatamente después del accidente, la enfermera de la empresa acudió al lugar de los hechos para atender al trabajador, cortó la hemorragia e instruyó a un compañero del trabajador para que envolviera la mano traumáticamente amputada en hielo natural. Mientras esperaban a la ambulancia, el compañero de la víctima metió la mano amputada en una caja de *porexpan* llena de dióxido de carbono sólido, comúnmente conocido como hielo seco, de las que utilizaban para el transporte de productos congelados, pues creía que procuraría una mejor conservación de la mano. Cuando la víctima fue ingresada en el centro sanitario los tejidos de la mano amputada estaban destruidos por congelación y no fue posible practicar el implante. El trabajador quedó manco de por vida y demanda a la empresa y a la enfermera de la misma por no haber comprobado cómo se trasladó la mano amputada al hospital. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron la concesión de 120.202 € que el demandante reclama, pero el Tribunal Supremo condenó a la enfermera a pagar una indemnización de 9.015 euros. La enfermera no fue del todo diligente y debía responder por la pérdida de las expectativas de reimplantar el miembro amputado.

6. La **STS, 1ª, 139/2011, de 14 de marzo** resuelve un supuesto de negligencia bilateral o concurrencia de culpas. El 13.8.2000, alrededor de las 12 del mediodía, una embarcación a motor conducida por Máximo atropelló a Fermín cuando practicaba submarinismo a unos 100-150 metros de la costa. En el momento del accidente, Fermín tenía problemas de oído y no iba acompañado de barca ni boya de señalización. La embarcación circulaba a unos 10 nudos de velocidad y había olas de más de un metro de altura. Como consecuencia del atropello, Fermín sufrió lesiones irreversibles que determinaron su incapacidad permanente.

En el procedimiento penal iniciado por estos hechos, el JI núm. 3 de Tortosa condenó al piloto de la embarcación. La AP revocó la SJI y lo absolvió, porque las dudas existentes sobre el lugar exacto en que había ocurrido el accidente impedían imputarle un comportamiento negligente.

Fermín demanda a Máximo, a Otilia (propietaria del barco) y a Zurich España S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, y solicita una indemnización de daños y perjuicios (no consta la cuantía).

El JPI núm. 49 de Barcelona (23.3.2005) estima en parte la demanda, considera que la conducta negligente del actor contribuyó en un 25% al accidente y que la conducta negligente del

conductor contribuyó en un 75%. El submarinista debió llevar una boya de señalización, como establece el art. 1 Orden del Ministerio de Fomento de 14.10.1997, y el conductor de la embarcación debió reducir la velocidad de la embarcación a unos 3 nudos, como establece el art. 69.2 Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: "En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa. Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a tres nudos, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad humana. Estará prohibido cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones". En aplicación de la regla de concurrencia de culpas, el JPI condena a los codemandados al pago de 216.374,36 €, límite máximo del seguro de responsabilidad civil, y al propietario y conductor de la embarcación al pago de los restantes 23.197,81 €.

La AP Barcelona (Secc. 14ª, 29.6.2006) estima en parte los recursos de apelación interpuestos por todas las partes. En relación al de Máximo y Otilia, la AP estima en un 50% el porcentaje de culpa de la víctima y del conductor, y condena a estos codemandados solidariamente junto a la compañía de seguros al pago de 167.649,52€ (límite del seguro obligatorio), así como al pago de los 21.075,06 € que completan el total del monto de la indemnización. En relación al del actor, la AP considera indemnizable conforme a baremos el daño moral complementario.

El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el actor porque "(…) ese especial deber de diligencia resulta, asimismo, de las disposiciones administrativas sobre la materia, que obligaban a reducir la velocidad en las zonas próximas a la costa, y especialmente a la playa, en previsión de la presencia de bañistas o nadadores. Pero, contrariamente a lo que se sostiene, no es circunstancia que excluya la posibilidad de imputar el resultado al comportamiento culpable del agente el que la embarcación impactase con la víctima más allá de los límites acotados reglamentariamente para el baño. Consta acreditado que la embarcación circulaba a una velocidad elevada (no menos de diez nudos) y por una zona que, aún fuera de la acotada, seguía encontrándose relativamente próxima a la costa (a una distancia de 100 a 150 metros), donde había calas y playas cercanas, era posible el submarinismo, y en la que, atendiendo al día, hora y época del año (mediodía de un domingo del mes de agosto, época vacacional), resultaba, asimismo, presumible, una notoria afluencia de bañistas. Y en esas circunstancias, y en atención al riesgo generado, el piloto no ha probado la adopción de las especiales medidas de precaución que le eran exigibles para evitar riesgos a la vida e integridad físicas de los bañistas, las cuales no cabe circunscribir a una zona determinada desde el momento que el deber de precaución subsiste desde la puesta en marcha de la embarcación, momento en que el agente desencadena el riesgo, hasta que se detenga, y debe acomodarse en cada momento a las concretas circunstancias que se encuentre durante la conducción." (FD 3º).

7. En el caso resuelto por la **STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre**, un joven de 21 años practicaba descenso por aguas bravas en el río Gállego al cruzar un desfiladero de especial dificultad, el "Paso del Embudo" en el término municipal de Murillo (Zaragoza), cayó de la balsa neumática, se golpeó la cabeza con una roca y falleció en el acto. Poco después, el padre de la víctima demandó a la asociación organizadora de la actividad deportiva, a la compañía aseguradora y al monitor que había dirigido la actividad. Por el hecho se siguieron diligencias penales posteriormente archivadas. En el pleito civil, las sentencias de las instancias desestimaron la demanda. Igual suerte corrió el demandante en casación. Se trata de un supuesto de culpa exclusiva de la víctima o, en su caso, de concreción de los riesgos asumidos por la propia víctima.

2. Circunstancias personales del demandado

I) Edad y estado de salud

A la hora de determinar los niveles de precaución debidos o estándares de diligencia a cumplir por el causante de los daños, jueces y tribunales toman en consideración las circunstancias personales de aquél.

En cuanto a la edad, el criterio comúnmente adoptado por la mejor doctrina es que los niños de muy corta edad (los menores de 7 años aproximadamente) son inimputables –por ellos responden sus padres o guardadores ex art. 1903 CC-; es más, si el menor carece de capacidad natural –un niño de tres años de edad, por ejemplo-, no hay acción, no hay agencia social. Si el menor tiene capacidad natural –y patrimonio con el que responder-, entonces puede efectivamente ser condenado a indemnizar por los daños causados. Mas, en el derecho positivo, la cuestión solo ha sido regulada por el Código Penal, arts. 19, 118.1 y 120.1 CP y 3 y 61 y ss. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En particular, la LO 5/2000 considera penal y civilmente responsables a los menores de edad desde que cumplen los catorce años (arts. 1.1 y 61.3 LO 5/2000). Además, la doctrina mayoritaria admite la aplicabilidad del art. 1902 CC al menor civilmente imputable (Esther GÓMEZ CALLE (2006), "Los sujetos de la responsabilidad civil. La responsabilidad por hecho ajeno", en L. Fernando Reglero Campos (Coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 3ª ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, pp. 461-538, 480).

El derecho comparado de países próximos a nuestra cultura ofrece soluciones similares, pero discrepantes en el detalle de la regulación propuesta.

La jurisprudencia de la Sala 1ª del TS tiende a juzgar la conducta de los menores con edades comprendidas entre 7 y 15 años en términos de negligencia, pero el estándar de diligencia exigible es más leve que el de los adultos. Hay que tener en cuenta también que, si bien los tribunales tienden a excusar travesuras y avatares de los juegos propios de la infancia, no hacen lo mismo con la conducta claramente despreciativa de peligros que todo niño de su edad debería prever, y tampoco la conducta antijurídica: los terceros no tienen por qué anticipar y prevenir el daño conexo a un acto voluntario, arriesgado y a veces incluso ilícito cometido en vísperas de la pubertad (Josep FERRER I RIBA y Covadonga RUISÁNCHEZ CAPELASTEGUI, "Niños y adolescentes", *InDret* 1/2000, pp. 7 y ss.)

STS, 1ª, 205/2002, de 8 de marzo

Patricia G.N., de 16 años, perdió la visión casi total del ojo derecho al sufrir un balonazo en la cara, lanzado por Mariano M.Q., de 17 años, que jugaba al fútbol con unos amigos, mientras estaba sentada en un banco del jardín municipal del Paseo de la Playa de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Georgina N.M., en nombre de su hija Patricia G.N., demandó a Mariano M.Q., a sus padres (Eusebio M.S. y Dulce Nombre Q.Z.) y al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y solicitó una indemnización de 90.151,81 euros.

El JPI nº 3 de Chiclana de la Frontera (29.12.1995) desestimó la demanda. La AP de Cádiz (Sección 5ª, 10.7.1996) estimó parcialmente el recurso de casación y condenó a Mariano M.Q. y a sus padres a satisfacer a la actora una indemnización de 60.101,21 euros.

El TS desestimó el recurso de casación y confirmó la SAP. No es necesario acudir a criterios de responsabilidad por riesgo para fundamentar la responsabilidad del menor. Basta analizar la imputación subjetiva del daño: la edad (17 años, 7 meses y 22 días) y los factores psicológicos del menor indican que podía haber previsto que jugando con un balón de cuero ligeramente deshinchado en un lugar inidóneo se podían causar daños a terceros ajenos al juego. La responsabilidad de los padres tiene su fundamento en la presunción de culpa contenida en el art. 1903 CC.

II) Responsabilidad civil de menores e incapaces en derecho español

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Artículo 118.1.1:

1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes:

1. En los casos de los números 1 y 3, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables.

Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.

Artículo 120. Responsables civiles subsidiarios

Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente:
1º Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. (…)

STS, 2ª, 619/2005, de 11 de mayo

El 8.7.2002 en Medina de Pomar (Burgos), sobre las 17:30 horas, Rodrigo, nacido el 31.7.1983 (19 años), con una dotación intelectual inferior al promedio (entre la normalidad y el retraso mental leve) y educado en un contexto familiar desestructurado (abandono de la madre a los cuatro años de edad, y padre alcohólico), tras comprar en una tienda un cuchillo de unos 11 cms. de hoja, entró en la Óptica Medina Centro, sita en la misma calle que el primer establecimiento. Esperó a que la dependienta, Soledad, atendiese a otro cliente y, cuando se encontraban solos en la óptica, le solicitó que le graduase la vista, Rodrigo y Soledad entraron al gabinete habilitado al efecto y, después de realizada tal operación, Soledad se levantó para rellenar el correspondiente impreso, mientras el joven permanecía sentado. Rodrigo, entonces, clavó el cuchillo que portaba consigo en la zona abdominal de Soledad, causándole graves lesiones que tardaron 235 días en sanar y secuelas consistentes en cicatriz queloidea de 17 cms. de longitud y 1 cm. de anchura en la línea media abdominal, cicatriz de 2 cms. en hipocondrio izquierdo y síndrome de estrés postraumático. El día en que ocurrieron los hechos Rodrigo había obtenido una autorización de salida de la Residencia en la que se encontraba ingresado (Residencia Los Robles de Villasante de Montija). No consta que el titular de dicha residencia, Hogadema, S.A. (que tenía contratado el seguro de responsabilidad civil con Mapfre Industrial, S.A.), hubiera adoptado medida alguna para evitar los hechos.

La SAP Burgos, Secc. 1ª, 7.5.2004, condenó al acusado Rodrigo como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasiva durante el tiempo de la condena, y prohibición de aproximación a la víctima a una distancia inferior de 200 metros y de comunicarse en cualquier forma con ella durante cinco años. También condenó a Rodrigo a indemnizar a Soledad con 30.680 € por lesiones y con 20.000 euros por secuelas. De dichas cantidades había de responder directamente Mapfre Industrial, S.A., en solidaridad con Hogadema, S.A.

La STS, 2ª, 11.5.2005, estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por Hogadema, S.A. de manera que redujo la responsabilidad civil de esta entidad de solidaria a subsidiaria, ya que el TS consideró aplicable el art. 120.1 CP "al Organismo que tenía bajo su guarda y tutela a

quien cometió un hecho delictivo por concurrir un cierto nivel de negligencia que guarda con el delito cometido una relación de causa/efecto". Y añadió que "en la sentencia de esta Sala 1527/2001, de 21 de julio, se declara que un requisito esencial de la responsabilidad civil subsidiaria es la existencia de una relación de causalidad –a la que se refiere claramente la expresión legal «siempre que haya mediado»– entre la culpa o negligencia de quienes tengan al exento de responsabilidad criminal –total o parcialmente– bajo su potestad o guarda y la comisión por aquél de un hecho punible (…); exclusión [de la responsabilidad del centro psiquiátrico] que no puede afirmarse en el presente caso (…) ya que no se produjo una cesión temporal de la guarda de hecho a favor de la familia o de tercera persona a quien le incumbiera la responsabilidad civil subsidiaria derivada de la actuación de Rodrigo, sino que se mantuvo la guarda de hecho por parte de Hogadema, S.A. durante las salidas autorizadas por su Dirección" (FD 2º).

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores

Artículo 1. Declaración general

1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

2. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por España.

Artículo 3. Régimen de los menores de catorce años.

Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Artículo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.

1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los números 1, 2 y 3 del artículo 20 del vigente Código Penal les serán aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.

Título VIII
De la responsabilidad civil

Artículo 61. Reglas generales

1. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.

3. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos.

4. En su caso, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus disposiciones complementarias.

Artículo 62. Extensión de la responsabilidad civil

La responsabilidad civil a la que se refiere el artículo anterior se regulará, en cuanto a su extensión, por lo dispuesto en el Capítulo I del Título V del Libro I del Código Penal vigente.

III) Edad, salud y responsabilidad civil en el derecho comparado

Common Law

a) ***Restatement (Third) of Torts:***

§ 10 ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010): **Children**

"(a) A child´s conduct is negligent if it does not conform to that of a reasonable person of the same age, intelligence, and experience, except as provided by section (b) or (c).

(b) A child less than five years of age is incapable of negligence.

(c) The special rule in Subsection (a) does not apply when the child is engaging in a dangerous activity that is characteristically undertaken by adults."

§ 11 ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010)**: Disability**

(a) The conduct of an actor with a physical disability is negligent only if the conduct does not conform to that of a reasonable careful person with the same disability.

(b) The conduct of an actor during a period of sudden incapacitation or loss of consciousness resulting form physical illness is negligent only if the sudden incapacitation or loss of consciousness was reasonably foreseeable for the actor.

(c) An actor´s mental or emotional disability is not considered in determining whether conduct is negligent, unless the actor is a child.

b) *Daniels v. Evans* (224 A.2d 63 (N.H. 1966))

[Plaintiff's decedent, a 19-year-old youth, was killed when his motorcycle collided with defendant's automobile. A trial by jury resulted in a verdict for plaintiff, and the only alleged error argued on appeal was the trial court's charge pertaining to the standard of care required of the decedent].

LAMPRON, J. As to the standard of care to be applied to the conduct of the decedent Robert E. Daniels, 19 years of age, the Trial Court charged the jury in part as follows:

"Now, he is considered a minor, being under the age of twenty-one, and a minor child must exercise the care of the average child of his or her age, experience and stage of mental development. In other words, he is not held to the same degree of care as an adult."

Concededly these instructions substantially reflect the rule by which the care of a minor has been judged heretofore in the courts of our state. However an examination of the cases will reveal that in most the minors therein were engaged in activities appropriate to their age, experience and wisdom. These included being a pedestrian, riding a bicycle, riding a horse [and] coasting.

We agree that minors are entitled to be judged by standards commensurate with their age, experience, and wisdom when engaged in activities appropriate to their age, experience, and wisdom. Hence when children are walking, running, playing with toys, throwing balls, operating bicycles, sliding or engaging in other childhood activities their conduct should be judged by the rule of what is reasonable conduct under the circumstances among which are the age, experience, and stage of mental development of the minor involved.

However, the question is raised by the defendant in this case whether the standard of care applied to minors in such cases should prevail when the minor is engaged in activities normally undertaken by adults. In other words, when a minor undertakes an adult activity which can result in grave danger to others and to the minor himself if the care used in the course of the activity drops below that care which the reasonable and prudent adult would use, the defendant maintains that the minor's conduct in that instance, should meet the same standards as that of an adult.

Many recent cases have held that "when a minor assumes responsibility for the operation of so potentially dangerous an instrument as an automobile, he should . . . assume responsibility for its careful and safe operation in the light of adult standards." The rule has been recognized in Restatement (Second), Torts and in Prosser, Torts. In an annotation in [the] A.L.R. it is said that recent decisions "hold that when a minor engages in such activities as the operation of an automobile or similar power driven device, he forfeits his rights to have the reasonableness of his conduct measured by a standard commensurate with his age and is thenceforth held to the same standard as all other persons."

One of the reasons for such a rule has been stated thusly in Dellwo v. Pearson: "To give legal sanction to the operation of automobiles by teen-agers with less than ordinary care for the safety of others is impractical today, to say the least. We may take judicial notice of the hazards of automobile traffic, the frequency of accidents, the often catastrophic results of accidents, and the fact that immature individuals are no less prone to accidents than adults. . . . [I]t would be unfair to the public to permit a minor in the operation of a motor vehicle to observe any other standards of care and conduct than those expected of all others. A person observing children at play . . . may anticipate conduct that does not reach an adult standard of care or prudence. However, one cannot know whether the operator of an approaching automobile . . . is a minor or an adult, and usually cannot protect himself against youthful imprudence even if warned." [...]

RSA 262, which establishes rules of the road for the operation of motor vehicles on our highways, reads as follows: "Required obedience to traffic laws. It is unlawful and . . . a misdemeanor for any person to do any act forbidden or fail to perform any act required in this chapter." (Emphasis supplied). This is some indication of an intent on the part of our Legislature that all drivers must, and have the right to expect that others using the highways, regardless of their age and experience, will, obey the traffic laws and thus exercise the adult standard of ordinary care […].

The rule charged by the Trial Court pertaining to the standard of care to be applied by the jury to the conduct of the minor plaintiff Robert E. Daniels in the operation of the motorcycle was proper in "the bygone days" when children were using relatively innocent contrivances. See A.L.R.. However in the circumstances of today's modern life, where vehicles moved by powerful motors are readily available and used by many minors, we question the propriety of a rule which would allow such vehicles to be operated to the hazard of the public, and to the driver himself, with less than the degree of care required of an adult.

We are of the opinion that to apply to minors a more lenient standard in the operation of motor vehicles, whether an automobile or a motorcycle, than that applied to adults is unrealistic, contrary to the expressed legislative policy, and inimical to public safety. Furthermore when a minor is operating a motor vehicle there is no reason for making a distinction based on whether he is charged with primary negligence, contributory negligence, or a causal violation of a statute and we so hold.

We hold therefore that a minor operating a motor vehicle, whether an automobile or a motorcycle, must be judged by the same standard of care as an adult and the defendant's objection to the Trial Court's charge applying a different standard to the conduct of plaintiff's intestate was valid.

Exception sustained.

c) *Purtle v. Shelton* (474 S.W.2d 123 (Ark. 1971))

GEORGE ROSE SMITH, Justice.

This is an action for personal injuries suffered by Jerry Purtle, a sixteen-year-old minor, in a hunting accident during the 1969 deer hunting season. The defendants are Kenneth Shelton and his son, Kenneth, Jr., who was seventeen at the time of the accident. The jury attributed half the negligence to Jerry Purtle and half to young Shelton; so there was no recovery. For reversal the appellant, Jerry's father and next friend, contends that the trial court erred in its instructions defining the standard of care to be observed by a minor while hunting deer with a high-powered rifle.

There were some conflicts in the testimony, but the salient facts are not really in dispute. Jerry and young Kenneth had spent the night at the home of L. D. McMullen, who owned a deer camp in Union county. Early the next morning, before daylight, McMullen took the two youths (and a third lad not involved in the case) to the area where they were to hunt. Kenneth's deer stand was next to the road, but Jerry had to walk a short distance through the woods to his stand. MaMullen had cautioned both boys to make their presence known when they were walking in the woods and not to shoot at anything without knowing it to be a deer.

Jerry failed to find his stand immediately and actually walked toward Kenneth's stand, without making his presence known. Kenneth thought he saw a deer and fired at it with his 30.06 rifle. The soft projectile apparently hit a tree, broke into shrapnel, and ricocheted toward Jerry, causing serious injuries to both his eyes.

The trial court submitted the case to the jury upon the theory that Kenneth was required to use that degree of care which a 17-year-old minor would use in the same circumstances. […]

We are unable to find any authority holding that a minor should be held to an adult standard of care merely because he engages in a dangerous activity. There is always the parallel requirement that the activity be one that is normally engaged in only by adults. So formulated, the rule is logical and sound, for when a youth is old enough to engage in adult activity there are strong policy reasons for holding him to an adult standard of care. In that situation there should be no magic in the attainment of the twenty-first birthday.

We have no doubt that deer hunting is a dangerous sport. We cannot say, however, either on the basis of the record before us or on the basis of common knowledge, that deer hunting is an activity normally engaged in by adults only. To the contrary, all the indications are the other way. A child may lawfully hunt without a hunting license at any age under sixteen. We know, from common knowledge, that youngsters only six or eight years old frequently use .22 caliber rifles and other lethal firearms to hunt rabbits, birds, and other small game. We cannot conscientiously declare, without proof and on the basis of mere judicial notice, that only adults normally go deer hunting.

In refusing to apply an adult standard of care to a minor engaged in hunting deer, we do not imply that a statute to that effect would be unwise. Indeed, we express no opinion upon that question. As judges, we cannot lay down a rule with the precision and inflexibility of a statute drafted by the legislature. If we should declare that a minor hunting deer with a high-powered rifle must in all instances be held to an adult standard of care, we must be prepared to explain why the same rule should not apply to a minor hunting deer with a shotgun, to a minor hunting rabbits with a high-powered rifle, to a twelve-year-old shooting crows with a .22, and so on down to the six-year-old shooting at tin cans with an air rifle. Not to mention other dangerous activities, such as the swinging of a baseball bat, the explosion of firecrackers, or the operation of an electric train. All we mean to say in this case is that we are unwilling to lay down a brand-new rule of law, without precedent and without any logical or practical means of even surmising where the stopping point of the new rule might ultimately be reached. […]

Affirmed.[…]

BYRD, Justice (dissenting).

"Because a bullet fired from the gun by a minor is just as deadly as a bullet fired by an adult, I'm at a loss to understand why one with 'buck fever' because of his minority is entitled to exercise any less care than any one else deer hunting. One killed by a bullet so fired would be just as dead in one instance as the other and without any more warning.

For the reasons stated, I respectfully dissent".

Civil Law: Francia y Alemania

a) Francia : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Article 3

"Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi".

b) Código Civil alemán *(Bürgerliches Gesetzbusch (BGB))*

§ 828 Minderjährige

"(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat.

(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern Seine Verantwortlichkeit nicht nach Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat".

3. Riqueza del demandado

¿Deben de tenerse en cuenta los medios de que dispone el demandado, su riqueza en términos económicos, culturales, biológicos? La respuesta es negativa en el caso de la riqueza económica, pero como veremos en seguida, hay muchas formas de riqueza que no son estricta y directamente mente económicos, aunque admitan valoración, al menos parcial, en tales términos:

— *Denver & Rio Grande R.R. v. Peterson* (69 P. 578 (Colo. 1902))

"CAMPBELL, C.J. The care required of a warehouseman is the same, whether he is rich or poor. For, if the fact that he is rich requires of him greater care than if he possessed only moderate means or is poor, then, if he were extremely poor, the care required might be such as practically to amount to nothing; and no one would claim that such an uncertain and sliding rule should be the measure of his liability…"

4. Conocimientos especiales y habilidades particulares del demandado

El punto de partida en la responsabilidad profesional es que el demandado responde por el incumplimiento del cuerpo de reglas propias de su profesión, arte u oficio: la *lex artis*. ¿Pero responden más intensamente los mejores, en cada profesión, oficio o práctica o lo hacen de acuerdo con las reglas generales del arte, con la media de su profesión? ¿Está penalizado ser de los mejores? La respuesta suele ser que quien dispone de conocimientos especiales ha de actuar desde luego de acuerdo con las reglas propias del cuerpo de conocimientos correspondientes, es decir, más prudentemente que el lego. En cambio, dentro de la profesión u oficio, la respuesta es que la pericia extraordinaria del demandado es una de las circunstancias de que delimitan sus deberes de cuidado, pero no la única de ellas. En todo caso, quien carece de las habilidades propias de un especialista, no ya porque sea lego, sino porque, siendo profesional, dispone solo de los conocimientos generales de su oficio, ha de abstenerse de ejercer una especialidad para cuyo ejercicio no está preparado suficientemente.

§ 12 ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010):

"If an actor has skills or knowledge that exceed those possessed by most others, these skills or knowledge are circumstances to be taken into account in determining whether the actor has behaved as a reasonably careful person."

- When the actor is one of a limited number of parties that engage in an activity that poses distinctive and significant dangers [electric-power company].

- When the actor that possesses an above-average knowledge has a pre-existing relationship with the other party. [STS, 1ª, 836/2004, de 22 de julio]

- Substandard judgment is usually ignored. Learners and beginners.

- Intoxication. The foreseeability test: voluntary intoxication is ignored. Iced tea spiked with liquour.

En tal sentido, puede verse la **STS, 1ª, 679/2010, de 10 de diciembre**, ya tratada *supra* (véase epígrafe 3.1): "Faltaron en el caso los conocimientos médicos necesarios para hacer posible el diagnóstico que hubiera prevenido o evitado la obstrucción completa de la arteria carótida a partir de una previa sintomatología neurológica que no fue detectada por el médico de guardia, como "sin duda" lo habría hecho el perito, lo que a la postre no viene sino a indicar que cualquier otro médico con una base mínima de conocimientos para estos supuestos o supliendo sus carencias mediante un consejo médico complementario, habría detectado de inmediato la razón de su ingreso y le hubiera proporcionado con la urgencia y diligencia necesaria todos los medios curativos de que disponía" (FD. 2º).

STS, 1ª, 798/2009, de 9 de octubre (en el mismo sentido, STS, 1ª, 815/2010, de 15 de diciembre). Comentada por Marian GILI SALDAÑA e Ignacio MARÍN GARCÍA (2009), "Sentencia de 9 de octubre de 2008 (RJ 2008, 6042)", *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil,* núm. 80, pp. 751-778. Fin de protección de la norma y ausencia de responsabilidad de auditores.

Desde 1993, "XM Patrimonios Agencia de Valores, S.A." creó la apariencia de que compraba valores por cuenta de clientes cuando, en realidad, desviaba los fondos que recibía a otras sociedades. "Price Waterhouse Auditores, S.A." auditó las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios de 1993 y 1994. Las auditorías, que fueron realizadas efectivamente por Iván, no contenían salvedad alguna y expresaban la opinión de que las cuentas de la sociedad auditada reflejaban la imagen fiel de su patrimonio.

"Lepanto Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", Luis Enrique, "Penedés, S.A." y "Alto Penedés, S.A." demandan a "Price Waterhouse Auditores, S.A." e Iván, y solicitan una indemnización de 8.961.322,55 € para "Lepanto"; 1.526.244,80 € para Luís Enrique; 846.379,26 € para "Penedés, S.A.", y 65.599,71 € para "Alto Penedés, S.A.".

El JPI nº 24 de Barcelona (21.10.1998) desestimó la demanda. La AP de Barcelona (Sección 16ª, 31.7.2000) estimó íntegramente el recurso de apelación y condenó a los demandados a pagar 8.961.322,55 € a "Lepanto", 1.526.244,80 € a Luís Enrique, 846.379,26 € a "Penedés, S.A." y 65.599,71 € a "Alto Penedés, S.A.".

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por "Price Waterhouse Auditores, S.A." e Iván y revoca la SAP y dictó una nueva sentencia. El hecho de que la CNMV no hubiera actuado a tiempo para impedir las inversiones efectuadas por los demandantes es una causa extraña al ámbito de protección de la norma a cuya infracción se vincula la responsabilidad del auditor (art. 11 Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas – ahora art. 22 RDL 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas), pues la finalidad de esta norma es permitir que tanto la sociedad auditada como los terceros pudieran conocer la calidad de la información económico contable sobre la cual versaba la opinión emitida por el auditor de cuentas.

5. Circunstancias personales de la víctima

¿Debe el demandado atender a las circunstancias personales de la víctima que la sitúan en una posición de extrema vulnerabilidad y que, a menudo, no son aparentes? La respuesta es afirmativa en todos aquellos casos o circunstancias en los cuales el demandado había de contar con la posible presencia de víctimas potenciales especialmente frágiles, por ejemplo, en las calles y plazas de la ciudad, en general, en los escenarios habituales de la vida cotidiana. La razón es sencilla de entender: si para medir la intensidad del deber de precaución no se tuviera en cuenta al 5% o al 10% o al 15% de población más frágil, los incentivos para comportarse adecuadamente serían subóptimos.

En cambio, en espacios o, en general, en ocasiones en las cuales el demandado puede contar con que aquellas personas con las cuales va a interactuar son homogéneamente sanas y fuertes, sus deberes de precaución no incluirán la consideración hacia aquellas que precisen de una protección especial salvo que su indefensión resulte aparente a ojos de un observador razonable. El ejemplo clásico es la práctica de un deporte de equipo y de contacto en un espacio cerrado, un estadio o un campo de deporte.

Los casos de la ley suelen seguir esta línea de razonamientos:

"One rule of the tort law … is that the defendant takes his victim as he finds him. In Smith v. Brain Leech & Co. Ltd (1962) 2 Q.B. 405, plaintiff's deceased was burned on his lip by splashing molten metal because defendant negligently failed to provide an adequate guard. Because of prior exposures of another kind in the past, deceased had (according to the court) developed a tendency toward cancer. In any event, the burned lip did develop a cancer from which he died. The court acknowledged that death by cancer was unforeseeable…" (EPSTEIN, Cases and Materials on Torts, 9th ed., p. 542).

6. Situaciones de peligro que requieren acción inmediata: *Sudden emergency doctrine*

Una emergencia es, dice el DRAE, una "situación de peligro que requiere una acción inmediata" (3ª acepción) y la pregunta es si, ante una emergencia, los deberes de precaución son menos intensos que ante una situación de riesgo normalmente esperable. La respuesta es que la emergencia se tiene en cuenta como una de las circunstancias que modulan los deberes de cuidado, pero que, probablemente, no hay necesidad de construir una doctrina específica en la cual quepa encasillar multitud de acontecimientos inesperados, pero muy heterogéneos entre sí.

***Lyons v. Midnight Sun Transportation Services, Inc.* (928 P.2d 1202 (Alaska 1996))** (http://www.onlinelawtutoring.com/Case_Reference/Lyons_v_Midnight_Sun_Transportation_Services_Inc_928_P2d_1202_1996.htm)

PER CURIAM.

I. FACTS AND PROCEEDINGS

Esther Hunter-Lyons was killed when her Volkswagen van was struck broadside by a truck driven by David Jette and owned by Midnight Sun Transportation Services, Inc. When the accident occurred, Jette was driving south in the right-hand lane of Arctic Boulevard in Anchorage. Hunter-Lyons pulled out of a parking lot in front of him. Jette braked and steered to the left, but Hunter-Lyons continued to pull out further into the traffic lane. Jette's truck collided with Hunter-Lyons's vehicle. David Lyons, the deceased's husband, filed suit, asserting that Jette had been speeding and driving negligently.

At trial, conflicting testimony was introduced regarding Jette's speed before the collision. Lyons's expert witness testified that Jette may have been driving as fast as 53 miles per hour. Midnight Sun's expert testified that Jette probably had been driving significantly slower and that the collision could have occurred even if Jette had been driving at the speed limit, 35 miles per hour. Lyons's expert later testified that if Jette had stayed in his own lane, and had not steered to the left, there would have been no collision. Midnight Sun's expert contended that steering to the left when a vehicle pulls out onto the roadway from the right is a normal response and is generally the safest course of action to follow.

Over Lyons's objection, the jury was given an instruction on the sudden emergency doctrine. The jury found that Jette, in fact, had been negligent, but his negligence was not a legal cause of the accident. Lyons appeals, arguing that the court should not have given the jury the sudden emergency instruction.

II. ANALYSIS AND DISCUSSION

The sudden emergency doctrine is a rule of law which states that a person confronted with a sudden and unexpected peril, not resulting from that person's own negligence is not expected to exercise the same 1204 judgment and prudence the law requires of a person in calmer and more deliberate moments. The person confronted with the imminent peril must, however, act as a reasonable person would under the same conditions.

[The Court first held that the use of the sudden emergency instruction count was harmless error since the jury decided in favour of defendant on the ground that his conduct was not the legal cause of plaintiff's injury.]

B. Sudden Emergency Instruction Disapproved

[W]e take this opportunity to disapprove of the instruction's further use. It adds nothing to the established law that the duty of care, which all must exercise, is to act reasonably under the circumstances. The instruction is potentially confusing. Although we cannot say that the instruction is never appropriate, we discourage its employment. In support of this admonition, we offer the following background.

The sudden emergency doctrine arose as a method of ameliorating the, sometimes harsh, "all or nothing" rule in contributory negligence systems. […]

Although the doctrine came out of the contributory negligence regime, there is nothing about it which is inherently incompatible with a comparative fault system. Comparative negligence is a method of apportioning liability for a particular accident among the various parties who have been deemed negligent. The sudden emergency doctrine, in turn, is an expression of the applicable standard of care against which particular actions are judged in order to determine whether they were negligent in character. The fault of one person, determined in the light of a sudden emergency instruction, can be compared to the fault of another person, whose negligence may have created the emergency, with no logical inconsistency. […]

We believe that the sudden emergency instruction is a generally useless appendage to the law of negligence. With or without an emergency, the standard of care a person must exercise is still that of a reasonable person under the circumstances. With or without the instruction, parties are still entitled to present evidence at trial which will establish what the circumstances were, and are also entitled to argue to the jury that they acted as a reasonable person would have in light of those circumstances. Thus, barring circumstances that we cannot at the moment hypothesize, a sudden emergency instruction serves no positive function. Further, the instruction may cause confusion by appearing to imply that one party is less blameworthy than the other. Therefore, we hold that it should not be used unless a court finds that the particular and peculiar facts of a case warrant more explanation of the standard of care than is generally required […].

AFFIRMED.

§ 9 *Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm* (2010):

"If an actor is confronted with an unexpected emergency requiring rapid response, this is a circumstance to be taken into account in determining whether the actor's resulting conduct is that of the reasonable careful person".

- This section addresses the situation in which an actor faces two or more choices of conduct, each of which entails its own combination of advantages and disadvantages. In an emergency, the fact of the emergency itself may mean that the response is instinctive rather than deliberative; at the least, it indicates that the opportunities for deliberation have been limited by severe time pressures.

- The emergency can be created by the conduct of another person, or without human action (failure of the brakes).

- Emergency. The kind of event that prevents reasonable people from exercising the kind of good judgment that such people ordinarily exercise.

- Prior negligence of the defendant. A number of courts adopt the rule that the emergency doctrine does not apply when the emergency is due to the defendant's prior negligence, but not all.

Capítulo 4º
Negligencia (II): Estimación del riesgo

1. Cálculo del riesgo. Concepto económico de culpa / *Calculus of risk. The Economic Concept of Negligence* 55
1.1. *Eckert v. Long Island R.R.* (43 N.Y. 502 (1871)) 55
1.2. STS, 1ª, 1186/2004, de 10 de diciembre 57
1.3. *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F.2d 169 (2d Cir. 1947)) 57
2. Negligencia como incremento irrazonable de riesgo / *Negligence as non-reasonable increase of risk* 60
2.1. *Helling v. Carey* (83 Wash. 2d 514, 519 P.2d 981 (1974)) 60
2.2. STS, 3ª, de 26 de junio de 2008 62
2.3. STS, 1ª, 64/2011, de 9 de febrero 62
2.4. STS, 1ª, 149/2010, de 25 de marzo 63
3. Costumbre / *Custom* 63
3.1. *The T.J. Hooper* (60 F.2d 737 (2d Cir.), cert. denied, 287 U.S. 662 (1932)) 64
3.2. Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Instrumentos de control social y derecho de daños", *InDret* 4/2004 (www.indret.com), pp. 10-12 66

1. Cálculo del riesgo. Concepto económico de culpa / *Calculus of risk. The Economic Concept of Negligence*

La idea de que, en un mundo finito, con recursos limitados, la precaución que hay que aplicar a la realización de una actividad lícita, pero peligrosa, no es infinita es muy antigua:

1.1. *Eckert v. Long Island R.R.* (43 N.Y. 502 (1871))

"[…] The case, as made by the plaintiff, was that the deceased received an injury from a locomotive engine of the defendant, which resulted in his death, on the 26th day of November, 1867, under the following circumstances:

He was standing in the afternoon of the day named, in conversation with another person about fifty feet from the defendant's track in East New York, as a train of cars was coming in from Jamaica at a rate of speed estimated by the plaintiff's witnesses of from twelve to twenty miles an hour. The plaintiff's witnesses heard no signal either, from the whistle or the bell upon the engine. The engine was constructed to run either way without turning and it was then running backward with the cowcatcher next the train it was drawing, and nothing in front to remove obstacles from the track. The claim of the plaintiff was that the evidence authorized the jury to find that the speed of the train was improper and negligent in that particular place, it being a thickly populated neighborhood and one of the stations of the road.

The evidence on the part of the plaintiff also showed that a child three or four years old was sitting or standing upon the track of the defendant's road as the train of cars approached and was liable to be run over, if not removed; and the deceased, seeing the danger of the child, ran to it, and, seizing it, threw it clear of the track on the side opposite to that from which he came, but, continuing across the track himself, was struck by the step or some part of the locomotive or tender, thrown down, and received injuries from which he died the same night.

The evidence on the part of the defendant tended to prove that the cars were being run at a very moderate speed, not over seven or eight miles an hour, that the signals required by law were given, and that the child was not on the track over which the cars were passing, but on a side track near the main track.

So far as there was any conflict of evidence or question of fact, the questions were submitted to the jury. At the close of the plaintiff's case, the counsel for the defendant moved for a nonsuit upon the ground that it appeared that the deceased's negligence contributed to the injury and the motion was denied and an exception taken. After the evidence was all in, the judge was requested by the counsel for the defendant to charge the jury, in different forms, that if the deceased voluntarily placed himself in peril from which he received the injury, to save the child, whether the child was or was not in danger, the plaintiff could not recover and all the requests were refused and exceptions taken, and the question whether the negligence of the intestate contributed to the accident was submitted to the jury. The jury found a verdict for the plaintiff and the judgment entered thereon was affirmed, on appeal, by the Supreme Court and from the latter judgment the defendant has appealed to this court.

GROVER, J. The important question in this case arises upon the exception taken by the defendant's counsel to the denial of his motion for a nonsuit, made upon the ground that the negligence of the plaintiff's intestate contributed to the injury that caused his death. The evidence showed that the train was approaching in plain view of the deceased, and had he for his own purposes attempted to cross the track, or with a view to save property placed himself voluntarily in a position where he might have received an injury from a collision with the train, his conduct would have been grossly negligent, and no recovery could have been had for such injury. But the evidence further showed that there was a small child upon the track, who, if not rescued, must have been inevitably crushed by the rapidly approaching train. This the deceased saw, and he owed a duty of important obligation to this child to rescue it from its extreme peril, if he could do so without incurring great danger to himself. Negligence implies some act of commission or omission wrongful in itself. Under the circumstances in which the deceased was placed, it was not wrongful in him to make every effort in his power to rescue the child, compatible with a reasonable regard for his own safety. It was his duty to exercise his judgment as to whether he could probably save the child without serious injury to himself. If, from the appearances, he believed that he could, it was not negligence to make an attempt so to do, although believing that possibly he might fail and receive an injury himself. He had no time for deliberation. He must act instantly, if at all, as a moment's delay would have been fatal to the child. The law has so high a regard for human life that it will not impute negligence to an effort to preserve it, unless made under such circumstances as to constitute rashness in the judgment of prudent persons. For a person engaged in his ordinary affairs, or in the mere protection of property, knowingly and voluntarily to place himself in a position where he is liable to receive a serious injury, is negligence which will preclude a recovery for an injury so received; but when the exposure is for the purpose of saving life it is not wrongful, and therefore not negligent, unless such as to be regarded either rash or reckless. The jury was warranted in finding the deceased free from negligence under the micas above stated. The motion for a nonsuit was therefore properly denied. That the jury was warranted in finding the defendant guilty of negligence in running the train in the manner it was running requires no discussion. None of the exceptions taken to the charge as given, or to the refusals to charge as requested, affect the right of recovery. Upon the principle above stated, the judgment appealed from must be affirmed, with costs.

CHURCH, C. J., and PECKHAM and RAPALLO, JJ., concur.

ALLEN, J., wrote a dissenting opinion, in which FOLGER, J., concurred.

Judgment affirmed".

En la jurisprudencia española, la idea de que la precaución exigible ha de ser conmensurable con el riesgo aparece en muchas sentencias, pero casi nunca de forma central:

1.2. STS, 1ª, 1186/2004, de 10 de diciembre

El 18.8.1990, José Manuel intentó socorrer a otra persona que se estaba ahogando en la playa de Cullera (Valencia) en una zona alejada de la de uso habitual de los bañistas, sin que existiera en las cercanías miembros del servicio de socorristas municipales y cuando el mar estaba picado. A pesar de que una zódiac de socorristas acudió a rescatarles, ambos fallecieron.

La viuda de José Manuel, en nombre propio y en el de su hijo, demandó al Ayuntamiento de Cullera y solicitó una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 1 de Sueca estimó la demanda (2.7.1996) y condenó al Ayuntamiento al pago de 102.172 €, de los cuales 72.121,45 € para la actora y 30.050,60 € para su hijo. La AP de Valencia (Secc. 8ª, 4.5.1998) estimó el recurso de apelación, revocó la SJPI y absolvió al Ayuntamiento.

El TS desestimó el recurso de casación al considerar que la actuación de la víctima fue negligente, pues no tuvo en consideración el mal estado del mar, y que la del equipo de salvamento fue adecuada: "el hecho en cuestión no puede ser reprochado culpabilísticamente al eventual responsable –el Ayuntamiento de Cullera- ya que aparte de la actuación personal del fallecido creadora del riesgo por su comportamiento, que aunque impregnado de un sentimiento solidario de amistad y altruismo, no tuvo en cuenta el mal cariz que presentaba el mar, que en ese momento suponía un peligro serio"(FD 1º).

En el caso debe tenerse en cuenta el criterio de la provocación, según el cual debe afirmarse la imputación objetiva del daño cuando el dañado asume el riesgo del que finalmente resulta víctima en su intento de salvar la vida, integridad física o bienes de un tercero en situación de peligro creada negligentemente por la víctima misma.

Obviando la posible responsabilidad de la persona a quien se intentó salvar–que la actora parece olvidar aferrándose a una entidad más solvente, el Ayuntamiento- , la cuestión radica en determinar si el Ayuntamiento, en concreto, los servicios de salvamento, incumplieron, por omisión, el deber de interrumpir el curso causal anteriormente mencionado.

Puede pensarse que, dada la autopuesta en peligro –o, dicho de otro modo, la asunción del riesgo- por parte de los bañistas, la Administración no incumplió su deber de protección y salvamento, pues no tiene la obligación de prever todo tipo de accidentes ni de proveer servicios de salvamento de forma que se reduzca el número de accidentes hasta cero, incluyendo los gravemente negligentes.

En este sentido, según el TS, la actuación de los servicios de salvamento fue "lógica y correcta", pues "no se puede exigir que haya una abundancia tal de socorristas que puedan actuar de inmediato"(FD 1º).

U.S. v. Carroll, resuelto en 1947, es el caso de derecho de daños más famoso del siglo XX quizás porque acuñó el concepto económico de negligencia en el cénit cultural de un sistema económico. Todavía hoy, es inconcebible un curso de responsabilidad civil impartido en cualquiera de las cincuenta facultades de derecho más prestigiosas según los rankings al uso que no mencione *U.S. v. Carroll*, aunque solo sea para tratar de superarlo. Como ha de ser:

1.3. *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F.2d 169 (2d Cir. 1947))

[The incident out of which this admiralty case arose was the sinking of a barge, along with its cargo, allegedly because of the defendant's negligence. A crucial issue in the case involved whether the person in charge of the barge, the bargee, was negligent in being ashore, away from the barge, during the period when it got into difficulties and sank. If the bargee's absence was negligence, and if it contributed substantially to the loss of the barge, then the bargee's employer, the owner of the barge, would not receive full recovery from the other parties whose negligence put the barge into difficulties in the first place].

L. HAND, J.
It appears … that there is no general rule to determine when the absence of a bargee or other attendant will make the owner of the barge liable for injuries to other vessels if she breaks away from her moorings. However, in any cases where he would be so liable for injuries to others obviously he must reduce his damages proportionately, if the injury is to his own barge. It becomes apparent why there can be no such general rule, when we consider the grounds for such a liability. Since there are occasions when every vessel will break from her moorings, and since, if she does, she becomes a menace to those about her; the owner's duty, as in other similar situations, to provide against resulting injuries is a function of three variables:

(1) the probability that she will break away;
(2) the gravity of the resulting injury, if she does;
(3) the burden of adequate precautions.

Possibly it serves to bring this notion into relief to state it in algebraic terms: if the probability be called P; the injury, L; and the burden, B; liability depends upon whether B is less than L multiplied by P: i.e., whether B less than PL. Applied to the situation at bar, the likelihood that a barge will break from its fasts and the damage it will do, vary with the place and time; for example, if a storm threatens, the danger is greater; so it is, if it is in a crowded harbor where moored barges are constantly being shifted about. On the other hand, the barge must not be the bargee's prison, even though he lives aboard; he must go ashore at times. We need not say whether, even in such crowded waters as New York Harbor a bargee must be aboard at night at all; it may be that the custom is otherwise… and that, if so, the situation is one where custom should control. We leave that question open; but we hold that it is not in all cases a sufficient answer to a bargee's absence without excuse, during working hours, that he has properly made fast his barge to a pier, when he leaves it. In the case at bar the bargee left at five o'clock in the afternoon of January 3rd, and the flotilla broke away at about two o'clock in the afternoon of the following day, twenty-one hours afterwards. The bargee had been away all the time, and we hold that his fabricated story was affirmative evidence that he had no excuse for his absence. At the locus in quo -especially during the short January days and in the full tide of war activity- barges were being constantly 'drilled' in and out. Certainly it was not beyond reasonable expectation that, with the inevitable haste and bustle, the work might not be done with adequate care. In such circumstances we hold -and it is all that we do hold- that it was a fair requirement that the Conners Company should have a bargee aboard (unless he had some excuse for his absence), during the working hours of daylight.

El remolcador de la compañía demandada remolcaba una línea de barcazas o gabarras, aguas arriba y aguas abajo, en el río Hudson. La línea incluía la Anna C., propiedad de la Connors Company. La Anna C. rompió sus amarras y, llevada por el viento y la marea, abordó un petrolero cuya hélice rasgó el casco de la barcaza que, a continuación, se hundió.

Una cuestión ante el tribunal era si el armador o dueño de la barraca había incurrido en negligencia, había sido contributivamente negligente, pues podría –se alegaba– haber destacado a un bargee –gabarrero, marinero– en la barcaza.

Juez Hand: No hay regla general, ni legal ni consuetudinaria que establezca cuándo la ausencia de un gabarrero, barquero hará al armador responsable por los daños derivados de la rotura de las amarras de la barcaza. Está claro por qué no puede haber una regla general semejante, pues hay ocasiones en las que cualquier barco se soltaría de sus amarras… El deber de cuidado del dueño es una función de tres variables: B = PxL.

Puede ser que la costumbre sea distinta, en cuyo supuesto, gobernará el caso.

En la literatura: Richard POSNER, *A Theory of Negligence* 1 J. Legal Stud. 29 (1972).

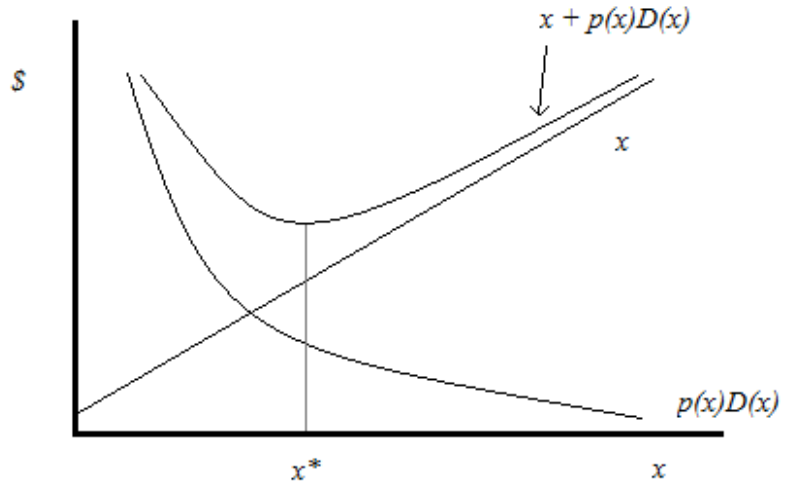


Gráfico de John PRATER BROWN (1983)/Steven SHAVELL (1987).

§ 3 *Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm* (2010): **Negligence**

"A person acts negligently if the person does not exercise reasonable care under all the circumstances."

Primary factors to consider in ascertaining whether the person's conduct lacks reasonable care are:

1) The foreseeable likelihood that the person's conduct will result in harm.
2) The foreseeable severity of any harm that may ensue.
3) And the burden of precautions to eliminate or reduce the risk of harm.

Análisis crítico:

1) Una simple plantilla: *Judex non calculat*, es decir, los tribunales no son consultorías, sino que aplican el derecho a los hechos del caso, tal y como resultan probados en el proceso.
2) La objeción filosófica de la inconmensurabilidad y los problemas empíricos de medición: *Helling v. Carey* (519 P. 22d 981 (Wash. 1974)). Entre los años 1959 y 1968, el demandante acudía a la consulta del oftalmólogo demandado para visitarse y tratarse de una irritación en los ojos causada por lentes de contacto. A finales de 1968, cuando el demandante tenía 32 años de edad, el demandado sospechó que aquel podría sufrir de glaucoma –una enfermedad de los ojos causada por un exceso de presión sobre el nervio óptico- cuando el paciente le dijo que había perdido visión periférica. El oftalmólogo le aplicó entonces un test de presión que confirmó el diagnóstico. El paciente acabó por perder la vista, pero un tratamiento temprano habría evitado el daño. En el pleito que siguió por mala praxis médica, el demandado alegó que el estándar profesional no exigía practicar pruebas de presión a pacientes menores de cuarenta años de edad, pues se trataba de una enfermedad muy poco común que sólo se presentaba en 1/25.000 casos. Suponiendo que el coste de

cada test aplicado a cada niño o persona joven que se visite es de 5 USD, ¿había que haber practicado el test o no? Fíjense que tenemos B = 5, P= 1/25.000, pero que nos falta L, la evaluación de la pérdida de la visión. Si B = PxL, entonces 5 = 125.000/25.000. Mas ¿cuánto vale un ojo de la cara?

3) Un caso similar, apropiado para ser discutido en un seminario, es la STS, 3ª, de 26 de junio de 2008: neuritis óptica de origen tóxico por tratamiento con medicación antituberculosa, Rifinah 300 (principio activo: isoniazida), reacción adversa, muy rara (que se produce en uno de cada diez mil tratamientos) y en caso en el que no existe indicación previa de propensión del paciente a neuritis.
4) Otra cuestión derivada de la presencia masiva de falsos positivos, que encarece mucho la práctica del test: si el test de presión sale positivo en muchos casos, de forma tal que sólo el 4% de los positivos es auténtico, es decir, desarrollarán glaucoma, la cosa se complica. Volveremos sobre la conveniencia o inconveniencia de estar a los estándares profesionales, a la costumbre.
5) Precaución absoluta o precauciones marginales: los primeros 60 euros o dólares USA evitan daños por una evaluación de 120, pero los segundos 40 sólo 30. Entonces, aunque (60 + 40 =) 100 < (120 + 30)= 150, es mejor, menos malo quedarse en 60 de gasto en precauciones, pues los segundos 40 superan en 10 a los 30 que se ahorran con ellos. Si no aprecian contar en unidades económicas, en dinero, pueden hacerlo en cualquier otra unidad que no les repela, por ejemplo, en *quality adjusted years of life, QUALY's.*
6) La fórmula no captura el autorriesgo (PORAT-COOTER, 29 J. Legal, Stud 19 (2000)), la autopuesta en riesgo, es decir, que no tiene en cuenta los daños probables causados por el comportamiento del demandado a sus propios bienes y, que en tal sentido, no incentiva la adopción óptima de precauciones.
7) La neutralidad al riesgo es poco plausible como supuesto general: muchas personas prefieren un 10% de probabilidad de perder 100 al 100% de perder 10. La función de utilidad crece menos proporcionalmente que la renta.
8) ¿Por qué es negligente la gente? Si es racional, no debería serlo.
9) Discontinuidades: pequeños errores en la apreciación del estándar llevan a discontinuidades en la función de responsabilidad: el médico cirujano pasa de ser un prudente profesional a un homicida negligente. Por un pequeño error. Y
10) ¿Sabemos realmente calcular las consecuencias de todas y de cada una de nuestras decisiones arriesgadas para nosotros mismos y para los demás? ¿Lo hacemos así?

2. Negligencia como incremento irrazonable de riesgo / *Negligence as non-reasonable increase of risk*

Tal y como se ha venido señalando en estas Sesiones, la otra cara de la definición de la negligencia concebida como infracción de deberes de cuidado es su concepción como incremento irrazonable de un riesgo. En el contexto del análisis de la regla de Hand, *Helling v. Carey* ilustra muy claramente este enfoque:

2.1. *Helling v. Carey* (83 Wash. 2d 514, 519 P.2d 981 (1974))

HUNTER, ASSOCIATE JUSTICE. This case arises from a malpractice action instituted by the plaintiff (petitioner), Barbara Helling.

The plaintiff suffers from primary open angle glaucoma. Primary open angle glaucoma is essentially a condition of the eye in which there is an interference in the ease with which the nourishing fluids can flow out of the eye. Such a condition results in pressure gradually rising above the normal level to such an extent that damage is produced to the optic nerve and its fibers with resultant loss in vision.... The disease usually has few symptoms and, in the absence of a pressure test, is often undetected until the damage has become extensive and irreversible.

The defendants (respondents), Dr. Thomas F. Carey and Dr. Robert C. Laughlin, are partners who practice the medical specialty of ophthalmology. Ophthalmology involves the diagnosis and treatment of defects and diseases of the eye.

The plaintiff first consulted the defendants for myopia, nearsightedness, in 1959. At that time she was fitted with contact lenses. [She consulted the defendants several times over the next nine years.] Until the October 1968 consultation, the defendants considered the plaintiff's visual problems to be related solely to complications associated with contact lenses. On that occasion, the defendant, Dr. Carey, tested the plaintiff's eye pressure and field of vision for the first time. This test indicated that the plaintiff had glaucoma. The plaintiff ... was then 32 years of age.

Thereafter, in August of 1969, after consulting other physicians, the plaintiff filed a complaint against the defendants alleging, among other things, that she sustained severe and permanent damage to her eyes as a proximate result of the defendants' negligence. During trial, the testimony of the medical experts for both the plaintiff and the defendants established that the standards of the profession for that specialty in the same or similar circumstances do not require routine pressure tests for glaucoma upon patients under 40 years of age. The reason the pressure test for glaucoma is not given as a regular practice to patients under the age of 40 is that the disease rarely occurs in this age group. Testimony indicated, however, that the standards of the profession do require pressure tests if the patient's complaints and symptoms reveal to the physician that glaucoma should be suspected.

The trial court entered judgment for the defendants following a defense verdict. The plaintiff thereupon appealed to the Court of Appeals, which affirmed the judgment of the trial court (...).

We find this to be a unique case. (…) The issue is whether the defendants' compliance with the standard of the profession of ophthalmology, which does not require the giving of a routine pressure test to persons under 40 years of age, should insulate them from liability under the facts in this case where the plaintiff has lost a substantial amount of her vision due to the failure of the defendants to timely give the pressure test to the plaintiff.

The incidence of glaucoma in one out of 25,000 persons under the age of 40 may appear quite minimal. However, that one person, the plaintiff in this instance, is entitled to the same protection as afforded persons over 40, essential for timely detection of the evidence of glaucoma where it can be arrested to avoid the grave and devastating result of this disease. The test is a simple pressure test, relatively inexpensive. There is no judgment factor involved, and there is no doubt that by giving the test the evidence of glaucoma can be detected. The giving of the test is harmless if the physical condition of the eye permits. The testimony indicates that although the condition of the plaintiff's eyes might have at times prevented the defendants from administering the pressure test, there is an absence of evidence in the record that the test could not have been timely given (...).

Under the facts of this case reasonable prudence required the timely giving of the pressure test to this plaintiff. The precaution of giving this test to detect the incidence of glaucoma to patients under 40 years of age is so imperative that irrespective of its disregard by the standards of the ophthalmology profession, it is the duty of the courts to say what is required to protect patients under 40 from the damaging results of glaucoma.

We therefore hold, as a matter of law, that the reasonable standard that should have been followed under the undisputed facts of this case was the timely giving of this simple, harmless pressure test to this plaintiff and that, in failing to do so, the defendants were negligent, which

proximately resulted in the blindness sustained by the plaintiff for which the defendants are liable (...).

The judgment of the trial court and the decision of the Court of Appeals is reversed, and the case is remanded for a new trial on the issue of damages only.

En la jurisprudencia española, la problemática abordada por Helling aparece en numerosas sentencias. Destacamos algunas:

2.2. STS, 3ª, de 26 de junio de 2008

En abril de 1999, el Sr. Octavio acudió a un Centro de Atención Primaria de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) donde el Dr. Millán, médico de cabecera del actor, le diagnosticó tuberculosis, que no fue confirmada por médico especialista, e inició tratamiento farmacológico con Rifinah (F: Sanofi Aventis, S.A.; PA: Isoniazida, Rifampicina; AT: tratamiento de la tuberculosis). En agosto de 1999, se retiró la medicación al Sr. Octavio porque su consumo le había causado una neuritis óptica bilateral, lo que devino en una incapacidad permanente absoluta. Consta acreditado que la neuritis óptica es una reacción poco frecuente (1/10.000 tratamientos) de la isoniazida y que puede paliarse con vitamina B 6, que no se le administró al paciente.

El Sr. Octavio interpuso, primero, reclamación administrativa contra la Administración General del Estado, el Instituto Nacional de la Salud y Mapfre Industrial, S.A. en la que solicitaba 26 millones de ptas. (156.263 euros), que fue desestimada por silencio administrativo y, después, recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que también fue desestimado (3.3.2004). El actor interpuso finalmente recurso de casación.

El TS estimó dicho recurso de casación, en el que se alegaba infracción del art. 141.1 Ley 30/1992, y condenó a la Administración General del Estado al pago de 30.000 euros porque "debe entenderse que siendo médicamente conocidos los efectos secundarios de la administración de isoniacida y que estos hubieran podido, si no prevenirse, sí minimizarse con la administración conjunta de la vitamina B 6, la no pautación de dicha vitamina al recurrente, a quien como a cualquier paciente, según el informe pericial, se le podían producir dichos efectos secundarios, sin olvidar además que al mismo no se le había realizado prueba que hubiese permitido una mejor confirmación del diagnóstico de presunción, supone una infracción de la "lex artis" que le ha generado una pérdida de oportunidad, en cuanto los resultados hubieran podido ser otros, si se le hubiese administrado conjuntamente la vitamina B 6" (FD 5ª).

2.3. STS, 1ª, 64/2011, de 9 de febrero

El 3.3.2001, Isaac esquiaba en la estación de La Molina (propiedad de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), junto a su familia, cuando cayó y se deslizó hasta impactar contra un cañón de nieve artificial. A raíz del accidente, a Isaac se le rompieron las vértebras D7, D8, D11 y D12, pertenecientes a dos zonas diferentes de la columna, y sufre paraplejia L1, con afectación de esfínteres rectales y urinarios.

Isaac y su mujer África demandaron, en su nombre y en el de sus tres hijas menores de edad –Maite, Melisa y Noemí–, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y a su aseguradora Winterthur y solicitaron una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (no consta cuantía).

El JPI nº 7 de Barcelona (15.12.2004) estimó en parte la demanda y condenó a las demandadas (a Winterthur solamente hasta los 300.005,99€) al pago de 646.803,97€ a Isaac y de 90.000€ por el daño moral causado a la mujer y a las hijas del actor.

La AP de Barcelona (Sección 1ª, 20.9.2006) estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por los actores y aumentó la indemnización a pagar por las demandadas a 790.220,60€ y a 110.000 € respectivamente.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por los demandados:

"(…) debe juzgarse como razonable la decisión de calificar como no diligente la conducta de la empresa titular de la estación pues […] el dueño de una estación de esquí se encuentra obligado a poner los medios adecuados para evitar el daño teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que gestiona, y con mayor motivo, cuando contribuyó a incrementar el riesgo propio de la actividad deportiva colocando en un lugar próximo a la pista un elemento artificial, rígido y duro, como un cañón artificial, que generó un riesgo evidente de lesiones en caso de colisión, incluso si esta se producía por consecuencia de un deslizamiento subsiguiente a una caída. Y siendo todo ello previsible, las caídas, las colisiones y el daño, no podía limitarse a señalar el elemento sino que le incumbía adoptar medidas de seguridad encaminadas a evitar o a disminuir el riesgo de lesiones, lo que no hizo". (FD 4º)

Vídeo de un accidente similar en Vallter 2000 en el año 2008
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/11638/el-terrible-accidente-en-la-nieve-que-costo-la-vida-a-un-joven-colombiano-en-espana/

2.4. STS, 1ª, 149/2010, de 25 de marzo

Una mujer de 65 años de edad y con problemas óseos y articulares, que habían determinado en 1987 el reconocimiento de una situación de invalidez absoluta, no advirtió que, en la entrada de un restaurante había un escalón, por lo que tropezó y se cayó. Como resultado de la caída, sufrió facturas del subcapital de fémur derecho, de la vértebra C1 sin desplazamiento y de la vértebra C2, que agravaron su artrosis previa.

La víctima demandó a la sociedad limitada propietaria del restaurante y a su compañía de seguros. El JPI desestimó la demanda. La AP estimó en parte el recurso de apelación de la actora y condenó a los demandados al pago de 45.076 euros. El TS desestimó el recurso de casación de los demandados y confirmó la SAP:

"[E]l tribunal de apelación no infringió el art. 1902 CC (…) porque en definitiva esta Sala sí comparte el juicio esencial de dicho tribunal sobre la negligencia inherente a la disposición o configuración del acceso del hostal al restaurante, con un escalón intermedio a escasísima distancia del umbral y precisamente en la zona de claroscuro provocado, simultáneamente, por los diferentes colores del pavimento y la luz solar a la entrada y al fondo, quedando en penumbra precisamente el punto en que se encontraba el escalón (…) [L]a causa de la caída no fue sólo esa omisión negligente dado que también contribuyó de forma importante el estado físico de la demandante que afectaba a su capacidad de deambulación. En suma, el problema no es tanto de culpa de la víctima, pues ninguna culpa hay en padecer enfermedades o limitaciones ósea y articulares, cuanto de imputación al demandado de la causa de lo sucedido y de sus consecuencias (FD. 4º).

3. Costumbre / *Custom*

La costumbre, los usos de la profesión, arte u oficio, sus buenas prácticas, son índices de calidad, de conducta adecuada, por diligente, del demandado, pero son solo eso: indicios, pues ni siquiera constituyen una presunción en sentido estricto. Por cierto, ¿conoce el lector la distinción entre presunciones, indicios y sospechas?

En cualquier caso, para valorar el comportamiento del demandado, hay que tener en cuenta, en primerísimo lugar, las disposiciones de la ley o, más frecuentemente, de los reglamentos que la

desarrollan en tema de estándares de precaución. Aquí es importante destacar que, entre la ley (y el reglamento), por un lado, y la costumbre, hay muchas posibilidades alternativas. Véase si no, la lista siguiente:

[First of all, statutory standards of care have to be taken into account:

a. Specific Safety Regulations.
b. Best Available Technology (BAT)
c. As Low As Reasonably Achievable (ALARA)
d. Cost-benefit: Entergy Corp. v. Riverkeeper Inc. et al.
e. The utmost care standard…
f. …

And then, there is:]

g. Custom

The general principles of negligence ("The reasonable person standard"), writes Epstein (p. 221), leave judges a great deal of latitude in deciding cases. This generality introduces a large element of uncertainty even in ostensible routine cases. Using custom to set the standard of care is one way to reduce this uncertainty.

The question is then: Should custom be given the same deference in actions between strangers as in actions arising out of consensual relationships? Does "reasonable safe" mean "safe according to the usages, habits, and ordinary risks of the business"? See *Titus v. Bradford, B & K*. R. Co. 20 A. 517 (Pa. 1890).

El caso de referencia sobre usos, costumbre y tecnología es *The T.J. Hopper*. Resuelto hace ochenta años, su lectura es todavía un magnífico punto de partida para el análisis de la cuestión de si la costumbre induce diligencia:

3.1. *The T.J. Hooper* (60 F.2d 737 (2d Cir.), cert. denied, 287 U.S. 662 (1932))

Petition by the Eastern Transportation Company, as owner of the tugs Montrose and T. J. Hooper, for exoneration from, or limitation of, liability; separate libels by the New England Coal & Coke Company and by H. N. Hartwell & Son, Inc., against the Northern Barge Corporation, as owner of the barge Northern No. 30 and the barge Northern No. 17; and libel by the Northern Barge Corporation against the tugs Montrose and Hooper. The suits were joined and heard together. From the decree rendered [53 F.(2d) 107], the petitioner Eastern Transportation Company and the Northern Barge Corporation, appeal.

[The operator of a tugboat was sued for the value of two barges and their cargoes, which were lost at sea during a coastal storm in March 1928. The basis of the claim was that the tug was negligently unseaworthy in that it was not equipped with a radio receiver, and thus could not receive reports of an impending storm. There was evidence that the master, had he heard the weather reports, would have turned back]

L. HAND,

It is not fair to say that there was a general custom among coastwise carriers so to equip their tugs. One line alone did it; as for the rest, they relied upon their crews, so far as they can be said to have relied at all. An adequate receiving set suitable for a coastwise tug can now be got at small cost and is reasonably reliable if kept up; obviously it is a source of great protection to their tows. Twice every day they can receive these predictions, based upon the widest possible information, available to every vessel within two or three hundred miles and more. Such a set is the ears of the tug to catch the spoken word, just as the master's binoculars are her eyes to see a

storm signal ashore. Whatever may be said as to other vessels, tugs towing heavy coal laden barges, strung out for half a mile, have little power to manoeuvre, and do not, as this case proves, expose themselves to weather which would not turn back stauncher craft. They can have at hand protection against dangers of which they can learn in no other way.

Is it then a final answer that the business had not yet generally adopted receiving sets? There are, no doubt, cases where courts seem to make the general practice of the calling the standard of proper diligence; we have indeed given some currency to the notion ourselves. Indeed in most cases reasonable prudence is in fact common prudence; but strictly it is never its measure; a whole calling may have unduly lagged in the adoption of new and available devices. It never may set its own tests, however persuasive be its usages. Courts must in the end say what is required; there are precautions so imperative that even their universal disregard will not excuse their omission. But here there was no custom at all as to receiving sets; some had them, some did not; the most that can be urged is that they had not yet become general. Certainly in such a case we need not pause; when some have thought a device necessary, at least we may say that they were right, and the others too slack. The statute (section 484, title 46, U. S. Code [46 USCA § 484]) does not bear on this situation at all. It prescribes not a receiving, but a transmitting set, and for a very different purpose; to call for help, not to get news. We hold the tugs therefore because had they been properly equipped, they would have got the Arlington reports. The injury was a direct consequence of this unseaworthiness.

Decree affirmed.

The Restatement (Third) of Torts "downgrades the role of custom" (Epstein) holding that compliance with the custom of the community is evidence that the actor's conduct is not negligence, but does not preclude a finding of negligence".

§ 13 *Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm* (2010)**: Custom**

(a) An actor's compliance with the custom of the community, or of others in like circumstances is evidence that the actor's conduct is not negligent but does not preclude a finding of negligence.

(b) An actor's departure from the custom of the community, or of others in like circumstances, in a way that increases risk is evidence of the actor's negligence but does not require a finding of negligence.

Epstein's dissenting analysis from The T. J. Hooper:

Hand's view has received overwhelming acceptance. Epstein disagrees. First, in cases that arise out of a consensual arrangement, negligence is often the appropriate standard of liability, and where it is so, custom should be regarded as conclusive evidence of due care in absence of any contractual stipulation to the contrary. Second, in stranger cases, negligence should normally not be the appropriate standard of care, so that reliance on custom is as irrelevant as the negligence issue to which custom alone is properly directed (…) because it registers the preferences of the parties to the custom, not those who are victimized by it.

Compare: custom in international law –as a source of legal obligations-; custom in contract law.

Discuss:

- Compliance with the custom of the community. Widespread reliance on custom.
- Private standards ("codes") and public recommendations. Example: National Electric Safety Code, issued by the American National Standards Institute.
- Actor's departure from the custom of the community (typically: a large-scale defendant that has adopted standards applicable to its own operations or its own employees). Departure impugns any claim by the defendant that the risk is unforeseeable or that the safety practice is

unfeasible. What happens when the actor departs from its own standard? The main question is the admissibility of introducing evidence regarding the defendant's violation of its own standard as admissible on the issue of negligence. Divided results. Grounds: if the admission of evidence is to be used against the defendant as an admission of departure, he would naturally find it to his interest NOT to adopt any rules at all. Counterargument: The defendant itself had made these decisions, *facta propria*.

Trimarco v. Klein (N.Y. 1982): plaintiff injured in 1976 when he slipped in his bathroom and received serious lacerations from crashing against a shower door made of ordinary glass estimated to be between 1/16 and ¼ an inch thick. The shower had been installed in the 1950´s, when the use of ordinary glass was standard practice. Since the mid-60´s , the common practice in NYC had been to use safer tempered glass… Must all old shower doors be replaced? Sprinklers and burglar alarms be retrofitted in old buildings?

Why should conformity to the practice protect a physician from liability? One good ground: no other standard is practical. The battle of the experts. The (technical) incompetence of courts.

Local or national standards?: "The time has come when the medical profession should no longer be Balkanized by the application of varying geographic standards" (Brune v. Bellinkoff, Mass 1968). The proper standard is whether the physician has exercised the degree of care and skill of the average qualified practitioner, taking into account the advances in the profession.

Read: Kenneth S. ABRAHAM, *Custom, Non-customary Practice, and Negligence*, 109 Colum , l. Rev. 1784 (2009).

3.2. Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Instrumentos de control social y derecho de daños", *InDret* 4/2004 (www.indret.com), pp. 10-12

"*El Derecho de Daños como instrumento de control social: un ejemplo sencillo aplicado a la instalación de dispositivos ABS para vehículos*

Para ilustrar cómo el derecho, y el derecho de daños en particular, contribuye a pasar de peores a mejores situaciones puede servir un ejemplo inspirado en otro que se puede encontrar en SCÄFER/OTT (2000) y que hemos reformulado para adaptarlo al sistema de frenado ABS (***Anti-Block System***) para automóviles. Éste es un dispositivo electrónico antibloqueo que controla la presión de líquido de los frenos y de esta forma evita que las ruedas se bloqueen cuando se ejerce una presión excesiva sobre el pedal, generalmente en situaciones de alto riesgo. En 1978, Mercedes Benz instala el primer sistema ABS en un coche de serie como sistema opcional. Con posterioridad, muchas firmas lo incorporaron a sus vehículos como equipo de serie, aunque todavía no era obligatorio[1].

Es indudable que este dispositivo mejora la capacidad de frenado de un vehículo bajo cualquier circunstancia por lo que evita accidentes individuales y también colectivos. Pero además, si

[1] El sistema de antibloqueo de ruedas al frenar (ABS) se convirtió en un dispositivo de serie obligatorio para todos los turismos nuevos vendidos en la Unión Europea a partir de 2003, en virtud de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión «Protección de los peatones: Compromiso de la industria europea del automóvil» (COM(2001) 389 — C5-0537/2001— 2001/2216(COS)), de 13 de junio de 2002 (P5_TA(2002)0323; DO C 261 E/576, de 30.10.2003). Sin embargo, la normativa se ha visto ya superada en este punto por el Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200\1, de 31.7.2009), el cual estableció el ESP (*Electronic Stability Control*, que incluye la función de ABS) como dispositivo de serie obligatorio en todos los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que se vendan en la Unión Europea desde el 1 de noviembre de 2011.

todos disponen del mismo, contribuye a disminuir en gran medida la probabilidad de colisión entre vehículos. Es este segundo efecto el que nos interesa destacar aquí.

En un sencillo ejemplo, dos conductores (C1 y C2) barajan la posibilidad de instalar sendos sistemas de frenado ABS. La utilidad anual que cada conductor obtiene del disfrute de su automóvil es de 1200 €, y sus costes esperados serán de 600 € que resultan de una probabilidad del 6% de sufrir un accidente que le comportará daños por valor de 10.000 € (0,06 x 10.000). La instalación de un dispositivo de ABS tiene un coste de 100 € anuales ya que este sistema requiere de revisiones periódicas. Pero disponer de él reduce la probabilidad de sufrir un accidente de un 6% a un 2%, por lo que los costes esperados bajarán a 200 € (0'02 x 10.000).

Los *pay-offs* de una y otra opción para C1 y C2 figuran en la tabla siguiente:

		C2	
		ABS	NoABS
C1	ABS	900, 900	500, 600
	NoABS	600, 500	600, 600

Supongamos que C2 opta por instalar el ABS. Entonces C1 hará lo propio, pues 900 > 600 como podemos observar en la primera columna. Por el contrario, si C2 resuelve no instalarlo, C1 tampoco lo hará, pues estaremos en la segunda columna, 600 > 500. Si partimos de la decisión de C1 llegaremos a la misma conclusión, resultando las dos situaciones de equilibrio señaladas en la tabla. Se observa que existe un equilibrio eficiente (casilla superior izquierda) y otro ineficiente (casilla inferior derecha) que se corresponden con sendos equilibrios de Nash. A cuál de ellos se llegará, dependerá de circunstancias externas como señalan SCHÄFER y OTT para un ejemplo similar: si C1 sabe que C2 ha instalado el ABS, hará lo propio, pero si sabe que no lo ha hecho, tampoco lo hará él, pues un solo ABS no disminuye suficientemente la frecuencia y gravedad de las colisiones entre vehículos. *A priori*, bajo un sistema de ausencia de responsabilidad *(no liability rule)*, no hay garantías de que ninguna de las dos partes se comportará correctamente tras asumir que la otra lo hará.

Supongamos ahora una situación en la que existe una serie de n conductores C1, C2, C3,... Cn, para $1<n<\infty$ y p es la probabilidad de que un conductor haya instalado el sistema ABS en su vehículos. Entonces los beneficios esperados para C1 serán:

Beneficios en caso de ABS → $B(ABS)= p\cdot 900 + (1-p)\cdot 500= p\cdot 400 + 500$
Beneficios en caso de No ABS → $B(NoABS)= p\cdot 600 + (1-p)\cdot 600= 600$
(donde probabilidad: $p \in [0,1]$)

C1 optará por instalar ABS siempre que:

B(ABS)>B(NoABS), entonces:
$p\cdot 400 + 500 > 600$,
$p> 0'25$

De donde resulta que C1 instalará el ABS en su automóvil siempre que la probabilidad sea superior a 25%, esto es, cuando más de una cuarta parte de los vehículos dispongan de él, pero no lo hará si la proporción es inferior, pues no le saldrá a cuenta. El ejemplo ilustra un caso típico de instalación de dispositivos en los que se produce un efecto de externalidades de red – *network externalities*- ya que a mayor número de usuarios de un mismo producto o servicio, mayor será la utilidad que cada uno de ellos obtendrá de él. Pero, a pesar de que todos los interesados coincidan en que la difusión generalizada del producto sería socialmente

beneficiosa, la existencia de dos equilibrios puede comportar que los sucesivos intentos de comercializar el uso del producto fracasen debido a que la red no esté lo suficientemente extendida para crear los incentivos privados necesarios para la instalación. Pero un cambio de jurisprudencia o, por supuesto, de legislación podría dar un vuelco a esta situación: por ejemplo, si el Tribunal Supremo, ante un caso de reclamación de daños y perjuicios por colisión entre dos vehículos, resuelve que la falta de instalación de ABS es negligencia y que ésta reduce o anula la indemnización a que tendría derecho el actor, entonces ningún conductor podrá reclamar si no disponía de ABS y, en cambio, deberá pagar los daños resultantes al otro vehículo. Los pagos para C1 se verían modificados de la manera siguiente:

		C2, C3, C4,... Cn	
		ABS	NoABS
C1	ABS	900 900	0 1100
	NoABS	1100 0	600 600

(donde indemnización esperada: I = 0,06 x 10.000= 600)

Si instala ABS, en caso de colisión será indemnizado por aquél que fue negligente porque no lo instaló. En cambio, si no instala el sistema deberá pagar una indemnización a quién lo había instalado, o bien, en caso de que el otro tampoco lo hubiera instalado cada uno asumirá sus propios daños.

Podemos observar cómo independientemente de la decisión de los demás individuos, para C1 resulta más beneficioso instalar ABS ya que los pagos de la fila superior son siempre superiores a los de la inferior. De esta forma, el precedente jurisprudencial habría inducido los incentivos privados necesarios para la generalización del producto, que de otra forma no hubiera podido producirse".

Capítulo 5º
Negligencia (III): Negligencia *per se* y *res ipsa loquitur*

1. Negligencia *per se*. Infracción de normas legales. Presunciones 69
1.1. *Gorris v. Scott* (L.R. 9 Ex. 125 (1874)) 71
1.2. *Martin v. Herzog* (126 N.E. 814 (N.Y. 1920)) 73
1.3. *Tedla v. Ellman* (280 N.Y. 124, 19 N.E.2d 987 (1939)) 73
1.4. *Brown v. Shyne* (151 N.E. 197 (N.Y. 1926)) 75
1.5. SAP de Almería, Secc. 2ª, Penal, 286/2000, de 3 de julio 77
1.6. *Uhr v. East Greenbush Cent. Sch. Dist.* (720 N.E.2d 886 (N.Y. 1999)) 80
1.7. STS, 1ª, 223/2013, de 12 de abril 82
1.8. STS, 1ª, 909/2005, de 9 de noviembre 82
1.9. STS, 1ª, 17/2004, de 3 de febrero 83
1.10. *Preemption* 84
2. *Res ipsa loquitur* 90
2.1. *Byrne v. Boadle* (159 Eng. Rep. 299 (Ex. 1863)) 91
2.2. *Colmenares Vivas v. Sun Alliance Insurance Co.* (807 F.2d 1102 (1st Cir. 1986)) . 91
2.3. *Ybarra v. Spangard* (25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687) 94
2.4. STS, 1ª, 1146/1998, de 9 de diciembre 95
2.5. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla 95
2.6. Otras sentencias sobre responsabilidad médica por daños desproporcionados 96

1. Negligencia *per se*. Infracción de normas legales. Presunciones

En esta Sesión, tratamos fundamentalmente de tres cuestiones:

En el Common Law, la conducta de quien infringe una ley escrita –o un reglamento—se presume negligente si el fin de protección de la normativa violada es justamente amparar a la víctima de los daños causados: si así es, el demandante no habrá de probar la negligencia del demandado sino únicamente el daño y la causalidad. La presunción admite prueba en contrario (negligencia *per se*). En cambio, si la ley quebrantada no persigue proteger a la víctima de los daños sufridos, su infracción conllevará la aplicación de las consecuencias de derecho previstas por la ley violada, pero será irrelevante a efectos de apreciar la negligencia. Y, finalmente, si el demandado desarrolló su actividad dañina cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios, ello es un indicio de que actuó correctamente, pero, de nuevo, cabe probar que no fue así.

Más allá de la ley escrita o de las regulaciones aplicables a un sector de actividad, una doctrina jurisprudencial común al Common Law y al Civil Law establece que si un accidente tiene lugar en circunstancias tales que su ocurrencia normalmente solo se explica porque su causante ha infringido un deber de cuidado, entonces también se presume su negligencia, siempre con posibilidad de prueba en contrario (res ipsa loquitur).

En tercer lugar, uno de los temas más importantes de los derechos contemporáneos, en entornos intensamente regulados es el relativo a si la regulación legal y reglamentaria de tal o cual actividad, con la consiguiente aplicación de las consecuencias de derecho legalmente previstas que correspondan en caso de infracción, cierran el sistema e impiden el ejercicio de las pretensiones de daños previstas por el derecho común, por ejemplo, por el art. 1902 CC (preemption), o bien y por el contrario, dejan abierta tal posibilidad. En el Common Law angloamericano, la cuestión es muy debatida, pero hay acuerdo en que el legislador puede clausurar el sistema. El problema es doble: si lo hace expresamente, hay que interpretar la delimitación legal del cierre categorial. Y si el cierre es implícito, las dudas interpretativas suelen ser aún mayores.

El derecho español vigente trata de estas cuestiones algo idiosincrásicamente, sobre todo en el caso de la negligencia per se, pues, como veremos, todavía es frecuente encontrar afirmaciones de los tribunales conforme a las cuales la producción del daño permite inferir la negligencia de su causante incluso si cumplió con todas las exigencias legales y reglamentarias.

Comenzaremos analizando los criterios del ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010) -RTT-, que extractamos del original en inglés y que ofrecen una buena base para una discusión de la negligencia per se en términos de razonabilidad, pero, como acabamos de señalar, no dan razón cabal del derecho español vigente:

§ 14 RTT. Statutory Violations as Negligence Per Se

An actor is negligent if, without excuse, the actor violates a statute that is designed to protect against the type of accident the actor´s conduct causes, and if the accident victim is within the class of persons the statute is designed to protect.

- This section applies to statutes, regulations and ordinances.

- Express and implied statutory causes of action: Some statutes declare conduct unlawful, impose a public-law penalty on the person whose conduct violates the statute, and also specify that the violator is civily liable in damages to the victim of the violation. Certain other statutes simply state that, if certain conduct causes harm, the actor is liable to a victim. Yet large numbers of statutes (…) are silent as to private liability in the event of a statutory violation. Then, the court, relying on ordinary principles of legislative interpretation, may in appropriate cases infer a cause of action for damages.

- Rationales:

a) It would be akward for a court in a tort case to commend as reasonable that behavior that tle legislature has already condemned as unlawful.

b) The judgement of the legislature is the authoritative representative of the community.

c) The negligence standard encounters difficulty in dealing with problems of recurring conduct. (…) statutes address conduct that conspicuously recurs in a way that brings it to the attention of the legislature. Negligence per se hence replaces decision making by juries [career judges].

d) Furthermore, negligence has been settled doctrine in American tort law for many decades, [not under Spanish Law: see infra].

- Negligence per se applies only when the accident that injures the plaintiff is the type of accident that the statute seeks to avert. In some cases, negligence per se does not apply because the statute is not a safety statute at all.

- Licensing statutes: One general purpose of such licensing statutes is to protect the public against physical and emotional harm (…) but in many cases, the immediate reason for the person´s lack of license is unrelated to the state´s general safety purpose. For example, a motorist may lack a license only because of a failure to file for license renewal. If this motorist is involved in an accident, the lack of license has no bearing on the motorist´s negligence. Similarly, a physician may lack a license in a state only because the physician has not yet satisfied the state´s residency requirement. In other cases, however, this general assessment does not pertain. If, for example, a person operates a motorcycle in a way that suggests a lack of skill, and if the evidence shows that the person does not have a license to operate a motorcycle because the person has failed the test that assesses skills, then, depending on the jurisdiction´s rules, the lack of a license may be negligence per se or admissible as tending to show the person´s negligent unskillfulness. Same if a property owner has installed a furnace without securing a permit required by a city ordinance, and the evidence indicates that the inspector would not have issued the permit (…).

- Negligence per se is clearly inappropriate when the actor´s conduct fall below the requirements of a statute enacted **after** the conduct occurred. However, a later-enacted statute can be admissible evidence bearing on the actor´s negligence.

Viceversa, el cumplimiento por el demandado de las regulaciones dictadas para proteger los intereses o la integridad del demandante no excluirá la posibilidad de que este último pruebe la negligencia de aquel, pero será un indicio de que la conducta puesta en cuestión fue correcta, diligente.

Como hemos señalado al inicio de esta Sesión, esta doble construcción no ha sido recibida por el derecho español ni, específicamente, por su jurisprudencia. Esta, como se verá a continuación, a menudo ha sostenido que el cumplimiento de las disposiciones dictadas para prevenir el daño causado no es óbice a la declaración de la existencia de negligencia, pues esta existiría porque el hecho mismo de que se haya producido el accidente implica que las regulaciones eran o habían devenido insuficientes y que alguna negligencia había debido de tener lugar: es una especie de animismo jurídico, acaso propio de un pensamiento primitivo.

Sin embargo y en ocasiones, esta jurisprudencia es contrarrestada por otra según la cual no cabe alegar en casación y ante la Sala 1ª la infracción de normas reglamentarias y puramente administrativas. Tampoco aquí parece que el Tribunal Supremo ande acertado: la mayor parte de las actividades que no pertenecen a los actos más sencillos de la vida cotidiana están intensamente reguladas y la consideración de los estándares establecidos por los agentes reguladores debería de ser un elemento muy importante para evaluar la diligencia o negligencia del demandado. La división jurisdiccional genera así una doctrina oracular e ignora el principio de la unidad del ordenamiento jurídico, de la vieja y buena idea conforme a la cual una tarea básica del intérprete es concordar razonadamente cánones discordantes.

§ 16 RTT Statutory Compliance

(a) An actor´s compliance with a pertinent statute, while evidence of nonnegligence, does not preclude finding that the actor is negligent under § 3 for failing to adopt precautions in addition to those mandated by the statute.

(b) If an actor´s adoption of a precaution would require the actor to violate a statute, the actor cannot be found negligent for failing to adopt that precaution.

- While Subsection (a) states the [U.S.] general common-law rule, this rule can be overcome by a particular statute expressing a contrary understanding.
- In each instance, compliance is evidence of non negligence but it is not conclusive.
- Statutes that merely set minimum standards.
- Unusual circumstances. A finding that additional precautions are called for despite the actor´s compliance with the statute is clearly appropriate if the precaution relates to some unusual situation beyond the generality of situations anticipated by the statute itself.

1.1. *Gorris v. Scott* (L.R. 9 Ex. 125 (1874))

The plaintiffs were entitled to assume that the defendant would perform all the duties cast upon him by the law, including compliance with these orders; and that being so, the defendant has impliedly contracted with the plaintiffs that he would perform them.

Kelly, C.B. This is an action to recover damages for the loss of a number of sheep which the defendant, a shipowner, had contracted to carry, and which were washed overboard and lost by reason (as we must take it to be truly alleged) of the neglect to comply with a certain order made by the Privy Council, in pursuance of the Contagious Diseases (Animals) Act, 18G9. The Act was passed merely for sanitary purposes, in order to prevent animals in a state of infectious disease from communicating it to other animals with which they might come in contact. Under the authority of that Act, certain orders were made; amongst others, an order by which any ship bringing sheep or cattle from any foreign port to ports in Great Britain is to have the place

occupied by such animals divided into pens of certain dimensions, and the floor of such pens furnished with battens or foot-holds. The object of this order is to prevent animals from being overcrowded, and so brought into a condition in which the disease guarded against would be likely to be developed. This regulation has been neglected, and the question is, whether the loss, which we must assume to have been caused by that neglect, entitles the plaintiffs to maintain an action.

The argument of the defendant is, that the Act has imposed penalties to secure the observance of its provisions, and that, according to the general rule, the remedy prescribed by the statute must be pursued ; that although, when penalties are imposed for the violation of a statutory duty, a person aggrieved by its violation may sometimes maintain an action for the damage so caused, that must be in cases where the object of the statute is to confer a benefit on individuals, and to protect them against the evil consequences which the statute was designed to prevent, and which have in fact ensued ; but that if the object is not to protect individuals against the consequences which have in fact ensued, it is otherwise ; that if, therefore, by reason of the precautions in question not having been taken, the plaintiffs had sustained that damage against which it was intended to secure them, an action would lie, but that when the damage is of such a nature as was not contemplated at all by the statute, and as to which it was not intended to confer any benefit on the plaintiffs, they cannot maintain an action founded on the neglect. The principle may be well illustrated by the case put in argument of a breach by a railway company of its duty to erect a gate on a level crossing, and to keep the gate closed except when the crossing is being actually and properly used. The object of the precaution is to prevent injury from being sustained through animals or vehicles being upon the line at unseasonable times; and if by reason of such a breach of duty, either in not erecting the gate, or in not keeping it closed, a person attempts to cross with a carriage at an improper time, and injury ensues to a passenger, no doubt an action would lie against the railway company, because the intention of the legislature was that, by the erection of the gates and by their being kept closed individuals should be protected against accidents of this description. And if we CO see that it was the object, or among the objects of this Act, that the owners of sheep and cattle coming from a foreign port should be protected by the means described against the danger of their property being washed overboard, or lost by the perils of the sea, the present action would be within the principle. But, looking at the Act, it is perfectly clear that its provisions were all enacted with a totally different view ; there was no purpose, direct or indirect, to protect against such damage ; but, as is recited in the preamble, the Act is directed against the possibility of sheep or cattle being exposed to disease on their way to this country. The preamble recites that "it is expedient to confer on Her Majesty's most honourable Privy Council power to take such measures as may appear from time to time necessary to prevent the introduction into Great Britain of contagious or infectious diseases among cattle, sheep, or other animals, by prohibiting or regulating the importation of foreign animals," and also to provide against the " spreading " of such diseases in Great Britain. Then follow numerous sections directed entirely to this object. Then comes s. 75, which enacts that "the Privy Council may from time to time make such orders as they think expedient for all or any of the following purposes." What, then, are these purposes? They are "for securing for animals brought by sea to ports in Great Britain a proper supply of food and water during the passage and on landing," " for protecting such animals from unnecessary suffering during the passage and on landing," and so forth, all the purposes enumerated being calculated and directed to the prevention of disease, and none of them having any relation whatever to the clanger of loss by the perils of the sea. That being so, if by reason of the default in question the plaintiffs' sheep had been overcrowded, or had been caused unnecessary suffering, and so had arrived in this country in a state of disease, I do not say that they might not have maintained this action. But the damage complained of here is something totally apart from the object of the Act of Parliament, and it is in accordance with all the authorities to say that the action is not maintainable.

Judgment for the defendant.

1.2. *Martin v. Herzog* (126 N.E. 814 (N.Y. 1920))

[The decedent was killed in a collision between the buggy he was driving and defendant's automobile. The accident occurred after dark, and decedent was driving the buggy without any lights, in violation of a statute. The defendant requested a ruling that the absence of a light on the plaintiff's vehicle was "prima facie evidence of contributory negligence". This request was refused, and the jury was instructed that it might consider the absence of lights as some evidence of negligence, but not conclusive evidence of negligence. The plaintiff next requested a charge that "the fact that the plaintiff's intestate was driving without a light is not negligence in itself", and to this the court acceded. The jury found the defendant liable and the decedent free from contributory negligence and the plaintiff had judgment. The appellate division reversed for error in the instructions. Affirmed].

CARDOZO, J. […] We think the unexcused omission of the statutory signals is more than some evidence of negligence. It is negligence in itself. Lights are intended for the guidance and protection of other travelers on the highway. By the very terms of the hypothesis, to omit, willfully or heedlessly, the safeguards prescribed by law for the benefit of another that he may be preserved in life or limb, is to fall short of the standard of diligence to which those who live in organized society are under a duty to conform. […] In the case at hand, we have an instance of the admitted violation of a statute intended for the protection of travelers on the highway, of whom the defendant at the time was one. Yet the jurors were instructed in effect that they were at liberty in their discretion to treat the omission of lights either as innocent or as culpable. They were allowed to "consider the default as lightly or gravely" as they would (Thomas, J., in the court below). They might as well have been told that they could use a like discretion in holding a master at fault for the omission of a safety appliance prescribed by positive law for the protection of a workman. Jurors have no dispensing power by which they may relax the duty that one traveler on the highway owes under the statute to another. It is error to tell them that they have. The omission of these lights was a wrong, and being wholly unexcused was also a negligent wrong. No license should have been conceded to the triers of the facts to find it anything else.

We must be on our guard, however, against confusing the question of negligence with that of the causal connection between the negligence and the injury. A defendant who travels without lights is not to pay damages for his fault unless the absence of lights is the cause of the disaster. A plaintiff who travels without them is not to forfeit the right to damages unless the absence of lights is at least a contributing cause of the disaster. To say that conduct is negligence is not to say that it is always contributory negligence.

[…] A statute designed for the protection of human life is not to be brushed aside as a form of words, its commands reduced to the level of cautions, and the duty to obey attenuated into an option to conform. […]

1.3. *Tedla v. Ellman* (280 N.Y. 124, 19 N.E.2d 987 (1939))

LEHMAN, J.

While walking along a highway, Anna Tedla and her brother, John Bachek, were struck by a passing automobile, operated by the defendant Hellman. She was injured and Bachek was killed. Bachek was a deaf-mute. His occupation was collecting and selling junk. His sister, Mrs. Tedla, was engaged in the same occupation. They often picked up junk at the incinerator of the village of Islip. At the time of the accident they were walking along 'Sunrise Highway' and wheeling baby carriages containing junk and wood which they had picked up at the incinerator. It was about six o'clock, or a little earlier, on a Sunday evening in December. Darkness had already set in. Bachek was carrying a lighted lantern, or, at least, there is testimony to that effect. The jury found that the accident was due solely to the negligence of the operator of the automobile. The defendants do not, upon this appeal, challenge the finding of negligence on the part of the operator. They maintain, however, that Mrs. Tedla and her brother were guilty of contributory negligence as matter of law.

Sunrise Highway, at the place of the accident, consists of two roadways, separated by a grass plot. There are no footpaths along the highway and the center grass plot was soft.

It is not unlawful for a pedestrian, wheeling a baby carriage, to use the roadway under such circumstances, but a pedestrian using the roadway is bound to exercise such care for his safety as a reasonably prudent person would use. The Vehicle and Traffic Law (Cons. Laws, ch. 71) provides that 'Pedestrians walking or remaining on the paved portion, or traveled part of a roadway shall be subject to, and comply with, the rules governing vehicles, with respect to meeting and turning out, except that such pedestrians shall keep to the left of the center line thereof, and turn to their left instead of right side thereof, so as to permit all vehicles passing them in either direction to pass on their right. Such pedestrians shall not be subject to the rules governing vehicles as to giving signals.' (§ 85, subd. 6.) **Mrs. Tedla and her brother did not observe the statutory rule and, at the time of the accident, were proceeding in easterly direction on the east-bound or right-hand roadway**. The defendants moved to dismiss the complaint on the ground, among others, that violation of the statutory rule constitutes contributory negligence as matter of law. They did not, in the courts below, urge that any negligence in other respect of Mrs. Tedla or her brother bars a recovery. The trial judge left to the jury the question whether failure to observe the statutory rule was a proximate cause of the accident; he left to the jury no question of other fault or negligence on the part of Mrs. Tedla or her brother, and the defendants did not request that any other question be submitted. Upon this appeal, the only question presented is whether, as matter of law, disregard of the statutory rule that pedestrians shall keep to the left of the center line of a highway constitutes contributory negligence which bars any recovery by the plaintiff […].

The plaintiffs showed by the testimony of a State policeman that 'there were very few cars going east' at the time of the accident, but that going west there was 'very heavy Sunday night traffic. Until the recent adoption of the new statutory rule for pedestrians, ordinary prudence would have dictated that pedestrians should not expose themselves to the danger of walking along the roadway upon which the 'very heavy Sunday night traffic' was proceeding when they could walk in comparative safety along a roadway used by very few cars. It is said that now, by force of the statutory rule, pedestrians are guilty of contributory negligence as matter of law when they use the safer roadway, unless that roadway is left of the center of the road. Disregard of the statutory rule of the road and observance of a rule based on immemorial custom, it is said, is negligence which as matter of law is a proximate cause of the accident, though observance of the statutory rule might, under the circumstances of the particular case, expose a pedestrian to serious danger from which he would be free if he followed the rule that had been established by custom. If that be true, then the Legislature has decreed that pedestrians must observe the general rule of conduct which it has prescribed for their safety even under circumstances where observance would subject them to unusual risk; that pedestrians are to be charged with negligence as matter of law for acting as prudence dictates. It is unreasonable to ascribe to the Legislature an intention that the statute should have so extraordinary a result, and the courts may not give to a statute an effect not intended by the Legislature […].

The statute upon which the defendants rely is of different character. It does not prescribe additional safeguards which pedestrians must provide for the preservation of the life or limb or property of others, or even of themselves, nor does it impose upon pedestrians a higher standard of care. What the statute does provide is rules of the road to be observed by pedestrians and by vehicles, so that all those who use the road may know how they and others should proceed, at least under usual circumstances. A general rule of conduct -- and, specifically, a rule of the road -- may accomplish its intended purpose under usual conditions, but, when the unusual occurs, strict observance may defeat the purpose of the rule and produce catastrophic results.

Negligence is failure to exercise the care required by law. Where a statute defines the standard of care and the safeguards required to meet a recognized danger, then, as we have said, no other measure may be applied in determining whether a person has carried out the duty of care imposed by law. Failure to observe the standard imposed by statute is negligence, as matter of

law. On the other hand, where a statutory general rule of conduct fixes no definite standard of care which would under all circumstances tend to protect life, limb or property but merely codifies or supplements a common-law rule, which has always been subject to limitations and exceptions; or where the statutory rule of conduct regulates conflicting rights and obligations in manner calculated to promote public convenience and safety, then the statute, in the absence of clear language to the contrary, should not be construed as intended to wipe out the limitations and exceptions which judicial decisions have attached to the common-law duty; nor should it be construed as an inflexible command that the general rule of conduct intended to prevent accidents must be followed even under conditions when observance might cause accidents. We may assume reasonably that the Legislature directed pedestrians to keep to the left of the center of the road because that would cause them to face traffic approaching in that lane and would enable them to care for their own safety better than if the traffic approached them from the rear. We cannot assume reasonably that the Legislature intended that a statute enacted for the preservation of the life and limb of pedestrians must be observed when observance would subject them to more imminent danger.

[…] A pedestrian is, of course, at fault if he fails without good reason to observe the statutory rule of conduct. The general duty is established by the statute, and deviation from it without good cause is a wrong and the wrongdoer is responsible for the damages resulting from his wrong.

In each action, the judgment should be affirmed, with costs.

1.4. *Brown v. Shyne* (151 N.E. 197 (N.Y. 1926))

LEHMAN, J. The plaintiff employed the defendant to give chiropractic treatment to her for a disease or physical condition. The **defendant had no license to practice medicine**, yet he held himself out as being able to diagnose and treat disease, and under the provisions of the Public Health Law he was guilty of a misdemeanor. The plaintiff became paralyzed after she had received nine treatments by the defendant. She claims, and upon this appeal we must assume, that the paralysis was caused by the treatment she received. She has recovered judgment in the sum of $ 10,000 for the damages caused by said injury. […]

At the close of the plaintiff's case the plaintiff was permitted to amend the complaint to allege "that in so treating the plaintiff the defendant was engaged in the practice of medicine contrary to and in violation of the provisions of the Public Health Law of the State of New York in such case made and provided, he at the time of so treating plaintiff not being a duly licensed physician or surgeon of the State of New York." Thereafter the trial judge charged the jury that they might bring in a verdict in favor of the plaintiff if they found that the evidence established that the treatment given to the plaintiff was not in accordance with the standards of skill and care which prevail among those treating disease. He then continued: "This is a little different from the ordinary malpractice case, and I am going to allow you, if you think proper under the evidence in the case, to predicate negligence upon another theory. The public health laws of this State prescribe that no person shall practice medicine unless he is licensed so to do by the Board of Regents of this State and registered pursuant to statute. This statute to which I have referred is a general police regulation. Its violation, and it has been violated by the defendant, is some evidence, more or less cogent, of negligence which you may consider for what it is worth, along with all the other evidence in the case. If the defendant attempted to treat the plaintiff and to adjust the vertebrae in her spine when he did not possess the requisite knowledge and skill as prescribed by the statute to know what was proper and necessary to do under the circumstances, or how to do it, even if he did know what to do, you can find him negligent." In so charging the jury that from the violation of the statute the jury might infer negligence which produced injury to the plaintiff, the trial justice in my opinion erred.

The provisions of the Public Health Law prohibiting the practice of medicine without a license granted upon proof of preliminary training and after examination intended to show adequate knowledge, are of course intended for the protection of the general public against injury which unskilled and unlearned practitioners might cause. If violation of the statute by the defendant

was the proximate cause of the plaintiff's injury, then the plaintiff may recover upon proof of violation; if violation of the statute has no direct bearing on the injury, proof of the violation becomes irrelevant. For injury caused by neglect of duty imposed by the penal law there is civil remedy; but of course the injury must follow from the neglect.

Proper formulation of general standards of preliminary education and proper examination of the particular applicant should serve to raise the standards of skill and care generally possessed by members of the profession in this State; but the license to practice medicine confers no additional skill upon the practitioner; nor does it confer immunity from physical injury upon a patient if the practitioner fails to exercise care. Here, injury may have been caused by lack of skill or care; it would not have been obviated if the defendant had possessed a license yet failed to exercise the skill and care required of one practicing medicine. True, if the defendant had not practiced medicine in this State, he could not have injured the plaintiff, but the protection which the statute was intended to provide was against risk of injury by the unskilled or careless practitioner, and unless the plaintiff's injury was caused by carelessness or lack of skill, the defendant's failure to obtain a license was not connected with the injury. The plaintiff's cause of action is for negligence or malpractice. The defendant undertook to treat the plaintiff for a physical condition which seemed to require remedy. Under our law such treatment may be given only by a duly qualified practitioner who has obtained a license. […]

No case has been cited where neglect of a statutory duty has given rise to private cause of action where it has not appeared that private injury has been caused by danger against which the statute was intended to afford protection, and which obedience to the statute would have obviated. […]

It is said that the trial justice did not charge that plaintiff might recover for defendant's failure to obtain a license but only that failure to obtain a license might be considered "some evidence" of defendant's negligence. Argument is made that even if neglect of the statutory duty does not itself create liability, it tends to prove that injury was caused by lack of skill or care. That can be true only if logical inference may be drawn from defendant's failure to obtain or perhaps seek a license that he not only lacks the skill and learning which would enable him to diagnose and treat disease generally, but also that he lacks even the skill and learning necessary for the physical manipulation he gave to this plaintiff. Evidence of defendant's training, learning and skill and the method he used in giving the treatment was produced at the trial and upon such evidence the jury could base finding either of care or negligence, but the absence of a license does not seem to strengthen inference that might be drawn from such evidence, and a fortiori would not alone be a basis for such inference. Breach or neglect of duty imposed by statute or ordinance may be evidence of negligence only if there is logical connection between the proven neglect of statutory duty and the alleged negligence.

Crane, J. (dissenting) […] What is the rule which is to guide us in determining whether a violation of a statute or ordinance is evidence of negligence? It is no answer to say that the statute provides a penalty, and, therefore, no other consequences can follow. Such is not the law. We are to determine it, as I read the authorities, from the purpose and object of the law, and also from the fact whether a violation of the law may be the direct and proximate cause of an injury to an individual. […]

The prohibition against practicing medicine without a license was for the very purpose of protecting the public from just what happened in this case. The violation of this statute has been the direct and proximate cause of the injury. The courts will not determine in face of this statute whether a faith healer, a patent medicine man, a chiropractor, or any other class of practitioner acted according to the standards of his own school, or according to the standards of a duly licensed physician. The law, to insure against ignorance and carelessness, has laid down a rule to be followed, namely, examinations to test qualifications, and a license to practice. If a man, in violation of this statute, takes his chances in trying to cure disease, and his acts result directly in injury, he should not complain if the law, in a suit for damages, says that his violation of the statute is some evidence of his incapacity.

1.5. SAP de Almería, Secc. 2ª, Penal, 286/2000, de 3 de julio

ANTECEDENTES DE HECHO

[…] Hechos probados

«El acusado Antonio N. G, mayor de edad y sin antecedentes penales con título de Licenciado en Medicina y Cirugía, habilitado mediante el oportuno certificado del Ministerio de Sanidad y Consumo para despeñar las funciones de Médico de Medicina General en el Sistema nacional de Sanidad Español, así como en los sistemas Públicos de Seguridad Social de los demás Estados miembros de la Unión Europea, desde fechas no concretadas es el titular de la Clínica "Nueva Andalucía", sita en la calle Blas Infante, ..., de Almería que se anunciaba públicamente al menos hasta 1998 en las páginas amarillas de la guía telefónica dentro del apartado "Médicos: Cirugía Plástica y Reparadora" como clínica de estética pero donde se practican Cirugía Plástica, Liposucciones y Microcirugía, y en la que efectivamente el acusado ha venido realizando ese tipo de intervenciones de cirugía plástica y liposucciones sin estar en posesión del título correspondiente de cirugía Plástica que le habilite para ello, junto a otro tipo de intervenciones quirúrgicas, y sin adoptar las mínimas precauciones exigidas por la "lex artis" de la Medicina.

Así, en fechas próximas a los meses de marzo y abril de 1994 el acusado atendió en dicha Clínica que regenta a doña Carmen Bernardina G. H. y a doña Isabel A. T., que acudieron a su consulta para tratar sus problemas de obesidad, aconsejando el acusado a cada una en su caso que deberían someterse a una intervención de liposucción y, previamente a ello, a un tratamiento que ambas pacientes aceptaron, consistente en una formulación magistral que al principio encargaba al Farmacéutico de Málaga, don Juan M. S., quien la preparaba y encapsulaba y enviaba con su etiqueta, por indicación del acusado, a ambas pacientes a sus respectivos domicilios y que ellas abonaban directamente al citado Farmacéutico, formulación esta que con posterioridad el acusado –pese a no estar en posesión del título de Licenciado en Farmacia– decidió prepararlas y encapsularlas en su clínica, y facilitarlas así a ambas pacientes, alterando la composición de los medicamentos, añadiendo otras sustancias que no figuraban en la etiqueta […].

Posteriormente, en fechas 29 de marzo y 11 de mayo de 1994, fueron sometidas por el acusado a sendas intervenciones, previo pago por parte de cada una de ellas de 200.000 pesetas, quienes decidieron someterse a las mismas voluntariamente, concretamente de liposucción de cadera y rodillas en el caso de doña Carmen, y de caderas, parte interna de los muslos y rodillas en el caso de doña Isabel, sin observar dicho individuo las más mínimas reglas de la práctica de la Medicina, realizando análisis de sangre incontrolados en los resultados, sin disponer del apoyo de profesionales especializados para evitar complicaciones, que eran perfectamente posibles e, incluso, aparecieron, aplicando en ambas mujeres con diversas anomalías estéticas y funcionales en las zonas intervenidas consecuencia del empleo por parte del acusado de una técnica quirúrgica y terapéutica inadecuada, lo que ha producido: En el caso de doña Carmen: secuelas: a nivel de la región femoral anterior y externa una zona de induración producida por el tacto de la fascia lata (incluso con reacción de fibrosis), con desaparición de todo el panículo adiposo a este nivel; dolor a este nivel; falta de fuerza muscular; limitación de la flexión en ambas rodillas de 120º (siendo la anormal de 135º); defecto estético a nivel de región glútea por aspiración insuficiente, no equilibrada, de exceso adiposo y cutáneo a nivel lateral de ambas rodillas y sobrecorrección zona medial, y de asimetría de las regiones femorales anteriores por sobrecorrección mayor nivel de miembro derecho; todo ello con 130 días de incapacidad, de los cuales 30 estuvo impedida para sus ocupaciones habituales. Durante la intervención sufrió un espasmo de glotis, que precisó de sutura.

En el caso de doña Isabel: Secuelas consistentes en zona de induración a nivel de cara posterior de ambas piernas, más acentuada y palpable al tacto en movimientos de fuerza o de extensión completa; este defecto se debe a una sobre corrección durante la liposucción, desapareciendo todo el panículo adiposo y habiendo originado incluso un proceso de fibrosis de la fascia muscular de la masa muscular gemelar; también, abultamientos y depresiones en piel a nivel de regiones femorales producidos por acúmulos de grasa (seromas), originados por una resección irregular; defecto a nivel cara interna de muslo derecho por resección excesiva; defecto a nivel

de ambas rodillas, visible en extensión y flexión, producido por una resección excesiva; cicatriz de rasgos leves en cara posterior de pierna derecha de 3 x 2 cm; defecto estético de la silueta, ya que al tratar la región femoral y no la cresta ilíacas (están por encima), se acentúa la silueta con deformidad en violín; todo ello tardando 131 días en curar, de los que estuvo 30 incapacitada para sus ocupaciones habituales. Tras la intervención, la paciente desarrolla un cuadro de alergia al esparadrapo utilizado, pese a que constaba en la historia su alergia a una clase determinada.

Ambas mujeres necesitaron para la curación, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico, pero, además, para quedar totalmente restablecidas precisarán además de tratamiento quirúrgico mediante cirugía plástica y reparadora, con un coste estimado para cada intervención de 1.800.000 pesetas».

TERCERO

[La Sentencia del Juzgado Penal] contiene el siguiente fallo: «Que debo condenar y condeno a Antonio N. G., como autor de dos delitos de imprudencia temeraria genérica de los arts. 565,1º y 4º con relación al art. 420-1º CP 1973, a la pena, por cada uno de ellos, de seis meses de arresto mayor, con la accesoria de suspensión del ejercicio de la profesión de Médico durante el tiempo de duración de las respectivas condenas. También, como autor de un delito de intrusismo profesional del art. 403, párrafo primero, inciso segundo, con relación al subtipo agravado del párrafo segundo del CP 1995 (carencia de título oficial referente a la especialidad médica de Cirugía Plástica y Reparadora, con ostentación pública de ello), a la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de médico durante el tiempo de la condena. Igualmente, como autor de otro delito de intrusismo profesional de párrafo primero, inciso primero, del art. 403 CP (falta de título académico de farmacéutico) a la pena de multa de nueve meses, con cuota diaria de 2.000 pesetas, lo que hace un total de 540.000 pesetas, que se pagarán en dos plazos como máximo, y caso de impago de la misma, previa excusión de bienes, a un arresto sustitutorio equivalente a un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas. […].

En cuanto a responsabilidad civil indemnizará:

A doña Carmen Bernardina G. H. en 150.000 pesetas por los 30 días de incapacidad sufridos; por los 130 días de curación 390.000 pesetas; por la intervención quirúrgica que tiene pendiente, la cantidad de 1.800.000 pesetas; por secuela, alzadamente 7.000.000 de pesetas.

A doña Isabel A. T. en 150.000 pesetas por los 30 días de incapacidad sufridos; en 393.000 pesetas por los 131 días de curación; en 1.800.000 pesetas por la intervención quirúrgica de la que pende; en 7.000.000 de pesetas por las secuelas […]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

[…E]s doctrina extensa y pormenorizada respecto de la imprudencia médica la que recuerda:

> a) Que el error de diagnóstico, por regla general no es tipificable, salvo que por su entidad y dimensiones constituya una equivocación inexcusable.
> b) Que queda fuera del ámbito penal, por la misma razón, la falta de pericia cuando ésta sea de naturaleza extraordinaria y excepcional.
> c) Que la determinación de la responsabilidad médica debe hacerse en contemplación de las circunstancias concretas del caso sometido a enjuiciamiento.
> d) Que la imprudencia nace cuando el tratamiento médico y quirúrgico incide en comportamientos descuidados, de abandono y omisión de los cuidados exigibles, atendidas las circunstancias del lugar, tiempo, personas y naturaleza de la lesión o enfermedad que olvidando la "lex artis" conduzca a resultados lesivos».

Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa resulta que […] existen una serie de datos probatorios que acreditan un proceder negligente en la conducta del facultativo porque el mismo carecía de la titulación suficiente para que llevara a cabo este tipo de operaciones, que por su envergadura y complejidad no debe ser realizado con la titulación de médico de medicina general, ya que la otra titulación aportada consistente en un documento expedido por la denominada Sociedad Española de Medicina Estética, se desconoce en qué consiste el mismo ni la naturaleza de la entidad que lo expide ya que no tiene el carácter de un organismo oficial. […].

Por otra parte no podemos ignorar las circunstancias previas a la operación de las perjudicadas en donde la analítica no resulta debidamente contrastada. […] Por consiguiente no hay constancia de que se hubiese llevado a cabo un preoperatorio adecuado.

Además las operaciones se efectuaron en un quirófano preparado para cirugía menor utilizando anestesia local a pesar de la larga duración de dichas operaciones […].

Finalmente debe tenerse en cuenta el resultado alcanzado consistente en lesiones graves y deformidades en los miembros inferiores de las denunciantes que necesitan de una operación de cirugía plástica para reparar las mismas […].

Con tales presupuestos fácticos no podemos sino considerar […] que el resultado producido ha sido por una culpa o negligencia inexcusable, por pretenderse efectuar unas operaciones de gran complejidad con escasos medios y utilizando técnicas de cirugía menor, sin tener la titulación adecuada para desarrollar dicha actividad, ni siquiera la experiencia que hubiese suplido dicha falta de titulación como lo acredita el resultado producido. […]

Se alega también por la parte recurrente una errónea valoración de la prueba. […] Se fundamenta este recurso en el hecho de que para realizar este tipo de operaciones de liposucción no es necesario tener una titulación específica bastando tener la titulación de médico de medicina general para poder atender problemas como el que motivó la intervención quirúrgica, es decir una obesidad de las denunciantes que fue tratada inicialmente con pastillas hasta que se vio conveniente la necesidad de efectuar la liposucción. En apoyo de su tesis se citan las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 23 marzo (RJ 1995\2699) y 16 junio de 1995 (RJ 1995\4917), entre otras, que precisan que la profesión de médico es una y sólo una siendo las especialidades variaciones de una única profesión... «en general cualquier médico sea o no especialista puede atender cualquier enfermedad a cualquier enfermo, incluso sobre aspectos de especialidad ajena, ya que el título de médico especialista sólo es necesario para ejercer la profesión con este carácter, es decir, no para ejercer la profesión, sino para ejercerla como especialista» […].

Con independencia de que la argumentación de la sentencia que se invoca debe ser aceptada por este Tribunal, en cuanto que supone una formulación genérica de la obligación y derecho de todo médico de prestar asistencia sanitaria de un modo general para atender cualquier tipo de enfermedad sin necesidad de ser especialista, sin embargo ello no supone que se pueda dar licencia o autorización para que cualquier médico ejercite la medicina desarrollando actividades propias de las especialidades médicas que como tales vienen definidas en el artículo 1 del Real Decreto 127/1984 de 11 de enero por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista. El límite entre la especialidad y la medicina general vendrá determinado en cada caso por las circunstancias concurrentes puesto que frecuentemente desde un médico generalista se llega al médico especialista a través del consejo y dirección de este último, sin perjuicio de que pueda tratarse y curar determinadas dolencias de escasa importancia, o de mayor en caso de urgencia médica, según las circunstancias, siendo el propio médico el que mejor puede trazar esa línea divisoria entre la especialización y la medicina general ya que ha estudiado las distintas asignaturas y ramas de la medicina sobre las que posteriormente se configuran las especialidades médicas. Es precisamente en esta línea divisoria en donde en cada caso concreto habrá que examinar en qué medida el médico que no tiene la especialización, equivalente a título oficial a efectos penales, ha podido incurrir en un delito de intrusismo por carecer de la titulación oficial necesaria sin perjuicio de que tenga la titulación de médico de medicina general.

[…] Este tipo de intervenciones quirúrgicas son propias de la cirugía plástica y reparadora, siendo ésta una especialidad médica para la que se requiere cinco años de preparación tras haber aprobado el correspondiente examen selectivo, lo que unido a los seis años de duración normal de la carrera de medicina determinan una preparación altamente cualificada para llevar a cabo intervenciones encuadrables en este tipo de especialidad […].

FALLAMOS

Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Antonio N. G. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Almería, de fecha 24-2-2000 debemos confirmar y confirmamos el fallo de dicha resolución, con declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada.

1.6. *Uhr v. East Greenbush Cent. Sch. Dist.* (720 N.E.2d 886 (N.Y. 1999))

ROSENBLATT, J. Education Law § 905(1) requires school authorities in the State of New York to examine students between eight and sixteen years of age for scoliosis at least once in each schoolyear. The principal issue on this appeal is whether the statute authorizes a private right of action.

During the 1992–1993 school year, the infant plaintiff was a seventh grade student at the Goff Middle School, operated by defendant East Greenbush Central School District. In October 1992, as part of a school program, a nurse screened her for scoliosis. The results were negative. She was examined during the following school year (1993–1994) by a school nurse who checked her height, weight and vision but allegedly did not screen her for scoliosis.

In March 1995, when the infant plaintiff was a ninth grader during the 1994–1995 school year at Columbia High School (also operated by the East Greenbush Central School District), a school nurse screened her for scoliosis and the examination proved positive. Her parents, who are also plaintiffs in this action, then had her examined by an orthopedic doctor who concluded that her scoliosis had progressed to the point that surgery was required instead of the braces that often can be utilized when the condition is diagnosed earlier. The infant plaintiff underwent surgery in July 1995.

Plaintiffs have alleged two causes of action against the East Greenbush Central School District and its Board of Education (collectively "the District"). One is based on a claimed violation of Education Law § 905(1), one on common law negligence. Plaintiffs assert, in essence, that the District was negligent in failing to examine the infant plaintiff for scoliosis during the 1993–1994 school year, as a result of which her ailment was allowed to progress undetected, to her detriment. Supreme Court granted the District's motion for summary judgment, holding that Education Law § 905(1) does not create a private right of action, and that plaintiffs had otherwise failed to state a claim for common law negligence. The Appellate Division affirmed. We granted leave to appeal to this Court and now affirm.

THE RELEVANT STATUTES

[…] Education Law § 905(1) states that "[m]edical inspectors or principals and teachers in charge of schools in this state shall . . . examine all . . . pupils between eight and sixteen years of age for scoliosis, at least once in each school year." Education Law § 905(2) provides that "[n]othwithstanding any other provisions of any general, special or local law, the school authorities charged with the duty of making such tests or examinations of pupils for the presence of scoliosis pursuant to this section shall not suffer any liability to any person as a result of making such test or examination, which liability would not have existed by any provision of law, statutory or otherwise, in the absence of this section." Finally, Education Law § 911 charges the Commissioner of Education with the duty of enforcing the provisions of sections 901 through 910 of the Education Law and authorizes the Commissioner to "adopt rules and regulations" for such purpose.

THE TEST FOR THE AVAILABILITY OF A PRIVATE RIGHT OF ACTION

The District's obligation to examine for scoliosis is, as plaintiffs point out, plain enough. A statutory command, however, does not necessarily carry with it a right of private enforcement by means of tort litigation.

The availability of a private right of action for the violation of a statutory duty –– as opposed to one grounded in common law negligence –– is not a new concept. When a statute itself expressly authorizes a private right of action, there is no need for further analysis. When a statute is silent, as it is here, courts have had to determine whether a private right of action may be fairly implied. […] In making the determination, we ask:

"(1) whether the plaintiff is one of the class for whose particular benefit the statute was enacted;
"(2) whether recognition of a private right of action would promote the legislative purpose; and
"(3) whether creation of such a right would be consistent with the legislative scheme".

[After concluding that the plaintiffs satisfied the first two parts, the court discussed the last requirement]. Plaintiffs argue that a private right of action is not only consistent with Education Law § 905(1) but also necessary for its operation. They assert that the statute offers no other practical means of enforcement and that a private right of action is imperative, in order to give it life. We disagree and conclude that a private right of action would not be consistent with the statutory scheme. To begin with, the statute carries its own potent official enforcement mechanism. The Legislature has expressly charged the Commissioner of Education with the duty to implement Education Law § 905(1) and has equipped the Commissioner with authority to adopt rules and regulations for such purpose (see, Education Law §§ 905[1], 911). Moreover, the Legislature has vested the Commissioner with power to withhold public funding from noncompliant school districts. Thus, the Legislature clearly contemplated administrative enforcement of this statute. The question then becomes whether, in addition to administrative enforcement, an implied private right of action would be consistent with the legislative scheme.

It would not. The evolution of Education Law § 905(2) is compelling evidence of the Legislature's intent to immunize the school districts from any liability that might arise out of the scoliosis screening program. By the language of Education Law § 905(2) the Legislature deemed that the school district "shall not suffer any liability to any person as a result of making such examination" (emphasis added). Plaintiffs contend that by implication, the District is denied immunity for failing to perform the examination. In effect, plaintiffs would interpret the statute as conferring immunity for misfeasance but not nonfeasance. On the other hand, the District contends that it would be incongruous for the Legislature to accord immunity for one circumstance but not the other.

Plaintiffs' reading of the statute might have some appeal if we did not have persuasive evidence as to the Legislature's intent to immunize the school districts for both nonfeasance and misfeasance. […] Revealingly, the Legislature evidently saw no need to amend Education Law § 905 in any other way, although obviously aware of the two Appellate Division decisions on that point. Its failure to otherwise amend the statute is strong evidence of the Legislature's conclusion that the Appellate Divisions had correctly interpreted the statute's immunity provision.

There is also the matter of cost to the school districts, as evidenced by the Legislature's expressed sensitivity in that regard. Orthopedists through the New York State Society of Orthopaedic Surgeons and other professionals from the Scoliosis Association, Inc. agreed to volunteer their time and expertise to train existing school personnel on the relatively simple examination procedure. In forecasting its cost, the Legislature anticipated that the program would have minimal financial impact on school districts (Budget Report on Bills, Bill Jacket, L 1978, ch 202). Allowing a private right of action against the government as opposed to a private entity has direct and obvious financial consequences to the public.

Given the Legislature's concern over the possible costs to the school districts –– as evidenced by the statutory immunity provision and the other legislative statements reflecting those concerns –– we conclude that the Legislature did not intend that the districts bear the potential liability for a program that benefits a far wider population. If we are to imply such a right, we must have clear evidence of the Legislature's willingness to expose the governmental entity to liability that it might not otherwise incur. The case before us reveals no such legislative intent.

In sum, we conclude that a private right of action to enforce Education Law § 905(1) is inconsistent with the statute's legislative scheme and therefore cannot be fairly implied.

COMMON LAW NEGLIGENCE

[The Court then held that the plaintiffs did no state a cause of action for common law negligence]

Affirmed.

La Sala Primera del Tribunal Supremo acoge la figura de la negligencia per se, aunque, normalmente, de acuerdo con la doctrina del fin de protección de la norma, un criterio de imputación objetiva. Sin embargo, el Tribunal, incluso en sentencias recientes, se aferra a la noción según la cual el cumplimiento de la normativa no excusa de la negligencia imputada al demandado si hubo daño, pues la producción del daño implica culpa en cuanto señaliza que el demandado no adoptó precauciones suficientes o las necesarias para evitar la producción del daño: las necesarias y exigibles, pero no todas, habría que matizar: las precauciones necesarias para evitar la producción del daño pueden ser infinitas.

1.7. STS, 1ª, 223/2013, de 12 de abril

Muerte accidental de una persona al electrocutarse con un cable de alta tensión situado a 4,80 metros del suelo –una altura inferior a la mínima establecida en el art. 25.1 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión–, mientras limpiaba la piscina de su parcela con un barredor de fondos cuyo mástil produjo un arco voltaico con el cable de alta tensión que pasaba por encima de la parcela.

Padres de la víctima c. Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. y a Comunidad de Parcelistas "El Corzo", demandada como propietaria del tendido eléctrico. JPI: estima en parte la demanda y condena a ambos demandados a pagar 91.030,35 euros, según baremos. AP: estima el recurso de apelación de la comunidad de propietarios, a quien absuelve y desestima el de Endesa y el de los demandantes. TS: desestima el recurso de casación de Endesa y el de los demandantes y confirma la SAP: "Cuando lo que se enjuicia es la responsabilidad por una muerte por electrocución a causa del incumplimiento de la distancia de seguridad entre el tendido eléctrico aéreo y el suelo, lo relevante no es la propiedad del tendido eléctrico sino el control de sus condiciones de seguridad" (FD. 2º).

1.8. STS, 1ª, 909/2005, de 9 de noviembre

El 20.8.1992, la U.T.E, formada por "Obras Subterráneas, S.A." y "Auxini, S.A.", encargó al mecánico Miguel Ángel la sustitución de una pieza del sistema de freno de una retroexcavadora en el exterior de una mina situada en Balsareny (Barcelona). Para ello, el conductor de la retroexcavadora hincó una palanca en el suelo a fin de que la presión ejercida por ésta levantara la rueda trasera y, cuando Miguel Ángel se disponía a colocar debajo un taco de madera, uno de los pistones del mecanismo de la palanca cedió provocando la caída brusca de la parte trasera de la máquina que le aprisionó y le causó la muerte.

Luisa, viuda de Miguel Ángel, en nombre propio y en el de su hijo menor Francisco, demandó a "Obras Subterráneas, S.A." y a "Auxini, S.A." y solicitó una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 5 de Manresa (23.5.1997) desestimó la demanda. La AP de Barcelona (Sección 16ª, 9.12.1998) estimó el recurso de apelación y condenó a las sociedades demandadas a pagar 120.202,42 €.

El TS desestima el recurso de casación: resuelve que el encargado y el capataz de las sociedades demandadas omitieron negligentemente medidas de precaución, pues consintieron que, como ya había ocurrido en otras ocasiones, se acometiera la reparación de forma arriesgada cuando el resultado finalmente producido era previsible. Señala el Tribunal en el Fundamento 2º de la Sentencia:

"No basta para excluir dicha declaración de culpabilidad la inexistencia de infracción reglamentaria sostenida por las recurrentes en base a ciertos informes incorporados a los autos, ya que, dada la naturaleza de la operación que se estaba realizando, es claro que la misma no era objeto de regulación de tal clase. Además, ha de citarse en este sentido la doctrina de esta Sala expresada, entre otras, en sentencias de 22 de abril de 2003 (RJ 2003, 3545) , 18 de junio (RJ 2004, 4431) y 8 de octubre de 2004 (RJ 2004, 6693), según la cual la imputación subjetiva del acto lesivo, con un fundamento de reproche culpabilístico, se basa en que la producción del daño indica que no se han tomado las precauciones o no se ha actuado con el cuidado necesario para impedirlo, revelando que las garantías adoptadas conforme a las disposiciones vigentes para evitar los daños posibles no han ofrecido resultado positivo, poniéndose de manifiesto la insuficiencia de las mismas y que no se hallaba completa la diligencia, y así precisa la última de las sentencias citadas que «no resulta suficiente la que podría denominarse diligencia reglamentaria, si la realidad fáctica evidencia que las medidas adoptadas para evitar los daños previsibles han resultado ineficaces, pues la diligencia que ha de adoptarse en el cumplimiento de las obligaciones comprende no solo las prevenciones y cuidados reglamentarios sino además todos los que la prudencia imponga para evitar los eventos dañosos".

1.9. STS, 1ª, 17/2004, de 3 de febrero

Un joven de 27 años falleció por inhalación de monóxido de carbono desprendido por un calentador de agua a gas que se hallaba en la cocina del piso que compartía con Daniel.

Los padres del fallecido, Leonardo y Rosa, demandan a "Repsol Butano, SA", a Daniel, y a los propietarios del piso, Luis Pedro y Eva, y solicitan una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 3 de León (2.5.1997) estima la demanda en parte: absuelve a Daniel y condena a "Repsol Butano, SA" por deficiencias en la instalación y en el funcionamiento del calentador y a Luis Pedro y Eva por carecer la cocina de rejillas de ventilación al pago de una indemnización de 49.619,56 €, por cuotas del 50 % la primera y 50 % los segundos. La AP de León (Sección 2ª, 27.1.1998) estima el recurso de apelación de "Repsol Butano, SA", revoca la SJPI y condena sólo a Luis Pedro y Eva a abonar a los actores una indemnización de 36.060,73 €.

El TS declara no haber lugar al recurso de casación de los actores. El TS resuelve que la casación no es una tercera instancia en la que pueda modificarse el relato de los hechos probados: "Repsol Butano, SA" sólo era suministradora de las bombonas de butano utilizadas en el calentador y, además, no las entregaba siquiera en el domicilio citado. Señala el Tribunal Supremo:

> "FJ 4º: No se cita [en el motivo de casación sobre posible culpa exclusiva de la víctima] norma ni jurisprudencia alguna como infringida, sin que a tal efecto pueda valer la de un artículo del Decreto de 11 de septiembre de 1992 sobre obligaciones del usuario de una instalación de gas, pues bien sabido es que según reiteradísima jurisprudencia de esta Sala las normas administrativas o reglamentarias carecen de idoneidad para sustentar por sí solas un motivo de casación civil".

1.10. *Preemption*

Como indicábamos al inicio de la Sesión, una de las cuestiones básicas del moderno derecho de daños es si las previsiones del legislador sobre la regulación de tal o cual actividad cierran o no el sistema de remedios al ejercicio de una pretensión civil de reparación o indemnización del daño causado. Así por ejemplo, cabe preguntar:

¿En el caso de que una conducta dañina esté prevista por una legislación específica que establezca las consecuencias de su realización, se aplica además el art. 1902 CC? ¿Si es así, se aplica cumulativamente?, ¿lo hace subsidiariamente?, ¿lo hace solo en la medida en que el daño no haya quedado íntegramente reparado con la aplicación de la ley infringida?

¿Tiene un trabajador accidentado una pretensión civil adicional a aquella o a aquellas que le reconoce el derecho laboral y de la seguridad social?

¿Tiene un cónyuge, excónyuge o persona integrante de una relación de pareja análoga a la matrimonial acciones de daños además de las pretensiones previstas por la legislación matrimonial para el caso de las crisis de pareja?

¿Responde el Estado legislador por la aprobación de una ley cuya aplicación daña al demandante?

Fernando Gómez Pomar, "Responsabilidad extracontractual y otras fuentes de reparación de daños: Collateral Source Rule y afines", InDret 1/1999 (www.indret.com).

- Responsabilidad civil y sistemas de compensación sin culpa

***Bruesewitz v. Wyeth,* 562 U. S. ___ (2011)**

(Slip Opinion) OCTOBER TERM, 2010

Syllabus

BRUESEWITZ ET AL. *v.* WYETH LLC, FKA WYETH, INC., ET AL. CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE THIRD CIRCUIT

No. 09–152. Argued October 12, 2010—Decided February 22, 2011

The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986 (NCVIA or Act) created a no-fault compensation program to stabilize a vaccine market adversely affected by an increase in vaccine-related tort litigation and to facilitate compensation to claimants who found pursuing legitimate vaccine-inflicted injuries too costly and difficult. The Act provides that a party alleging a vaccine-related injury may file a petition for compensation in the Court of Federal Claims, naming the Health and Human Services Secretary as the respondent; that the court must resolve the case by a specified deadline; and that the claimant can then decide whether to accept the court's judgment or reject it and seek tort relief from the vaccine manufacturer. Awards are paid out of a fund created by an excise tax on each vaccine dose. As a *quid pro quo,* manufacturers enjoy significant tort-liability protections. Most importantly, the Act eliminates manufacturer liability for a vaccine's unavoidable, adverse side effects. Hannah Bruesewitz's parents filed a vaccine-injury petition in the Court of Federal Claims, claiming that Hannah became disabled after receiving a diphtheria, tetanus, and pertussis (DTP) vaccine manufactured by Lederle Laboratories (now owned by respondent Wyeth). After that court

denied their claim, they elected to reject the unfavorable judgment and filed suit in Pennsylvania state court, alleging, *inter alia,* that the defective design of Lederle's DTP vaccine caused Hannah's disabilities, and that Lederle was subject to strict liability and liability for negligent design under Pennsylvania common law. Wyeth removed the suit to the Federal District Court. It granted Wyeth summary judgment, holding that the relevant Pennsylvania law was preempted by 42 U. S. C. §300aa–22(b)(1), which provides that "[n]o vaccine manufacturer shall be liable in a civil action for damages arising from a vaccine-related injury or death associated with the administration of a vaccine after October 1, 1988, if the injury or death resulted from side-effects that were unavoidable even though the vaccine was properly prepared and was accompanied by proper directions and warnings." The Third Circuit affirmed.

Held: The NCVIA preempts all design-defect claims against vaccine manufacturers brought by plaintiffs seeking compensation for injury or death caused by a vaccine's side effects. Pp. 7–19.

(a) Section 300aa–22(b)(1)'s text suggests that a vaccine's design is not open to question in a tort action. If a manufacturer could be held liable for failure to use a different design, the "even though" clause would do no work. A vaccine side effect could alway*s* have been avoidable by use of a different vaccine not containing the harmful element. The language of the provision thus suggests the design is not subject to question in a tort action. What the statute establishes as a complete defense must be unavoidability (given safe manufacture and warning) with respect to the particular design. This conclusion is supported by the fact that, although products-liability law establishes three grounds for liability—defective manufacture, inadequate directions or warnings, and defective design—the Act mentions only manufacture and warnings. It thus seems that the Act's failure to mention design-defect liability is "by deliberate choice, not inadvertence." *Barnhart* v. *Peabody Coal Co.*, 537 U. S. 149, 168. Pp. 7–8.

(b) Contrary to petitioners' argument, there is no reason to believe that §300aa–22(b)(1)'s term "unavoidable" is a term of art incorporating Restatement (Second) of Torts §402A, Comment *k*, which exempts from strict liability rules "unavoidably unsafe products." "Unavoidable" is hardly a rarely used word, and cases interpreting comment *k* attach special significance only to the term "unavoidably unsafe products," not the word "unavoidable" standing alone. Moreover, reading the phrase "side effects that were unavoidable" to exempt injuries caused by flawed design would require treating "even though" as a coordinating conjunction linking independent ideas when it is a concessive, subordinating conjunction conveying that one clause weakens or qualifies the other. The canon against superfluity does not undermine this Court's interpretation because petitioners' competing interpretation has superfluity problems of its own. Pp. 8–12.

(c) The structure of the NCVIA and of vaccine regulation in general reinforces what §300aa–22(b)(1)'s text suggests. Design defects do not merit a single mention in the Act or in Food and Drug Administration regulations that pervasively regulate the drug manufacturing process. This lack of guidance for design defects, combined with

- Responsabilidad civil y sistema de regulación de la seguridad de producto

Pliva, Inc., et. al. v. Mensing, 564 U. S. ___ (2011)

(Slip Opinion) OCTOBER TERM, 2010

Syllabus

PLIVA, INC., ET AL. *v.* MENSING

CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE EIGHT CIRCUIT

No. 09–993. Argued March 30, 2011—Decided June 23, 2011[2]

Five years after the Food and Drug Administration (FDA) first approved metoclopramide, a drug commonly used to treat digestive tract problems, under the brand name Reglan, generic manufacturers such as petitioners also began producing the drug. Because of accumulating evidence that long-term metoclopramide use can cause tardive dyskinesia, a severe neurological disorder (a movement disorder which consists in adverse effects including diminished voluntary movements and the presence of involuntary movments similar to tic or chorea, tremor discoordination ---Wikipedia: definition to be improved), warning labels for the drug have been strengthened and clarified several times, most recently in 2009.

Respondents were prescribed Reglan in 2001 and 2002, but both received the generic drug from their pharmacists. After taking the drug as prescribed for several years, both developed tardive dyskinesia. In separate state-court tort actions, they sued petitioners, the generic drug manufacturers that produced the metoclopramide they took (Manufacturers). Each respondent alleged, *inter alia,* that longterm metoclopramide use caused her disorder and that the Manufacturers were liable under state tort law for failing to provide adequate warning labels. In both suits, the Manufacturers urged that federal statutes and FDA regulations pre-empted the state tort claims by requiring the same safety and efficacy labeling for generic metoclopramide as was mandated at the time for Reglan. The Fifth and EighthCircuits rejected these arguments, holding that respondents' claims were not pre-empted.

Held: The judgment is reversed, and the cases are remanded.

588 F. 3d 603 and 593 F. 3d 428, reversed and remanded.

JUSTICE THOMAS delivered the opinion of the Court with respect to all but Part III–B–2, concluding that federal drug regulations applicable to generic drug manufacturers directly conflict with, and thus pre-empt, these state claims. Pp. 4–14, 17–20.

(a) Because pre-emption analysis requires a comparison between federal and state law, the Court begins by identifying the state tort duties and federal labeling requirements applicable to the Manufacturers. Pp. 4–10.

(1) State tort law requires a manufacturer that is, or should be, aware of its drug's danger to label it in a way that renders it reasonably safe. Respondents pleaded that the Manufacturers knew, or should have known, both that the long-term use of their products carried a high risk of tardive dyskinesia and that their labels did not adequately warn of that risk. Taking these allegations as true, the state-law duty required the Manufacturers to use a different, stronger label than the one they actually used. Pp. 4–5.

[2] Together with No. 09-1039, *Actavis Elisabeth, LLC v. Mensing*, also on certiorari to the same court, and No. 09-1501, Actavis, Inc. v. Demahy, on certiorari to the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit.

(2) On the other hand, federal drug regulations, as interpreted by the FDA, prevented the Manufacturers from independently changing their generic drugs' safety labels. A manufacturer seeking federal approval to market a new drug must prove that it is safe and effective and that the proposed label is accurate and adequate. Although the same rules originally applied to all drugs, **the 1984 law commonly called the Hatch-Waxman Amendments allows a generic drug manufacturer to gain FDA approval simply by showing that its drug is equivalent to an already-approved brand-name drug, and that the safety and efficacy labeling proposed for its drug is the same as that approved for the brand-name drug**. Respondents contend that federal law nevertheless provides avenues through which the Manufacturers could have altered their metoclopramide labels in time to prevent the injuries here. These include: (1) the FDA's "changes-being- effected" (CBE) process, which permits drug manufacturers, without preapproval, to add or strengthen a warning label; and (2) sending "Dear Doctor" letters providing additional warnings to prescribing physicians and other healthcare professionals. However, the FDA denies that the Manufacturers could have used either of these processes to unilaterally strengthen their warning labels. The Court defers to the FDA's views because they are not plainly erroneous or inconsistent with the regulations, and there is no other reason to doubt that they reflect the FDA's fair and considered judgment. Auer v. Robbins, 519 U. S. 452, 461, 462. Assuming, without deciding, that the FDA is correct that federal law nevertheless required the Manufacturers to ask for the agency's assistance in convincing the brand- name manufacturer to adopt a stronger label, the Court turns to the pre-emption question. Pp. 5–10.

(b) Where state and federal law directly conflict, state law must give way. See, e.g., Wyeth v. Levine, 555 U. S. 555, 583. Such a conflict exists where it is "impossible for a private party to comply with both state and federal requirements." Freightliner Corp. v. Myrick, 514 U. S. 280, 287. Pp. 11–14, 17–20.

(1) The Court finds impossibility here. If the Manufacturers had independently changed their labels to satisfy their state-law duty to attach a safer label to their generic metoclopramide, they would have violated the federal requirement that generic drug labels be the same as the corresponding brand-name drug labels. Thus, it was impossible for them to comply with both state and federal law. And even if they had fulfilled their federal duty to ask for FDA help in strengthening the corresponding brand-name label, assuming such a duty exists, they would not have satisfied their state tort-law duty. State law demanded a safer label; it did not require communication with the FDA about the possibility of a safer label. Pp. 11–12.

(2) The Court rejects the argument that the Manufacturers' pre-emption defense fails because they failed to ask the FDA for help in changing the corresponding brand-name label. The proper question for "impossibility" analysis is whether the private party could independently do under federal law what state law requires of it. See Wyeth, supra, at 573. Accepting respondents' argument would render conflict pre-emption largely meaningless by making most conflicts between state and federal law illusory. In these cases, it is possible that, had the Manufacturers asked the FDA for help, they might have eventually been able to strengthen their warning label. But it is also possible that they could have convinced the FDA to reinterpret its regulations in a manner that would have opened the CBE process to them, persuaded the FDA to rewrite its generic drug regulations entirely, or talked Congress into amending the Hatch-Waxman Amendments. If these conjectures sufficed to prevent federal and state law from conflicting, it is unclear when, outside of express pre- emption, the **Supremacy Clause** would have any force. That Clause— which makes federal law "the supreme Law of the Land . . . any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding," U. S. Const., Art. VI, cl. 2—

cannot be read to permit an approach to pre-emption that renders conflict pre-emption all but meaningless. Here, it is enough to hold that when a party cannot satisfy its state duties without the Federal Government's special permission and assistance, which is dependent on the exercise of judgment by a federal agency, that party cannot independently satisfy those state duties for pre-emption purposes. Pp. 12–14, 17.

(3) Wyeth is not to the contrary. The Court there held that a state tort action against a brand-name drug manufacturer for failure to provide an adequate warning label was not pre-empted because it was possible for the manufacturer to comply with both state and federal law under the FDA's CBE regulation. 555 U. S., at 572–573. The federal statutes and regulations that apply to brand-name drug manufacturers differ, by Congress' design, from those applicable to generic drug manufacturers. And different federal statutes and regulations may, as here, lead to different pre-emption results. This Court will not distort the Supremacy Clause in order to create similar pre-emption across a dissimilar statutory scheme. Congress and the FDA retain authority to change the law and regulations if they so desire. Pp. 17–20.

THOMAS, J., delivered the opinion of the Court, except as to Part III– B–2. ROBERTS, C. J., and SCALIA and ALITO, JJ., joined that opinion in full, and KENNEDY, J., joined as to all but Part III–B–2. SOTOMAYOR, J., filed a dissenting opinion, in which GINSBURG, BREYER, and KAGAN, JJ., joined.

- Textos relacionados con las cuestiones planteadas:

a) Artículo 123 LGSS. Recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

b) Competencia de jurisdicción:

b.1) STS, 1ª, 1217/2008, de 15 de diciembre

La Sala de lo Social es la única competente para conocer de las demandas de responsabilidad civil por accidente de trabajo entre empleado y empleador.

El 27.11.1997, Juan Alberto, quien prestaba servicios para "Colafe Construcciones Extremeñas, S.A.", sufrió un accidente cuando trabajaba en la colocación de un ascensor en una obra, causado por un fallo en la sujeción del chasis en el puntal de aquél. El trabajador no llevaba el cinturón de seguridad. Como consecuencia del accidente, Juan Antonio quedó impedido para la realización de las tareas habituales de su profesión.

Juan Antonio demandó la constructora y solicitó una indemnización de 180.303,63 €. El JPI núm. 6 de Badajoz (3.3.2000) desestima la demanda. La AP de Badajoz (Sección 2ª, 24.11.2000) desestima el recurso de apelación y confirma la SJPI.

El TS se abstuvo de conocer el recurso de casación y declaró la nulidad de todas las actuaciones. Apreció falta de competencia de la jurisdicción civil para conocer la reclamación de responsabilidad planteada, pues es consecuencia del incumplimiento del contrato de trabajo por parte del empresario (FD 3º).

En el mismo sentido: STS, 1ª, 1395/2008, de 15 de enero; STS, 1ª, 267/2008, de 16 de abril; STS, 1ª, 367/2008, de 19 de mayo; STS, 1ª, 513/2008, de 4 de junio; STS, 1ª, 1060/2008, de 17 de noviembre; STS, 1ª, 1061/2008, de 17 de noviembre. *Cfr.* con STS, 1ª, 1118/2008, de 19 de noviembre.

b.2) STS, 1ª, 587/2009, 11 de septiembre

Competencia del orden civil para conocer de demandas por accidentes de trabajo interpuestas con anterioridad a la STS, 1ª, Pleno, 15.1.2008.

El 15.12.1993, a las 16:30 horas, Millán, de 27 años de edad, realizaba tareas de selección de pescado en una embarcación propiedad de Constanza. Iba vestido con impermeable y botas de goma de suela antideslizante, y cargaba unas cajas vacías cuando, a causa de un golpe de mar, perdió el equilibrio y cayó al agua por un hueco que, de haber tendido dimensiones inferiores, hubiera impedido la caída, y falleció ahogado.

La mujer e hijos de la víctima demandaron a Constanza, propietaria del barco, y solicitaron una indemnización de 480.809,68 €.

El JPI núm. 48 de Barcelona (15.6.1999) estimó en parte la demanda y condenó a la demandada al pago de 48.080,97 euros con base en los arts. 1902 y 1903 CC. Ambas partes recurrieron en apelación. La AP de Barcelona (Sección 1ª, 15.4.2000) desestimó el de la demandada y estimó en parte el de la actora en el sentido de aumentar la indemnización a 209.278,72 euros.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por la demandada:

"[L]os usos y costumbres de la mar aceptan determinados riesgos. Ahora bien, estos riesgos están pensados más en la efectividad de la pesca que en la seguridad del trabajador … El golpe de mar es un hecho previsible y previsible era también que un marinero pudiera caer, como cayó, por efecto de este golpe de mar y de la inclinación del barco por un hueco que, de haber tenido unas dimensiones inferiores, nunca se hubiera producido" (FD. 3º).

El Tribunal resolvió, en contra de los precedentes judiciales, a favor de la competencia del orden civil:

"Sin duda la jurisdicción es un presupuesto procesal absoluto para el válido desarrollo de la relación jurídico procesal y como tal de obligada observancia por su naturaleza de orden público … Sin embargo, la aceptación de las anteriores conclusiones, no es suficiente para considerar que la competencia jurisdiccional sobre la pretensión ejercitada en este proceso corresponde al orden social y negar la legitimidad del orden jurisdiccional civil para conocer de un asunto que se inicia con la cobertura que le proporcionaba una reiterada jurisprudencia al respecto. Lo contrario contradice la misma esencia del derecho a la tutela judicial efectiva, pues contrario a esta tutela es que a partir de una interpretación posterior de la normativa, y después de que han pasado más de diez años desde que se interpuso la demanda, se inadmita a trámite en la jurisdicción en la que había sido planteada, pasando absolutamente por alto que este mismo Tribunal, en ocasiones y, precisamente tras ponderar las circunstancias del caso, acuñó la doctrina del peregrinaje enraizando principios procesales con los constitucionalmente protegidos -la tutela judicial efectiva sin indefensión, y la evitación de dilaciones indebidas-".

Con posterioridad, el TS ha mantenido este nuevo criterio en la STS, 1ª, 9.3.2010 (JUR 2010 131735; MP: Juan Antonio Xiol Ríos).

b.3) Art. 2 b) Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

"**Artículo 2.** Ámbito del orden jurisdiccional social.
Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
(…)
b. En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.

c) STS, 3ª, de 3 de noviembre de 2008

A las 11:30 h. del 29.11.1996, Patricia, celadora en el centro de especialidades del complejo hospitalario "Xeral Calde" (Lugo), dependiente del Servicio Gallego de Salud ("SERGAS"), bajaba en el ascensor de dicho complejo cuando, debido a un fallo mecánico, el ascensor cayo desde la 3ª planta, chocando con el amortiguador situado en el foso del sótano del edificio. Como consecuencia del accidente, Patricia sufrió traumatismos múltiples y precisó de atención psiquiátrica hasta 1998. La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo (29.1.1999) declaró que las secuelas derivadas del accidente de trabajo por Patricia eran constitutivas de invalidez permanente absoluta en grado de gran invalidez y reconoció el derecho de ésta a percibir una pensión mensual de 1.404,84 € con un recargo del 50% por falta de medidas de seguridad.

Patricia demandó al "SERGAS" y a la Xunta de Galicia y solicitó una indemnización de 1.031.171,25 €, que la Consellería denegó por silencio administrativo. El TSJ Galicia (Sección 1ª, 3.3.2004) estimó el recurso contencioso administrativo y condenó a las administraciones codemandadas al pago de 300.500 €

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por el "SERGAS" y la Xunta de Galicia. El TS, tras desestimar los argumentos por los cuales la demandante debería haber llamado al proceso a la empresa fabricante del ascensor y la encargada de su mantenimiento, analizó el motivo central del recurso, a saber, si la existencia de una relación de empleo público entre víctima y Administración anulaba la responsabilidad patrimonial de esta última. El TS resolvió que, por más que el daño se habuiera producido en el desarrollo de una relación de servicio público, el accidente quedaba fuera de los riesgos inherentes al ejercicio de su profesión, de manera que la lesión era antijurídica, máxime cuando la empleada no tuvo la más mínima intervención en el accidente (F. D. 5º).

2. *Res ipsa loquitur*

Los tribunales españoles han recibido la doctrina de denominada *"Res ipsa loquitur"* –"las cosas hablan por sí mismas"–, en virtud de la cual si el accidente ha tenido lugar en circunstancias tales que, normalmente y a ojos de un observador razonable, tales accidentes suelen ocurrir por negligencia del demandado, entonces la existencia de esta última se presume salvo prueba en contrario. Se trata así de conductas que normalmente son dañinas solo porque son negligentes, pues en ausencia de culpa el daño no tiene lugar. La doctrina encuentra su mayor dificultad en aquellos casos, que son legión, en los cuales a la presumible negligencia del demandado se suma la presunta negligencia del demandante. Los casos que se citan a continuación dan razón del alcance de esta doctrina y de sus límites.

2.1. *Byrne v. Boadle* (159 Eng. Rep. 299 (Ex. 1863))

[Plaintiff's complaint stated that he was passing along the highway in front of defendant's premises when he was struck and badly hurt by a barrel of flour that was apparently being lowered from a window above, which was on the premises of the defendant, a dealer in flour. Several witnesses testified that they saw the barrel fall and hit plaintiff. The defendant claimed "that there was no evidence of negligence for the jury". The trial court, agreeing, nonsuited plaintiff after the jury had assessed the damages at £50. On appeal in the Court of Exchequer, the plaintiff argued that the evidence was sufficient to support a verdict in his favor. In response, the defendant's lawyer argued that it was consistent with the evidence that the purchaser of the flour or some complete stranger was supervising the lowering of the barrel of flour and that its fall was not attributable in any way to defendant or his servants. POLLOCK, C.B.: "The presumption is that the defendant's servants were engaged in removing the defendant's flour. If they were not it was competent to the defendant to prove it". Defendant's attorney replied that "Surmise ought not to be substituted for strict proof when it is thought to fix a defendant with serious liability. The plaintiff should establish his case by affirmative defense [...] The plaintiff was bound to give affirmative proof of negligence. But there was not a scintilla of evidence, unless the occurrence is of itself evidence of negligence". POLLOCK, C.B.: "There are certain cases of which it may be said res ipsa loquitur and this seems one of them. In some cases the Court had held that the mere fact of the accident having occurred is evidence of negligence, as, for instance, in the case of railway collisions"].

POLLOCK, C.B. We are all of opinion that the rule must be absolute to enter the verdict for the plaintiff. The learned counsel was quite right in saying that there are many accidents from which no presumption of negligence can arise, but I think it would be wrong to lay down as a rule that in no case can presumption of negligence arise from the fact of an accident. Suppose in this case the barrel had rolled out of the warehouse and fallen on the plaintiff, how could he possibly ascertain from what cause it occurred? It is the duty of persons who keep barrels in a warehouse to take care that they do not roll out, and I think that such a case would, beyond all doubt, afford prima facie evidence of negligence. A barrel could not roll out of a warehouse without some negligence, and to say that a plaintiff who is injured by it must call witnesses from the warehouse to prove negligence seems to me preposterous. So in the building or repairing a house, or putting pots on the chimneys, if a person passing along the road is injured by something falling upon him, I think the accident alone would be prima facie evidence of negligence. Or if an article calculated to cause damage is put in a wrong place and does mischief, I think that those whose duty it was to put it in the right place are prima facie responsible, and if there is any state of facts to rebut the presumption of negligence, they must prove them. The present case upon the evidence comes to this, a man is passing in front of the premises of a dealer in flour, and there falls down upon him a barrel of flour. I think it apparent that the barrel was in the custody of the defendant who occupied the premises, and who is responsible for the acts of his servants who had the control of it; and in my opinion the fact of its falling is prima facie evidence of negligence, and the plaintiff who was injured by it is not bound to shew that it could not fall without negligence, but if there are any facts inconsistent with negligence it is for the defendant to prove them. [Judgment affirmed].

2.2. *Colmenares Vivas v. Sun Alliance Insurance Co.* (807 F.2d 1102 (1st Cir. 1986))

BOWNES, Circuit Judge.

Appellants are plaintiffs in a diversity action to recover damages for injuries they suffered in an accident while riding an escalator. After the parties had presented their evidence, the defendants moved for and were granted a directed verdict. The court held that there was no evidence of negligence and that the doctrine of res ipsa loquitur, which would raise a presumption of negligence, did not apply. We reverse the directed verdict and remand the case to the district court because we hold that res ipsa loquitur does apply.

I. BACKGROUND

The relevant facts are not in dispute. On February 12, 1984, Jose Domingo Colmenares Vivas and his wife, Dilia Arreaza de Colmenares, arrived at the Luis Muñoz Marin International Airport in Puerto Rico. They took an escalator on their way to the Immigration and Customs checkpoint on the second level. Mrs. Colmenares was riding the escalator on the right-hand side, holding the moving handrail, one step ahead of her husband. When the couple was about halfway up the escalator, the handrail stopped moving, but the steps continued the ascent, causing Mrs. Colmenares to lose her balance. Her husband grabbed her from behind with both hands and prevented her from falling, but in doing so, he lost his balance and tumbled down the stairs. Mr. and Mrs. Colmenares filed a direct action against the Sun Alliance Insurance Company, who is the liability insurance carrier for the airport's owner and operator, the Puerto Rico Ports Authority. Sun Alliance brought a third-party contractual action against Westinghouse Electric Corporation based on a maintenance contract that required Westinghouse to inspect, maintain, adjust, repair, and replace parts as needed for the escalator and handrails, and to keep the escalator in a safe operating condition. […]

The trial was conducted on January 30 and 31, 1986. Appellants called four witnesses. The Ports Authority's contract and maintenance supervisor testified about his daily weekday inspections of the escalator, about the maintenance contract with Westinghouse, about inspection and maintenance procedures, and about the accident report and subsequent repair and maintenance of the escalator. The Ports Authority's assistant chief of operations testified about the accident report. Appellants' testimony concerned the accident and their injuries.

[…] After hearing the parties' arguments, the court ruled that there was no evidence that the Ports Authority had been negligent, and that the case could not go to the jury based on res ipsa loquitur because at least one of the requirements for its application -- that the injury-causing instrumentality was within the exclusive control of the defendant -- was not met […].

II. RES IPSA LOQUITUR

Under Puerto Rico law, three requirements must be met for res ipsa loquitur, ("the thing speaks for itself"), to apply: "(1) the accident must be of a kind which ordinarily does not occur in the absence of someone's negligence; (2) it must be caused by an agency or instrumentality within the exclusive control of defendant; [and] (3) it must not be due to any voluntary action on the part of plaintiff." Community Partnership v. Presbyterian Hospital.. . If all three requirements are met, the jury may infer that the defendant was negligent even though there is no direct evidence to that effect. […]

A. The First Requirement: Inference of Negligence

The first requirement that must be met for res ipsa loquitur to apply is that "the accident must be such that in the light of ordinary experience it gives rise to an inference that someone has been negligent". It is not clear to us whether the district court decided that this requirement was met, although the court did suggest that it was giving the benefit of the doubt on this question to the appellants. We hold that this requirement was met because an escalator handrail probably would not stop suddenly while the escalator continues moving unless someone had been negligent.

This requirement would not be met if appellants had shown nothing more than that they had been injured on the escalator, because based on this fact alone it would not be likely that someone other than the appellants had been negligent. […]. Here, it was not disputed that the handrail malfunctioned and stopped suddenly, an event that foreseeably could cause riders to lose their balance and get injured. Thus, the evidence gave rise to an inference that someone probably had been negligent in operating or maintaining the escalator, and the first requirement for the application of res ipsa loquitur was met.

B. The Second Requirement: Exclusive Control

The second requirement for res ipsa loquitur to apply is that the injury-causing instrumentality -- in this case, the escalator -- must have been within the exclusive control of the defendant. The district court found that this requisite was not met, despite the parties' stipulation that "the escalator in question is property of and is under the control of the Puerto Rico Ports Authority." We agree that this stipulation was not by itself enough to satisfy the res ipsa loquitur requirement. It did not exclude the possibility that someone else also had control over the escalator; indeed, the stipulation said that Westinghouse maintained the escalator. We hold, however, that the Ports Authority effectively had exclusive control over the escalator because the authority in control of a public area has a nondelegable duty to maintain its facilities in a safe condition.

Few courts have required that control literally be "exclusive." [...]. The exclusive control requirement, then, should not be so narrowly construed as to take from the jury the ability to infer that a defendant was negligent when the defendant was responsible for the injury-causing instrumentality, even if someone else might also have been responsible. The purpose of the requirement is not to restrict the application of the res ipsa loquitur inference to cases in which there is only one actor who dealt with the instrumentality, but rather "to eliminate the possibility that the accident was caused by a third party." [...] It is not necessary, therefore, for the defendant to have had actual physical control; it is enough that the defendant, and not a third party, was ultimately responsible for the instrumentality. Thus, res ipsa loquitur applies even if the defendant shares responsibility with another, or if the defendant is responsible for the instrumentality even though someone else had physical control over it. [...] It follows that a defendant charged with a nondelegable duty of care to maintain an instrumentality in a safe condition effectively has exclusive control over it for the purposes of applying res ipsa loquitur. [...] Unless the duty is delegable, the res ipsa loquitur inference is not defeated if the defendant had shifted physical control to an agent or contracted with another to carry out its responsibilities.

We hold that the Ports Authority could not delegate its duty to maintain safe escalators. There are no set criteria for determining whether a duty is nondelegable; the critical question is whether the responsibility is so important to the community that it should not be transferred to another. [...]. The Ports Authority was charged with such a responsibility. It was created for a public purpose, which included the operation and management of the airport. ... A concomitant of this authority is the duty to keep the facilities it operates in a reasonably safe condition. The public is entitled to rely on the Ports Authority -- not its agents or contractors -- to see that this is done. The Ports Authority apparently recognized this responsibility, for its maintenance and contract supervisor conducted daily weekday inspections of the escalators despite the maintenance contract with Westinghouse.

Duties have been seen as nondelegable in several analogous situations. For example, a public authority may not delegate to an independent contractor its responsibility to see that work in a public place is done carefully. [...] Also, a government may not delegate its responsibility to maintain safe roads and similar public places. [...] Finally, an owner has a nondelegable duty to keep business premises safe for invitees. [...] These examples demonstrate a general tort law policy not to allow an entity to shift by contract its responsibility for keeping an area used by the public in a safe condition. It would be contrary to this policy to allow the owner and operator of an airport terminal to delegate its duty to keep its facility safe. We hold, therefore, that the district court erred in ruling that the exclusive control requirement was not met.

C. The Third Requirement: The Plaintiffs' Actions

The third requirement that must be met for res ipsa loquitur to apply is that the accident must not have been due to the plaintiff's voluntary actions. The district court found, and we agree, that there was no evidence that Mr. and Mrs. Colmenares caused the accident. Indeed, there is no indication that they did anything other than attempt to ride the escalator in the ordinary manner. Therefore, we hold that all three requirements were met and that the jury should have

been allowed to consider whether the Ports Authority was liable based on the permissible inference of negligence raised by the application of res ipsa loquitur. [...]

TORRUELLA, Circuit Judge dissenting. I must regretfully dissent. […] In my view, solely because the handrail stopped and Mrs. Colmenares fell, without further evidence as to why or how the handrail malfunctioned, does not give rise to an inference of negligence by the Ports Authority. […]

The malfunctioning of an escalator presents an even stronger argument against the raising of an inference of negligence without additional proof as to the cause of the malfunction. Although a court can take notice that an escalator is a complicated piece of machinery, it has no basis of common knowledge for inferring that its malfunction is the result of the operator's negligence.

2.3. *Ybarra v. Spangard* (25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687)

GIBSON, C. J. This is an action for damages for personal injuries alleged to have been inflicted on plaintiff by defendants during the course of a surgical operation. The trial court entered judgments of nonsuit as to all defendants and plaintiff appealed.

On October 28, 1939, plaintiff consulted defendant Dr. Tilley, who diagnosed his ailment as appendicitis, and made arrangements for an appendectomy to be performed by defendant Dr. Spangard at a hospital owned and managed by defendant Dr. Swift. Plaintiff entered the hospital, was given a hypodermic injection, slept, and later was awakened by Drs. Tilley and Spangard and wheeled into the operating room by a nurse whom he believed to be defendant Gisler, an employee of Dr. Swift. Defendant Dr. Reser, the anesthetist, also an employee of Dr. Swift, adjusted plaintiff for the operation, pulling his body to the head of the operating table and, according to plaintiff's testimony, laying him back against two hard objects at the top of his shoulders, about an inch below his neck. Dr. Reser then administered the anesthetic and plaintiff lost consciousness. When he awoke early the following morning he was his hospital room attended by defendant Thompson, the special nurse, and another nurse who was not made a defendant.

Plaintiff testified that prior to the operation he had never had any pain in, or injury to, his right arm or shoulder, but that when he awakened he felt a sharp pain about half way between the neck and the point of the right shoulder. He complained to the nurse, and then to Dr. Tilley, who gave him diathermy treatments while he remained in the hospital. The pain did not cease but spread down to the lower part of his arm, and after his release from the hospital the condition grew worse. He was unable to rotate or lift his arm, and developed paralysis and atrophy of the muscles around the shoulder. He received further treatments from Dr. Tilley until March, 1940, and then returned to work, wearing his arm in a splint on the advice of Dr. Spangard. […]

We have no doubt that in a modern hospital a patient is quite likely to come under the care of a number of persons in different types of contractual and other relationships with each other. For example, in the present case it appears that Drs. Smith, Spangard and Tilley were physicians or surgeons commonly placed in the legal category of independent contractors; and Dr. Reser, the anesthetist, and defendant Thompson, the special nurse, were employees of Dr. Swift and not of the other doctors. But we do not believe that either the number or relationship of the defendants alone determines whether the doctrine of res ipsa loquitur applies. Every defendant in whose custody the plaintiff was placed for any period was bound to exercise ordinary care to see that no unnecessary harm came to him and each would be liable for failure in this regard. Any defendant who negligently injured him, and any defendant charged with his care who so neglected him as to allow injury to occur, would be liable. The defendant employers would be liable for the neglect of their employees; and the doctor in charge of the operation would be liable for the negligence of those who became his temporary servants for the purpose of assisting in the operation. […]

The judgment is reversed.

2.4. STS, 1ª, 1146/1998, de 9 de diciembre

La esposa del actor, de 78 años de edad, fue intervenida satisfactoriamente de halux valgus bilateral, esto es, juanetes. A los pocos días de la intervención, sin embargo, la paciente presentó un cuadro de contractura muscular progresiva a nivel cervical, con dificultad de deglución, por lo que, ante la sospecha de que se tratara de tétanos postquirúrgico se inició el oportuno tratamiento y la enferma fue trasladada a otro hospital donde, confirmado el diagnóstico fue ingresada en la UCI. La paciente falleció a los quince días por tétanos grave postquirúrgico. El actor demandó a la congregación religiosa titular del hospital, al cirujano, al médico que le asistió en la operación y a la Mutua General de Seguros en reclamación de una indemnización 120.202,42 €. El Juzgado desestimó la demanda, mas la Audiencia revocó la sentencia y condenó a la congregación religiosa y a la compañía aseguradora a pagar 90.151,82 € más las costas causadas en primera instancia. El Tribunal Supremo revocó la Sentencia de la Audiencia únicamente en lo referente a la condena en costas, en el sentido de no imponer las de primera instancia a ninguna de las partes. La Sentencia imputóa el resultado dañoso al mal cumplimiento por la entidad titular del centro hospitalario, de la prestación de tener el espacio, el instrumental y el material a utilizar en el estado que sea preciso para evitar infecciones. Y ello porque, aunque se afirma que la obligación médica es de medios, no de resultado, ello no obsta a la presunción desfavorable que nace del daño, cuando éste es desproporcionado en relación con lo que es usual.

Por primera vez el Tribunal Supremo identifico la doctrina del daño desproporcionado con las medidas de facilitación de la prueba existentes en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno:

«[C]onviene recordar la doctrina sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor (así, la Sentencia de 13 diciembre 1997 [A.8816]), que corresponde a la regla «res ipsa loquitur» (la cosa habla por sí misma) que se refiere a una evidencia que crea una deducción de negligencia y ha sido tratada profusamente por la doctrina angloamericana y a la regla del *Anscheinsbeweis* (apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la doctrina francesa de la *faute virtuelle* (culpa virtual); lo que requiere que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que entre en la esfera de la acción del demandado aunque no se conozca el detalle exacto y que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que corresponda a la esfera de la propia víctima» (FD. 2º).

2.5. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla

El 7.1.1991 Marisol sufrió un accidente de esquí en Baqueira Beret que le causó una fractura de espina tibial, de la que fue auxiliada *in situ* y trasladada a Barcelona, donde fue atendida por el doctor Carlos Antonio, que tenía contratado un seguro con Winterthur y pertenecía a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA". El tratamiento se prolongó hasta mayo de 1992, en cuyo transcurso la paciente se sometió a tres intervenciones. Finalmente, Marisol acudió a otro doctor para que acabase el tratamiento, pero le quedaron secuelas graves que consisten en limitación de la movilidad de la rodilla derecha, atrofia muscular y una cojera irreversible.

Marisol demanda al doctor Carlos Antonio, a Winterthur y a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA" y solicita una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 25 de Barcelona (7.4.1995) estima en parte la demanda y condena a Carlos Antonio y a Winterthur al pago de 72.121,45 €. La AP de Barcelona (Sección 11ª, 8.5.1997) estima el recurso de apelación, revoca la SJPI y absuelve a los condenados en la instancia previa.

El TS estima el recurso interpuesto por la actora, revoca la SAP y confirma la SJPI. Considera que el largo periodo de tratamiento, con tres intervenciones de por medio y con el resultado de graves secuelas, es suficiente para deducir la negligencia médica de acuerdo con la regla *res ipsa loquitur*. Así:

"[U]na caída y una lesión que tampoco se dice que fueran especialmente graves, ni complicados, tienen un tratamiento largo y doloroso con un resultado que no puede por menos que considerarse desproporcionado: una cojera irreversible; lo cual crea una deducción de negligencia («res ipsa loquitur»), una apariencia de prueba de ésta ("Anscheisbeweis"), una culpa virtual ("faute virtuelle").No se trata, pues, de una objetivación absoluta de responsabilidad sino de apreciación de culpa, deducida del resultado desproporcionado y no contradichos por hechos considerados acreditados por prueba pericial. Se produce un suceso y un daño: es claro que no consta causa del mismo imputable a la víctima (…), ni se menciona el caso fortuito o la fuerza mayor; la causa fue la actuación médica, de cuyo mal resultado se desprende la culpa y, por ende, la responsabilidad" (FD 3º).

2.6. Otras sentencias sobre responsabilidad médica por daños desproporcionados

STS, 1ª, 417/2007, de 16 de abril

El 9.2.1994, el Dr. Jorge intervino quirúrgicamente a Maite de una hernia discal y le implantó un injerto óseo y una placa de titanio que le produjeron una infección bacteriana. En el postoperatorio, la paciente fue visitada en tres ocasiones por dolores, pero la infección no fue detectada por falta de empleo del medio diagnóstico adecuado. El 3.9.1994, Maite ingresó en el "Hospital Virgen de las Nieves" de Granada, donde fue intervenida en tres ocasiones porque se le encontró un absceso de pus en la zona en la que había sido intervenida. Maite sufrió secuelas consistentes en una tetraparesia con incapacidad del 76%, perjuicio estético derivado de traqueotomía y depresión grave.

Maite demandó a Jorge y a "Neurosan, S.L." *(no consta relación con el caso)*, y solicitó una indemnización de 901.518,6 €.

La SJPI nº 25 de Barcelona, 16.2.1999, estimó en parte la demanda, condenó a Jorge a pagar 540.910,89 € y absolvió al otro demandado. La SAP de Barcelona, Secc. º7ª, 31.1.2000, desestimó el recurso de apelación interpuesto por Jorge y confirmó la SJPI.

El TS desestimó el recurso de casación, pues:

"[A]nte el daño desproporcionado (…) se espera del agente una explicación o una justificación cuya ausencia u omisión puede determinar la imputación por culpa que ya entonces se presume" y en este caso, "no se ha producido por parte del demandado una explicación que excluya la apreciación de negligencia por falta de atención durante el postoperatorio" (FD 2º).

— SSTS, 1ª, 813/1997, de 26 de septiembre; 593/1999, de 29 de junio; 1038/1999, de 9 de diciembre.
— Bibliografía específica: Álvaro LUNA YERGA, *La prueba de la responsabilidad civil médico-sanitaria. Culpa y Causalidad*, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp. 186 y ss.

Capítulo 13º
El proceso civil de reclamación de responsabilidades civiles

1. El proceso civil de reclamación de daños y perjuicios **97**
2. El proceso ordinario **98**
2.1. Fase alegatoria: demanda y contestación. Reconvención. 98
2.2. Fase intermedia: audiencia Previa 101
2.3. Fases probatoria y final: juicio 102
2.4. Sentencia: aclaración, corrección y complemento 104
3. Recursos **105**
4. Ejecución provisional y definitiva. Medidas cautelares. **106**
5. Juicio verbal **107**

"Para obtener Justicia no basta tener razón,
es necesario saberla exponer y demostrarla,
encontrar quien la entienda y la quiera dar,
y por último -que es lo más importante-,
encontrar un deudor que pueda pagar."

Piero CALAMANDREI

Estudios sobre el proceso civil, Tomo III,
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1962, p. 261.

El derecho de daños no se entiende sin las reglas que regulan el proceso en que se exigirán las eventuales responsabilidades civiles, esto es, sin el derecho procesal. El primero, sin el segundo, es un derecho abstracto, y el segundo, sin el primero, es un derecho vacío.

Con mucha frecuencia, al revisar la jurisprudencia, nos encontramos con resoluciones judiciales que, desde un punto de vista estrictamente material, pueden tener difícil explicación. Sin embargo, el fallo se explica las más de las veces en atención a las vicisitudes del proceso: si no se admitió tal o cual prueba, si precluyó la alegación de algún hecho o fundamento jurídico, o si las partes no llevaron a cabo alguna actuación que podía perjudicar la futura interposición de algún recurso procesal, por ejemplo.

En las páginas que siguen se contiene una aproximación sintética a las reglas del procedimiento civil y una explicación práctica de algunas de las cuestiones procesales más relevantes del proceso desde la perspectiva del derecho de daños. En modo alguno pretende ser un tratado exhaustivo sobre la materia ni, por tanto, sustituye el estudio de las leyes procesales, la jurisprudencia y la doctrina al respecto.

1. El proceso civil de reclamación de daños y perjuicios

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (en adelante, LEC) regula en el Título II del Libro II dos procesos declarativos ordinarios, que son los que están enumerados en el artículo 248.2 LEC: el juicio ordinario y el juicio verbal.

Como veremos a continuación, nuestro legislador ha delimitado el ámbito de ambos, si bien ha establecido una cláusula de cierre, mediante la cual ha dispuesto que todas las contiendas judiciales que no tengan señalada por la Ley una tramitación específica, serán ventiladas y decididas por los trámites del juicio ordinario.

La Ley utiliza dos criterios para decidir qué materias jurídicas, o conflictos jurídicos, se resolverán a través de los trámites del juicio ordinario o el juicio verbal: el criterio objetivo y el de la cuantía, una vez excluidas ciertas materias que tienen señalada en la LEC una tramitación especial.

En el ámbito de las reclamaciones de daños y perjuicios, con carácter general:

i) Se decidirán en juicio ordinario las reclamaciones de más de 6.000 euros de cuantía. La cuantía de un pleito se fija según el interés económico de la demanda, que se calcula de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos 251 y siguientes LEC.

ii) Se decidirán en juicio verbal las reclamaciones de menos de 6.000 euros de cuantías.

iii) Se decidirán en todo caso por los trámites del juicio ordinario los pleitos en materia de derechos al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen.

En las páginas que siguen a continuación se exponen las reglas generales del juicio ordinario. Ulteriormente (*vid*. apartado 5), y a modo de apunte, se expondrán sintéticamente las principales diferencias entre el juicio ordinario y el verbal.

2. El proceso ordinario

Con el objeto de estudiar el juicio ordinario, podemos dividirlo en las siguientes fases: alegatoria, intermedia, probatoria y final.

2.1. Fase alegatoria: demanda y contestación. Reconvención.

a) Demanda

Dice el artículo 399 LEC que "*el juicio principiará por demanda*". La demanda es, así, el acto de incoación del juicio, el acto de petición o postulación y, en suma, el escrito rector del procedimiento que delimita el objeto del juicio[3].

La demanda debe incluir la identificación del tribunal, de las partes, del procurador y del abogado del demandante, los hechos -narrados "*de forma ordenada y clara*" y con expresión de "*los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones*" (artículo 399.2 LEC)-, los fundamentos de derecho procesales y sustantivos, y la petición o suplico.

> La LEC regula, en sus artículos 256 y siguientes, las diligencias preliminares, un conjunto de posibles actividades que obedecen a la finalidad de preparar el juicio y que se llevan a cabo antes de interponer la demanda. En el catálogo se encuentran, entre otras, la solicitud de exhibición de la cosa o la solicitud de exhibición de documentos necesarios para el juicio. En relación con las llamadas acciones colectivas o de clase (*Class actions*), las diligencias preliminares son esenciales para la averiguación de los integrantes de un grupo de afectados.

Una demanda defectuosa está abocada al fracaso. No basta tener la razón: hay que conocer las reglas del juego para convertir esa razón en una resolución judicial estimatoria. A este respecto, y por su relevancia práctica en los procedimientos de responsabilidad civil –tanto contractual como extracontractual-, conviene abordar el problema de la preclusión. De conformidad con el artículo 400 LEC:

[3] Francisco RAMOS MÉNDEZ, *Enjuiciamiento Civil,* Tomo II, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 1157-1158.

"Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.

1. La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a la demanda y a la contestación.

2. De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

Destacan las dos consecuencias prácticas siguientes:

1. **No se puede corregir una demanda defectuosa**. Más allá de las alegaciones complementarias y aclaratorias, y de las pretensiones complementarias, a que se refiere el artículo 426 LEC en el marco de la audiencia previa, una vez planteada la demanda y delimitado el objeto del litigio no es posible alterar el mismo, ni siquiera para corregir un defecto en la demanda.

   Véase, por ejemplo, la STS, 1ª, 1172/2003, de 12 diciembre, en un caso en que se ejercitaba una acción declarativa de dominio con posterioridad a un proceso de tercería de dominio:

   "La sentencia de esta Sala de 30 de julio de 1996 declaró que «no desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, **pues no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos**, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió»".

2. **No se pude dejar para un pleito posterior la reclamación de los daños y perjuicios**. Con carácter general, no se puede instar una demanda en la que se solicite, exclusivamente, que el Juzgado declare la responsabilidad del causante del daño si esta pretensión no se acompaña de la reclamación de las consecuencias derivadas de aquella declaración de responsabilidad, e.g., la indemnización de daños y perjuicios.

   La doctrina considera que las acciones meramente declarativas no pueden ejercitarse en los supuestos en que a la actora no le conviene o no le interesa solicitar una tutela de condena, como sucede en el presente caso. En este sentido, el Profesor ORTELLS RAMOS, *Derecho Procesal Civil*, Thomson-Aranzadi, 2007, p. 52, sostiene que:

   "[S]i por la naturaleza jurídica del derecho puede ser pedida la condena a prestación, no es admisible pedir una tutela de mera declaración, porque es contrario a la economía en el ejercicio de la potestad jurisdiccional permitir la realización de dos procesos si la tutela necesaria puede ser dispensada en uno sólo".

   Más recientemente, y con referencia expresa al artículo 400 LEC, la STS, 1ª, 164/2011, de 21 marzo, dictada en un caso en que se discutía la reclamación de daños derivados de un siniestro, establece que no puede dejarse para un pleito posterior una indemnización de daños y perjuicios no solicitada en el pleito anterior, siempre que entre dicha pretensión y el objeto principal del pleito exista una íntima conexión:

   "**No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero**, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión **cuando antes se omitieron pedimentos**, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió (SSTS 30.7.96, 3.5.00 y 27.10.00)", y, b) además, según esta misma sentencia, alcanza a cuestiones que se han deducido de

manera implícita en la demanda: "La cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, **cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace**, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado (SSTS 28.2.91 y 30.7.96), postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la nueva LEC".

La solicitud de declaración de responsabilidad civil no acompañada de la reclamación de daños y perjuicios es una estrategia relativamente frecuente –aunque arriesgada- cuando la demanda sirve al exclusivo fin de forzar una negociación y, muy particularmente, cuando se trata de limitar el riesgo de costas procesales. Y puede tener éxito, si se acredita la necesidad de adopción urgente de una resolución judicial que declare la responsabilidad civil del causante.

Junto con la demanda deben acompañarse todos los documentos de que quiera valerse la parte para sostener su posición. Son excepcionales los casos en que, con posterioridad a la presentación de la demanda, se permitirá a la parte demandante introducir una prueba documental o pericial (véanse los artículos 265, 270, 337, 338, 339, 386, 387, 426 y 427 LEC).

b) Contestación a la demanda y reconvención

La parte adversa dispondrá de un plazo de 20 días desde la notificación de la demanda para contestarla (artículo 404 LEC).

La contestación a la demanda se redactará en la forma prevista para la demanda (artículo 399 LEC) y, parecidamente a ésta, deberán exponerse todos los fundamentos de la oposición a las pretensiones del actor, alegando no sólo las excepciones materiales sino, además, cuantas excepciones procesales obsten a la válida prosecución del procedimiento (artículo 405 LEC).

El demandado puede también, y dentro del plazo para contestar a la demanda, plantear reconvención frente al demandante. La reconvención es la demanda que formula el demandado contra el demandante, aprovechando la oportunidad que le ofrece la pendencia del juicio[4]. La reconvención, que ha de proponerse a continuación de la demanda, adopta su misma forma y en ella habrá de expresarse la concreta tutela judicial que se pretende obtener respecto del actor y, en su caso, de terceros. El demandante reconvenido y, en su caso, los terceros, dispondrán de un plazo de 20 días para contestar a la reconvención, en los mismos términos que la contestación a la demanda (artículo 407 LEC).

Con la entrada en vigor de la LEC de 2000, la referencia del artículo 406.4 LEC a la preclusión, a la que antes nos hemos referido ("*será de aplicación a la reconvención lo dispuesto para la demanda en el artículo 400 LEC*"), extendió entre los abogados el temor de que resultara necesario plantear las reclamaciones que se tuvieran contra el demandante vía reconvención para evitar la preclusión y, en consecuencia, la extinción de las acciones que se tuvieran frente a aquel[5]. El temor resultó infundado. Con base en la doctrina jurisprudencial de las audiencias provinciales, creemos poder afirmar que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, con carácter general, una obligación de reconvenir. Véase el AAP Barcelona, Secc. 11ª, 35/2009, de 17 de febrero: "*tal carga (la de formular reconvención) no existe ni siquiera en la legislación procesal vigente. La LEC de 2000 establece la naturaleza puramente potestativa de la*

[4] Francisco RAMOS MÉNDEZ, 2008, p. 1301.
[5] Francisco RAMOS MÉNDEZ, 2008, p. 1302: "*la ley ha silenciado aposta el hecho de que, si no se hace uso de la reconvención, el demandado conserva vivas todas sus acciones, que pueden ejercitar en el juicio correspondiente, tal como decía la ley anterior. El silenciamiento parece intencionado, como digo, porque la ley quiere aplicar a la reconvención no formulada la preclusión definitiva*".

reconvención para el demandado, quien es libre de formularla". Cuestión distinta es que, formulada reconvención, la misma deba fundarse en todas las causas de pedir, sin que pueda reservárselas para un procedimiento posterior.

c) Fijación de los términos del debate

Los términos del debate, salvo las excepciones previstas para la audiencia previa que pasamos a examinar a continuación, vendrán determinados por demanda y contestación, por lo que con posterioridad no se admitirá ninguna modificación sustancial que altere las pretensiones objeto principal del pleito, so pena de incurrir en la denominada *mutatio libelli*, prohibida en nuestro ordenamiento jurídico (véase la STS, 1ª, 372/2011, de 1 de junio).

2.2. Fase intermedia: audiencia Previa

Tras las alegaciones iniciales de las partes, esto es, una vez contestada la demanda o, en su caso, la reconvención, la LEC prevé en sus artículos 414 y siguientes la celebración de la llamada audiencia previa, que tiene como finalidad:

a) En primer lugar, conseguir, si ello fuera posible, que las partes alcancen un acuerdo o transacción que evite la continuación del procedimiento (artículo 19 LEC). En la práctica, es altamente improbable que las partes alcancen un acuerdo en este momento, ni siquiera con la mejor voluntad del Juez. De ahí que la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles reconociera al Juez el poder de invitar a las partes a una mediación y le otorgara potestad para conminarlas a asistir a una sesión informativa. Son pocos los casos en que el Juez ha hecho uso de esta potestad hasta la fecha, y menos aún los casos en que tras un proceso de mediación las partes han alcanzado un acuerdo. No obstante, existe una voluntad clara de impulsar la mediación, como lo demuestra la reciente firma en septiembre de 2013 de un convenio de colaboración entre el CGPJ y la Cámara de Comercio de Barcelona por el que todos los jueces mercantiles de Barcelona remitirán de forma preferente los asuntos de mediación a la Cámara a través del Consolat de Mar.

b) En el caso de que el acuerdo no fuera posible -y, en consecuencia, hubiera de continuar el procedimiento-, examinar y resolver las cuestiones procesales planteadas por el demandado, por el actor a la vista de la contestación del demandado o en la eventual contestación a la reconvención, o incluso las que pueda plantear de oficio el propio órgano judicial.

c) La audiencia previa sirve, asimismo, para que las partes fijen de forma definitiva los términos del debate:

   Las partes pueden formular alegaciones complementarias (artículo 426.1 LEC), aclaraciones o rectificaciones (artículo 426.2 LEC), pretensiones complementarias o accesorias (artículo 426.3 LEC); dar a conocer hechos nuevos o de nueva noticia (artículo 426.4 LEC) e incluso aportar, con los límites establecidos, nuevos documentos y dictámenes (artículo 426.5 y 427.3 y .4 LEC).

   Las partes deben manifestar su posición sobre los documentos, particularmente si cuestionan o no su autenticidad, y sobre los dictámenes e informes que se hayan podido presentar por las partes, pudiendo proponer su ampliación (artículo 427.1 y .2 LEC). También pueden las partes solicitar la aportación de nuevos dictámenes cuya necesidad se hubiera puesto de manifiesto a raíz de las alegaciones complementarias o aclaratorias, aclaraciones o rectificaciones, o pretensiones complementarias o accesorias (artículo 427.3 LEC).

   Por último, las partes fijarán de forma definitiva cuáles son los hechos controvertidos, esto es, las cuestiones estrictamente fácticas de la controversia sobre las que no coinciden. La fijación de los hechos controvertidos tiene una importancia evidente: la

prueba que se solicite deberá venir referida, exclusivamente, al esclarecimiento de estos hechos controvertidos, por lo que si no se fija de forma correcta se corre el riesgo de que, posteriormente, en la fase de proposición de prueba, se inadmitan los medios de prueba propuestos por impertinentes.

d) Si existe disconformidad sobre los hechos, las partes pueden a continuación proponer las pruebas de que intenten valerse para demostrarlos.

Si no existe disconformidad y, en consecuencia, la controversia queda reducida a una cuestión estrictamente jurídica, la proposición y práctica de prueba resulta innecesaria y el caso queda visto para sentencia sin necesidad de celebración de juicio. Lo mismo sucede si, posteriormente, la única prueba propuesta fuera la documental (artículo 429.8 LEC). En este sentido, es muy frecuente que los abogados traten de evitar manifestar una plena conformidad con los hechos para garantizarse la práctica de alguna prueba (por ejemplo, interrogatorio de parte o declaración de testigos o peritos) –por el impacto que pueda causar al Juez oír sus explicaciones de viva voz- y, sobre todo, el trámite de conclusiones.

Es el Juez el que decide sobre la admisión o inadmisión de las pruebas propuestas por las partes, en atención a su necesidad, pertinencia y utilidad (artículo 283 LEC). Si un medio de prueba es denegado, es absolutamente indispensable recurrir en reposición (artículos 285.2 y 451 LEC) en el mismo momento y si, como sucede en la mayor parte de los casos, el recurso es desestimado, formular protesta, a efectos de poder reiterar la solicitud de admisión de la prueba en segunda instancia.

En la práctica, la fase de proposición y admisión de prueba es, acaso, la más tensa de todas las que componen la audiencia previa, pues se convierte en un buen número de ocasiones en una lucha encarnizada para lograr la admisión de las pruebas propias y la inadmisión de las ajenas, desarbolando de este modo la estrategia del contrario. ¡Buena parte del pleito va en ello!

e) Por último, el juez señala día y hora para la celebración del juicio y cita a las partes, al tiempo que acuerda citar a las restantes personas que hayan de intervenir en el juicio y que las partes no se comprometan a citar por ellas mismas.

Típicamente, el guión de una audiencia previa sería el siguiente:

I. Intento de conciliación o transacción
II. Examen de cuestiones procesales
III. Delimitación de los términos del debate
  A) Alegaciones complementarias (art. 426.1 LEC).
  B) Aclaraciones y rectificaciones (art. 426.2 LEC).
  C) Pretensiones accesorias o complementarias (art. 426.3 LEC).
  D) Hechos nuevos o de nueva noticia (art. 426.4 LEC).
  E) Nuevos documentos y dictámenes (arts. 426.5 y 427.3-4 LEC).
  F) Posicionamiento ante documentos y dictámenes (art. 427.1-2 LEC).
  G) Fijación de los hechos controvertidos (art. 428.1 LEC)
IV. Proposición de Prueba

2.3. Fases probatoria y final: juicio

En un juicio ordinario, todas las actuaciones tienen como fin último la celebración de una sesión oral en la que se practican las pruebas propuestas y admitidas y tienen lugar, en último término, las conclusiones del procedimiento. A este acto se le denomina, propiamente, juicio. Dice el artículo 431 LEC:

> "El juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas de declaración de las partes, testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial en su caso y reproducción de palabras, imágenes y sonidos.

> Asimismo, una vez practicadas las pruebas, en el juicio se formularán las conclusio-nes sobre éstas".

El juicio se celebra, de ordinario, en unidad de acto, y sólo cuando ello no sea posible (por ejemplo, debido al elevado número de pruebas a practicar) se continúa en las sesiones necesarias para completar las actividades previstas en la LEC y que, generalmente, ya habrán sido programadas en la audiencia previa. No es infrecuente, en este sentido, que una vista que comenzó a primera hora de la mañana pueda alargarse –sin apenas alguna pequeña pausa- hasta bien entrada la tarde.

Al juicio han de concurrir los abogados y procuradores de las partes y, en el caso de que se hubiera solicitado su interrogatorio, la propia parte o representante legal de la misma. Si ninguna de las partes comparece, el pleito queda visto para sentencia, pero continuará si concurriese cualquiera de ellas (artículo 432 LEC). Ahora bien, si la parte llamada a declarar no concurriera al juicio, podrá tenérsela por confesa (*ficta confessio*, artículo 304 LEC), esto es, podrán considerarse reconocidos por ella los hechos en que hubiera intervenido y cuya fijación como ciertos le sea perjudicial.

Con carácter previo a la práctica de las pruebas, las partes podrán hacer alegaciones acerca de hechos nuevos acaecidos o conocidos con posterioridad a la audiencia previa. Asimismo, también con carácter previó, se resolverá cualquier cuestión planteada en relación con la vulneración de derechos fundamentales en la obtención u origen de alguna prueba.

Resueltas las eventuales cuestiones previas, la vista se dedicará a continuación a la práctica de la prueba. Las pruebas se practican por el orden establecido en la LEC: declaración de las partes, testigos, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial y reproducción de palabras, imágenes y sonidos (artículo 431 LEC).

> Debido a que puede transcurrir largo tiempo entre la interposición de la demanda o contestación y la vista de juicio, y para garantizar la práctica de la prueba, la LEC prevé en sus artículos 293 y siguientes las llamadas medidas de aseguramiento de prueba. Estas medidas se dirigen a evitar que "*por conductas humanas o acontecimiento naturales, que puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas, resulte imposible en su momento practicar una prueba o incluso carezca de sentido proponerla*". Desde la interposición de la demanda hasta la celebración del juicio puede transcurrir más de un año, según el partido judicial, por lo que es conveniente valorar la adopción de estas medidas para garantizar que la prueba pueda llegar a practicarse.

Por último, y al término de la práctica de la prueba, las partes concluyen con un informe oral –sólo excepcionalmente, y aunque no está previsto legalmente, los jueces admiten conclusiones escritas para facilitar su labor- en el que se extraen las consecuencias de su actividad probatoria en relación con sus respectivas peticiones de juicio. Dice el artículo 433.2 LEC:

> "Practicadas las pruebas, las partes formularán oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa, si, a su juicio, los hechos relevantes han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso, probados o inciertos.
>
> A tal fin, harán un breve resumen de cada una de las pruebas practicadas sobre aquellos hechos, con remisión pormenorizada, en su caso, a los autos del juicio. Si entendieran que algún hecho debe tenerse por cierto en virtud de presunción, lo manifestarán así, fundamentando su criterio. Podrán, asimismo, alegar lo que resulte de la carga de la prueba sobre los hechos que reputen dudosos.
>
> En relación con el resultado de las pruebas y la aplicación de las normas sobre presunciones y carga de la prueba, cada parte principiará refiriéndose a los hechos aducidos en apoyo de sus pretensiones y seguirá con lo que se refiera a los hechos aducidos por la parte contraria".

Las conclusiones son una pieza clave en el proceso judicial. No basta con que, tras la práctica de la prueba, tales o cuales hechos hayan quedado demostrados. Ulteriormente, hay que poner de manifiesto al juez la relevancia de los hechos probados en el marco de la cuestión jurídica debatida en el procedimiento.

> Los jueces dan una gran importancia a las conclusiones del juicio siempre que las mismas consistan, precisamente, en este ejercicio de síntesis de la prueba practicada y relación de la prueba con los fundamentos de derecho que sustentan las pretensiones de las partes. Un buen informe de conclusiones es esencial en la formación del juicio del tribunal.

De este modo, en el informe de conclusiones se resumen y valoran las pruebas practicadas y se expone si, a juicio del abogado informante, los distintos hechos controvertidos han quedado o no probados; en segundo lugar, se informa sobre los argumentos jurídicos que sustentan las pretensiones de las partes; y por último, se indica al tribunal si se mantienen las respectivas peticiones o si, como consecuencia del resultado de la prueba practicada, se modifican (por ejemplo, se reduce el monto de la indemnización reclamada, se concreta una petición genérica, etc.)[6].

Antes de dictar sentencia es posible la adopción de las llamadas diligencias finales (artículos 435 y 436 LEC), que consisten en diligencias o actuaciones de prueba que se pueden llevar a cabo, principalmente, cuando (i) no se hubiera podido practicar una prueba admitida; (ii) se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia previstos en el artículo 286 LEC.

2.4. Sentencia: aclaración, corrección y complemento

Terminado el juicio, es función del tribunal decidir la controversia, esto es, enjuiciar el asunto. La estructura de las sentencias, que se regula en los artículos 248 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 209 LEC, es la siguiente: encabezamiento, donde se expresan los datos identificativos del procedimiento y de las partes; antecedentes de hecho, donde se consignan con claridad y concisión los hechos que sustentan las pretensiones de las partes; fundamentos de derecho, que contienen las razones jurídico-legales que sustentan el fallo; y por último, el fallo, que contiene los pronunciamientos de la sentencia.

Los artículos 214 y 215 LEC prevén la posibilidad, a instancia de parte o, según los casos, incluso de oficio, de aclarar, corregir, subsanar o complementar las sentencias oscuras, que contengan errores o que sean incompletas. La falta de solicitud de aclaración, corrección, subsanación o complemento puede ser causa de inadmisión de ulteriores recursos frente a la sentencia.

> Esto es especialmente relevante en cuanto al acceso al recurso extraordinario por infracción procesal, en la medida en que constituye causa de inadmisión la omisión del "*deber de agotar todos los medios posibles para la denuncia o subsanación de la infracción o el defecto procesal (artículo 470.2 LEC, en relación con el artículo 469.2 LEC)*", cusa en la que se incluye la "*alegación de falta de motivación (artículo 469.2 LEC), de la vulneración del principio de congruencia y de otros vicios in iudicando o in procedendo de la sentencia recurrida si no se ha solicitado la aclaración, corrección, subsanación o complemento de la sentencia (artículos 214 y 215 LEC)* (Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, de 30 de diciembre de 2011).

[6] Francisco RAMOS MÉNDEZ, 2008, p. 70.

3. Recursos

Contra la sentencia de primera instancia cabe interponer recurso de apelación que será resuelto por la Audiencia Provincial que corresponda (artículos 455 y siguientes LEC). El recurso no permite introducir nuevas pretensiones, excepciones o cuestiones nuevas, sino que sólo podrá versar sobre las pretensiones que se hubieran planteado en la instancia.

Tras la reforma de la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, el recurso se interpone ante el juzgado que hubiera dictado la sentencia recurrida en el plazo de 20 días. Ulteriormente, una vez presentadas las eventuales oposiciones el recurso, será elevado a la Audiencia Provincial correspondiente que deba resolverlo (artículo 458 LEC).

El recurso de apelación es una segunda instancia, de tal modo que la Audiencia Provincial no estará vinculada por la valoración de la prueba efectuada por el juzgado *a quo* ni por la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.

Cuestión distinta son los recursos extraordinarios: el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, que resuelven el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia que corresponda, en función de que el derecho aplicable a la controversia sea común o foral, respectivamente, son recursos extremadamente formalistas que presentan importantes limitaciones:

(i) El recurso extraordinario por infracción procesal procede contra sentencias y autos dictados en segunda instancia (artículo 468 LEC). Los motivos son tasados (artículo 469 LEC): infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva y funcional; infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia; infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del juicio, cuando la infracción determina la nulidad conforme a la ley o haya podido producir indefensión; vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española.

(ii) El recurso de casación, por su parte, procede contra sentencias dictadas en segunda instancia y habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (artículo 477 LEC). El recurso contra sentencias dictadas en segunda instancia procede en los siguientes casos: cuando se hayan dictado para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución; siempre que la cuantía del proceso exceda de 600.000 euros; y, cuando la cuantía del proceso no exceda de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.

Tras la reforma de la LEC por la Ley 37/2011, estos recursos se interponen, individual o conjuntamente, según los casos (Disposición Final 16ª LEC) directamente ante el órgano que dictó la resolución recurrida en plazo de 20 días. Ulteriormente el recurso será elevado al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia que deba resolverlo.

A diferencia de la apelación, en los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación los autos se elevan al Tribunal Supremo o Superior de Justicia inmediatamente después de su interposición. Una vez que se personen las partes, el Tribunal decidirá sobre la admisión de los motivos. Típicamente, el Tribunal pondrá de manifiesto a las partes las posibles causas de inadmisión del recurso y se abrirá un plazo de alegaciones de 10 días para que las partes se manifiesten al respecto.

El Tribunal Supremo, sobre todo, pero también algunos Tribunales Superiores de Justicia, han emitido criterios sobre la admisión de los recursos, que interpretan y complementan la regulación contenida en la LEC. El examen de admisión es muy riguroso y ha sido muy criticado por la doctrina, en la medida en que, las más de las veces, el recurso simplemente se inadmite (sucede en más del 90% de los recursos interpuestos ante la Sala Primera del

> Tribunal Supremo), avanzándose de este modo la resolución del recurso sin entrar a conocer del fondo.

Las causas de admisión de los motivos de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación son tasadas. Así, por ejemplo, en relación con la valoración de la prueba, el Tribunal Supremo no puede llevar a cabo una valoración de la prueba distinta, salvo que se acredite que la valoración de la Audiencia Provincial es ilógica o arbitraria. La casación, por su parte, no es una nueva alzada; no es una tercera instancia, y en consecuencia, el Tribunal se limita "*a conocer de la regularidad de la aplicación del derecho o de determinados principios básicos del juicio por los tribunales de instancia*[7]".

La inadmisión de los recursos, o en su caso, la sentencia que se dicte, ya sea estimatoria o desestimatoria, pone fin al proceso judicial de manera firme, y de ella se predican los efectos de la cosa juzgada (artículos 207 y 222 LEC).

4. Ejecución provisional y definitiva. Medidas cautelares.

Como decía CALAMANDREI, a quien citamos al comienzo de estas páginas, no basta con obtener una resolución favorable, sino que hace falta encontrar un deudor que pueda pagar.

Si el demandado no cumple voluntariamente con la sentencia, es necesario entonces instar su ejecución para dar de este modo cumplimiento al fallo de la resolución judicial y así obtener satisfacción.

Son ejecutables las sentencias firmes (artículos 538 y siguientes), pero también las sentencias de primera instancia o apelación que no sean firmes porque hayan sido objeto de recurso, en lo que se conoce como ejecución provisional (artículos 524 y siguientes). Aunque con algunas limitaciones. En síntesis, son ejecutables provisionalmente los pronunciamientos de condena dineraria pero no los pronunciamientos que condenen a emitir una declaración de voluntad. Además, no cabe la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Cuando la resolución no es firme, el demandado no tiene propiamente obligación de cumplir la sentencia si el demandante no insta su ejecución provisional, sin perjuicio de que, desde que se dictó, se devengan los intereses de la mora procesal del artículo 576.1 LEC:

> "Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley".

Por este motivo, existe reiterada doctrina que señala que en el caso de que el ejecutado consigne voluntariamente el importe de la condena, dentro de los 20 días siguientes a la notificación del auto despachando ejecución provisional, sin formular oposición, no procede el pago de las costas de la ejecución (SAP Madrid, Secc. 10ª, 1049/2004, de 16 de noviembre, o SAP Madrid, Secc. 14ª, 603/2007, de 30 de octubre).

Para un estudio exhaustivo de la ejecución, provisional y definitiva, nos remitimos a Francisco RAMOS MÉNDEZ (2008), *Enjuiciamiento Civil*, Tomo I, Atelier, Barcelona, pp. 109 y ss.

Por último, es necesario advertir que para garantizar la ejecución de la sentencia que se dicte en el procedimiento es posible solicitar la adopción de medidas cautelares, cuya regulación se contiene en los artículos 721 y siguientes LEC. En particular, dice el artículo 726 LEC:

---

[7] Francisco RAMOS MÉNDEZ, 2008, p. 1489.

> "1. El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características:
>
> 1.ª Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente.
>
> 2.ª No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.
>
> 2. Con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte".

La adopción de medidas cautelares requiere justificar (i) el peligro de la mora procesal (*periculum in mora*), esto es, el riesgo de que durante la pendencia del proceso se produzcan situaciones que dificulten o impidan la efectividad de la tutela judicial que se pueda otorgar en la eventual sentencia estimatoria; (ii) la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*), esto es, sin prejuzgar el fondo del asunto, el juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión; (iii) de ordinario, prestar caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pueda causar al patrimonio del demandado (artículo 728 LEC).

5. Juicio verbal

En el juicio verbal (artículos 437 y siguientes LEC), a diferencia del juicio ordinario, la fase alegatoria queda dividida: la demanda (ordinaria o sucinta) es escrita, pero la contestación a la demanda se produce en la primera parte del juicio o de la vista a la que son convocadas las partes (artículo 440 LEC). A efectos prácticos (artículo 443 LEC), en esta vista se contesta a la demanda y, posteriormente, se acumulan en un mismo acto las actuaciones propias de la audiencia previa del juicio ordinario y del juicio. Así, se resuelven las posibles excepciones, se fijan los hechos controvertidos y se propone la prueba que se practica inmediatamente a continuación (de ahí que las partes puedan solicitar al Juzgado con antelación que cite a los testigos que no puedan aportar ellas mismas y de cuyo testimonio pretendan valerse en el juicio, caso de que posteriormente, en el juicio, se admita la prueba). A diferencia del juicio ordinario, la LEC no prevé un trámite de conclusiones, aunque en atención a la complejidad del asunto algunos jueces pueden invitar a las partes a formularlas.